Sommaire de l'article

Parution: juillet 2023

Annexes

A 1 - Plus-values immobilières : abattement pour durée de détention

L'essentiel du patrimoine privé - La Revue Fiduciaire - éd. 2023

La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits immobiliers est réduite d'un abattement pour chaque année de détention au-delà de la 5e dont le taux et la cadence diffèrent selon l'assiette d'imposition :

-pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il est de 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu'à la 21e, et de 4 % au terme de la 22e année de détention. Ce qui conduit à une exonération totale d'impôt sur le revenu après 22 ans de détention ;

-pour le calcul des prélèvements sociaux, il est de 1,65 % pour chaque année au-delà de la 5e et jusqu'à la 21e, de 1,60 % pour la 22e année de détention, et de 9 % au-delà de la 22e. Ce qui conduit à une exonération totale de prélèvements sociaux après 30 ans de détention.

Fraction imposable des plus-values immobilières après abattement pour durée de détention **Impôt**

Nombre d'années pleines de détention	Calcul de l'IR		Calcul des prélèvements sociaux		
	Taux d'abattement (en %)	Fraction im posable (en %)	Taux d'abattement (en %)	Fraction imposable (en %)	
De 0 à 5	0	100	0	100	36,20 (1)
6	6	94	1,65	98,35	34,78 (2)
7	12	88	3,30	96,70	33,35
8	18	82	4,95	95,05	31,93
9	24	76	6,60	93,40	30,50
10	30	70	8,25	91,75	29,08

11	36	64	9,90	90,10	27,66
12	42	58	11,55	88,45	26,23
13	48	52	13,20	86,80	24,81
14	54	46	14,85	85,15	23,39
15	60	40	16,50	83,50	21,96
16	66	34	18,15	81,85	20,54
17	72	28	19,80	80,20	19,11
18	78	22	21,45	78,55	17,69
19	84	16	23,10	76,90	16,27
20	90	10	24,75	75,25	14,84
21	96	4	26,40	73,60	13,42
22	100	0	28	72	12,38
23	100	0	37	63	10,84
24	100	0	46	54	9,29
25	100	0	55	45	7,74
26	100	0	64	36	6,19
27	100	0	73	27	4,64
28	100	0	82	18	3,10
29	100	0	91	9	1,55
30	100	0	100	0	0

(1) (100 x 19 %) + (100 x 17,2 %).

(2) (94 x 19 %) + (98,35 x 17,2 %).

A 2 - RM Grosskost - 28 juin 2005

Rép. Grosskost n° 55175, JO 28 juin 2005, AN quest. p. 6466

Texte de la question

Mme Arlette Grosskost souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouveau barème fiscal pour les liquidations de droit d'enregistrement. À compter du 1er janvier 2004, un nouveau barème fiscal, codifié à l'article 669 du code général des impôts, fixe les valeurs respectives de l'usufruit viager et de la nue, propriété applicables pour la liquidation des droits d'enregistrement. Ce nouveau barème fiscal a pour conséquence d'augmenter la valeur fiscale de l'usufruit car il tient compte de l'allongement de la durée de vie, mais il ne correspond pas à la valeur économique des droits démembrés. Ainsi, en cas d'apport en société de la nue-propriété d'un immeuble, la valeur de l'usufruit devrait pouvoir s'établir sur la base d'une évaluation économique rigoureuse, tenant compte du rendement de l'immeuble et de la durée de l'usufruit. L'application obligatoire du seul barème prévu à l'article 669 du CGI aurait pour conséquence directe de surestimer la valeur de la nue-propriété apportée et donc le capital social de la société. Elle irait à l'encontre des règles de sincérité du bilan et ne donnerait pas une image fidèle des comptes. En conséquence, elle lui demande si l'évaluation de la nue-propriété d'un bien apporté à une société peut être fixée sans utiliser le barème de l'article 669 du CGI.

Texte de la réponse

La réforme du barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété était souhaitée de longue date par le Parlement et les professionnels. En effet, les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété étaient jusqu'au 31 décembre 2003 fixées par un barème datant de 1901. L'article 19 de la loi de finances pour 2004 a actualisé ce barème en tenant compte d'un rendement des actifs et d'une espérance de vie plus proche des réalités actuelles. L'objectif poursuivi au travers de cette revalorisation est de retenir pour l'application des droits d'enregistrement des valeurs correspondant à la réalité économique. Cela étant, les parties demeurent libres de fixer le prix de l'usufruit et de la nue-propriété comme elles l'entendent. Dès lors, l'évaluation de la nue-propriété d'un bien apporté à une société peut être fixée sans utiliser le barème de l'article 669 du code général des impôts. En revanche, pour la liquidation des droits de mutation dus à cette occasion, l'administration fiscale retiendra la valeur telle qu'elle résulte de l'application du barème non seulement lorsque le prix stipulé sera inférieur à la valeur vénale, mais aussi lorsqu'il sera supérieur.

A 3 - Durée de l'amortissement (CE 10 juillet 2007, n° 287661)

CE 10 juillet 2007, 3e et 8e s.s. réunies, n° 287661

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2005 et 27 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SA SCA OUEST, dont le siège est route de Cordemais à Saint-Etienne-de-Montluc (44360), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA SCA OUEST demande au Conseil d'État

1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 21 janvier 2003 du tribunal administratif de Nantes, rectifié par une ordonnance du 21 février 2003, prononçant la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 1996 et, d'autre part, remis cette cotisation intégralement à sa charge ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

-le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

-les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SA SCA OUEST,

-les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI de la Motte a été créée en 1972 par des associés personnes physiques de la SA SCA OUEST afin de donner en location à cette dernière société un ensemble immobilier constitué d'entrepôts, de bureaux et d'aires de stationnement, sis à Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Atlantique) ; que, le 29 juin 1995, la SA SCA OUEST a acquis la totalité des parts sociales de la SCI, dont elle est ainsi devenue l'associée unique ; que les résultats de la SCI, précédemment imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers, ont alors été déterminés selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux ; que la SCI, conformément à l'accord conclu entre les parties lors de la cession des parts, a réalisé une première clôture d'exercice le 28 juin 1995, puis une seconde le 31 décembre 1995 ; que ses résultats de l'année 1995 ont été, par suite, imposés primitivement, pour la période du le 1er janvier au 28 juin, entre les mains des associés personnes physiques en tant que revenus fonciers et, pour la période du 29 juin au 31 décembre, intégrés à la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la SA SCA OUEST ; qu'enfin, la SCI a opté, à compter du 1er janvier 1996, pour l'impôt sur les sociétés ; que le service a estimé que les résultats imposables de la SCI au titre de l'ensemble de l'année 1995 devaient être déterminés selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et imposés au nom de la SA SCA OUEST, dans la mesure ou cette dernière détenait la totalité des parts sociales au 31 décembre 1995 ; que, pour le calcul de l'amortissement au titre de l'exercice clos à la même date, le service a estimé qu'il y avait lieu de retenir la date de l'acquisition ou de la création des biens amortissables par la SCI et, après avoir constaté que certains de ces biens étaient déjà totalement amortis, a réduit en conséquence le montant des amortissements pratiqués au titre de l'année 1995 ; qu'enfin, le service a estimé qu'en conséquence de l'option de la SCI, à compter du 1er janvier 1996, pour l'impôt sur les sociétés, la plus-value latente imposable devait inclure le montant des amortissements qui auraient pu être pratiqués depuis l'acquisition ou la création des biens amortissables par la SCI et non les seuls amortissements effectivement pratiqués ; que la SA SCA OUEST demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 21 janvier 2003 du tribunal administratif de Nantes, rectifié par une ordonnance du 21 février 2003, prononçant la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 1996 et, d'autre part, remis cette cotisation intégralement à sa charge ;

Sur le redevable de l'imposition et les règles de détermination du régime fiscal applicable au titre de l'année 1995 :

Considérant que les bénéfices d'une société soumise au régime défini à l'article 8 du code général des impôts sont réputés réalisés dès la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des associés pour la part correspondant à ses droits dans la société ; qu'il en va ainsi en cas de clôture d'un exercice d'une société civile immobilière en cours d'année, sans qu'y fassent obstacle ni les dispositions de l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts, qui ont pour seul objet d'imposer aux sociétés immobilières visées à l'article 172 du même code le dépôt d'une déclaration annuelle de résultats, ni la circonstance que, postérieurement à cette clôture d'exercice, du fait d'un changement d'associés, les résultats imposables de la SCI auraient été déterminés, en vertu du I de l'article 238 bis K de ce code, selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux ; que, dès lors, en jugeant que l'administration était fondée à ne tirer aucune conséquence fiscale de la déclaration des résultats de la SCI arrêtés à la clôture de son exercice le 28 juin 1995 et que les résultats de la SCI de la Motte devaient être déterminés, pour l'année entière, selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et être ainsi imposés dans leur intégralité au nom de la SA SCA OUEST, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ;

Sur le montant des amortissements :

Considérant qu'en vertu du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, applicable à une société civile immobilière, la part de bénéfice correspondant, dans une société mentionnée à l'article 8, aux droits inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés est « déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits » ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 2°(...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...)» ; que la

durée d'amortissement d'un bien s'apprécie à la date d'acquisition ou de création de ce bien par l'entreprise ; que, par suite, alors même que la SCI de la Motte n'était pas tenue, avant l'année 1995, de comptabiliser les amortissements de ses biens des lors que ses résultats étaient déterminés selon les règles applicables aux revenus fonciers, et que la SA SCA OUEST devait procéder à la reconstitution comptable de ces amortissements, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que la durée d'amortissement de vingt ans qu'elle a appliquée, et dont il n'est pas contesté qu'elle correspondait à la durée normale d'utilisation de ses biens, devait être comptée à partir de la date d'acquisition ou de création des biens en cause et non de celle du changement des règles de détermination du résultat, sans que doive être pris en compte l'amortissement éventuellement déduit au titre de l'article 31 du code général des impôts, des lors que la société civile immobilière créée en 1972 par certains des associés personnes physiques de la SA SCA OUEST est toujours demeurée une même et unique entité avant comme après la cession des parts et que l'acquisition de la totalité des parts de la SCI de la Motte par cette société en 1995 n'a pas induit de changement du régime fiscal auquel elle était soumise ;

Sur l'imposition des plus-values latentes :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts : « Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse, totalement ou partiellement, d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter (...), l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social » ; et qu'aux termes du deuxième alinéa du II du même article de ce code : « Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II s ; l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine, et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avaient été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création » ; qu'enfin, aux termes de l'article 39 duodecies du même code : » 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :...b) aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt (...) 10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés... la fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2 » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'une société imposable selon les règles applicables aux revenus fonciers décide d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 202 ter du Code général des impôts, les plus-values latentes immédiatement imposables au régime des plus-values à court terme comprennent notamment les amortissements qui auraient été admis en déduction si la société avait été soumise à l'impôt sur les sociétés depuis sa création ; que, dès lors, en déduisant de la circonstance qu'antérieurement à l'année 1995, les résultats de la SCI de la Motte provenant de la location de ses immeubles ont été déterminés selon les règles applicables aux revenus fonciers, que l'administration était fondée à imposer comme plus-value à court terme, non seulement la part des amortissements réellement effectués par la SCI de la Motte au titre de l'année 1995 mais aussi les amortissements reconstitués correspondant à la période antérieure à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 septembre 2005 ne doit être annulé que dans la seule mesure où il a remis à la charge de la SA SCA OUEST les cotisations d'impôts sur les sociétés à raison des résultats déclarés par la SCI de la Motte au titre de l'exercice clos

par cette dernière le 28 juin 1995 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les résultats de la SCI de la Motte ne doivent être déterminés selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et imposés au nom de la SA SCA OUEST que pour la période allant du 29 juin au 31 décembre 1995 ; que, par suite, la SA SCA OUEST est fondée a demander que la base d'imposition de la SCI ainsi que les droits et pénalités auxquels elle a été assujettie soient réduits dans cette mesure ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 septembre 2005 est annulé en tant qu'il a remis à la charge de la SA SCA OUEST des cotisations d'impôt sur les sociétés à raison des résultats déclarés par la SCI de la Motte au titre de l'exercice clos par cette dernière le 28 juin 1995.

Article 2 : La SA SCA OUEST est déchargée des droits et pénalités mis à sa charge à hauteur de la réduction de la base d'imposition de la SCI de la Motte résultant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des résultats déclarés par celle-ci au titre de l'exercice défini à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

A 4 - Dépenses prises en charge à la place d'un associé par une personne morale (CAA Versailles 23 octobre 2007, n° 06VE00596)

CAA Versailles 23 octobre 2007, n° 06VE00596, 3e chambre

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Delpeyroux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303383 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

-La société civile immobilière « Les Iris » a bénéficié de la part de la société STIO d'une avance contre rémunération de 5 % d'un montant de 5 900 000 F qui doit s'interpréter comme un classique concours financier de la société mère à sa filiale, ce que ne conteste pas l'administration ;

-ni le cumul des fonctions d'associé, de banquier et de locataire ni la circonstance qu'il soit personnellement actionnaire à hauteur de 98,8 % de la société STIO et qu'il détienne de 40 % du capital de la société civile immobilière « Les Iris » ne révèlent d'acte anormal de gestion ; c'est donc à tort que le tribunal en a jugé autrement et que les associés de la SCI devaient être imposés sur le fondement de l'article 109 2° du code général des impôts ;

-Il ne saurait être reproché à la société STIO d'avoir essayé de trouver la meilleure rémunération pour ses disponibilités financières et d'avoir fait le meilleur choix en termes de location de ses locaux professionnels ;

-L'absence de contrat de prêt écrit n'a aucune incidence ;

-ni le fait le remboursement se fasse par imputation sur les loyers dus ni l'absence de remboursement en capital n'est anormal puisqu'il y a eu versement des intérêts ;

-Aucune somme n'a été mise à sa disposition de M. X puisque c'est la société civile immobilière « Les Iris », dont les statuts ne révèlent aucune intention frauduleuse, qui est propriétaire de l'actif immobilier et c'est à elle qu'il revenait de rembourser l'avance en compte courant consentie par la société STIO et de payer les intérêts ;

-Il ne peut être regardé comme propriétaire direct de 40 % de l'actif de la société civile immobilière Les Iris et il n'avait pas l'obligation d'avancer une somme égale à 40 % de l'investissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

-le rapport de M. Lenoir, président-assesseur ;

-les observations de Me Delpeyroux ;

-et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est actionnaire à 98,80 % de la société anonyme STIO dont il est également le président-directeur général ; que le 11 avril 1997, M. X et la société STIO ont, en vue d'acquérir un ensemble immobilier à Morangis, constitué la société civile immobilière « Les Iris », détenue à 60 % par la société STIO et à 40 % par M. X ; que le 29 mai 1997, la société STIO, d'une part, a consenti une avance en compte courant de 5 900 000 F au profit de la SCI « Les Iris », moyennant une rémunération de 5 % par an, pour paiement du coût d'acquisition de l'immeuble en cause, d'autre part, a pris à bail ledit immeuble moyennant un loyer annuel de 500 400 F HT ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a considéré que la société STIO avait, en finançant l'intégralité de l'acquisition de l'immeuble détenu par la SCI « Les Iris » dont elle ne détient que 60 % des parts, consenti à son associé, M. X, une libéralité égale à 40 % du coût de l'acquisition imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu du au titre de l'année 1997 auxquelles il a été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de cet avantage ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) » ;

Considérant que les dépenses prises en charge à la place d'un associé par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés constituent, pour le bénéficiaire, une libéralité imposable en tant que distribution ; qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, le requérant est devenu propriétaire, à hauteur de sa participation au capital de la société civile immobilière, de l'ensemble immobilier acquis le 29 mai 1997 sans avoir contribué personnellement au financement de cette opération ; que dès lors, et quelles que soient les modalités de financement utilisées pour la réalisation de l'opération en cause, les dépenses entièrement supportées par la société STIO pour l'achat d'un immeuble qui sera détenu à 40 % par M. X constituent, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts et à hauteur de cette participation, une libéralité imposable entre les mains de ce dernier en tant que revenu distribué ; que, par suite, M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en estimant qu'il avait bénéficié de la part de la société STIO d'un avantage constituant une distribution au sens des dispositions de l'article 109-1-2° précité du code général des impôts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

A 5 - Donation de la nue-propriété - donation indirecte (cass. com. 10 février 2009, n° 07-21807)

Cass. com. 10 février 2009, n° 07-21807

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2007), que Mme X... a constitué le 8 novembre 1989 avec ses trois enfants la société civile SFTC, dont le capital était composé de 1 200 parts ; que, le 20 février 1990, Mme X... a fait donation à ses enfants de la nue-propriété des 1 197 parts qu'elle détenait ; que la société a opté le 22 mars 1997 pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que l'assemblée générale a, par décisions des 28 juin 1996, 23 juin 1997, 20 mai 1999, 31 mai 2000 et 29 juin 2001, affecté à un compte de réserve les bénéfices réalisés par la société au cours des années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000 ; que, considérant que ces décisions répétées de mise en réserve des bénéfices s'analysaient en une donation indirecte faite par Mme X... à ses enfants, l'administration fiscale a notifié à M. Jean-Pierre X... le 5 mai 2003 un redressement ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir invalidé le redressement notifié le 5 mai 2003 et les impositions subséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée ; que cependant l'exigence d'un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée qui marque le transfert définitif de la propriété, n'a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée ; qu'en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, a droit aux dividendes ; que par ailleurs, il résulte de l'article 1844, alinéa 3, du code civil, que si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote concernant l'affectation des bénéfices appartient à l'usufruitier qui peut notamment les porter en compte de réserve ; qu'à cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les sommes portées en réserve constituent un accroissement de l'actif social revenant au nu-propriétaire ; que la distribution ultérieure des bénéfices mis en réserve ne saurait remettre en cause le principe de leur transmutation en capital ; qu'ainsi, en cas de distribution des réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire ; que, si le droit éventuel de l'usufruitier d'en obtenir la jouissance sous forme de quasi-usufruit n'est pas contesté, il apparaît que cette appréhension n'est que temporaire puisqu'à charge de restituer la somme à la fin de l'usufruit ; que dès lors, la décision de l'usufruitier de droits sociaux de mise systématique en réserve les bénéfices sociaux s'analyse en une renonciation définitive et irrévocable de sa part à appréhender les dividendes auxquels il a droit ; que cette opération est donc bien constitutive d'une donation indirecte consentie par l'usufruitier au profit du nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, qui a reconnu que « l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires », a néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X... aux motifs que « les réserves ainsi distribuées reviennent à l'usufruitier, soit que l'on considère que la

décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit, l'usufruitier retrouvant alors le droit d'exercer son droit de jouissance sur les sommes distribuées, même s'il a la charge de les restituer en fin d'usufruit » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ;

2°/ qu'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de chose donnée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, a reconnu que « l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires » ; que la cour d'appel a néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X... aux motifs que les réserves distribuées reviennent à l'usufruitier, « soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit » ; qu'en statuant de la sorte par une motivation alternative qui a laissé incertaine la base de la condamnation de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 894 du code civil ;

Mais attendu que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'il s'ensuit qu'avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et qu'en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire ; que, par ces motifs de pur droit, substitués aux motifs critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 12 avril 2006 et invalidé le redressement notifié le 5 mai 2003 et les impositions subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Pour l'administration fiscale, la politique constante d'inscription en réserves des bénéfices la SCI SCFC a entraîné un dessaisissement irrévocable de Thérèse X..., usufruitière, au profit de ses enfants. Les parts sociales sont par nature productives de revenus, mais le résultat de l'exercice ne devient un fruit qu'à dater de la décision de distribution. L'usufruitier a droit aux dividendes qui sont les bénéfices distribués, et n'a aucun droit sur les bénéfices qui sont mis en réserve. C'est pourquoi le législateur lui accorde le droit de vote pour l'affectation des résultats (article 1844 du code civil). En principe, lorsque l'usufruitier vote une résolution décidant une mise en réserve des bénéfices, il ne renonce pas à un droit de créance, puisque ce droit n'aurait existé que si la distribution des bénéfices avait été décidée. Cependant lorsque, comme en l'espèce, l'écran que constitue l'assemblée générale de la société décidant l'affectation des résultats s'avère fictif, Thérèse X... étant usufruitière de la quasi-totalité des parts sociales, il est possible d'affirmer que c'est bien elle qui est à l'origine de la politique de non-distribution des dividendes. Aucun projet d'investissement n'étant allégué, cette non-distribution n'est justifiée par aucun autre intérêt de la société

que la valorisation de son capital. C'est pourquoi l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires. Encore faut-il pour retenir une donation indirecte que ce dessaisissement du donateur soit irrévocable. Or, l'assemblée générale ordinaire a toujours la faculté de décider ultérieurement le versement d'un dividende prélevé sur les réserves. Les réserves ainsi distribuées reviennent à l'usufruitier, soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit, l'usufruitier retrouvant alors le droit d'exercer son droit de jouissance sur les sommes ainsi distribuées, même s'il a la charge de les restituer en fin d'usufruit. Il n'est donc pas possible de dire que Thérèse X..., en sa qualité d'usufruitière, perdrait de manière irrévocable ses droits sur les bénéfices mis en réserve. Il s'ensuit que pour ce motif au moins la décision du premier juge mérité d'être confirmée.

ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée ; que cependant l'exigence d'un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée qui marque le transfert définitif de la propriété, n'a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée ; qu'en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, a droit aux dividendes ; que par ailleurs, il résulte de l'article 1844 alinéa 3 du code civil que si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote concernant l'affectation des bénéfices appartient à l'usufruitier qui peut notamment les porter en compte de réserve ; qu'à cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les sommes portées en réserve constituent un accroissement de l'actif social revenant au nu-propriétaire ; que la distribution ultérieure des bénéfices mis en réserve ne saurait remettre en cause le principe de leur transmutation en capital ; qu'ainsi, en cas de distribution des réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire ; que, si le droit éventuel de l'usufruitier d'en obtenir la jouissance sous forme de quasi-usufruit n'est pas contesté, il apparaît que cette appréhension n'est que temporaire puisqu'à charge de restituer la somme à la fin de l'usufruit ; que dès lors, la décision de l'usufruitier de droits sociaux de mise systématique en réserve les bénéfices sociaux s'analyse en une renonciation définitive et irrévocable de sa part à appréhender les dividendes auxquels il a droit ; que cette opération est donc bien constitutive d'une donation indirecte consentie par l'usufruitier au profit du nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, qui a reconnu que « l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires » a, néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X... aux motifs que « les réserves ainsi distribuées reviennent à l'usufruitier, soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit, l'usufruitier retrouvant alors le droit d'exercer son droit de jouissance sur les sommes distribuées, même s'il a la charge de les restituer en fin d'usufruit » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de chose donnée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon a reconnu que « l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires » ; que la cour d'appel a néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X... aux motifs que les réserves distribuées reviennent à l'usufruitier, « soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit » ; qu'en statuant de la sorte par une motivation alternative qui a laissé incertaine la base de la condamnation de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 894 du code civil.

A 6 - RM Straumann Éric - 5 mai 2009

rép. Straumann n° 28171, JO 5 mai 2009, AN quest. p. 4357

Texte de la question

M. Éric Straumann interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de savoir si une acquisition démembrée constitue un abus de bien social. Ce système permet aux dirigeants de société d'acquérir la nue-propriété du bâtiment, l'usufruit étant acquis pour quinze ans par la société, dont le nu-propriétaire du bâtiment est, par ailleurs, le principal actionnaire. Cette solution est économiquement plus intéressante que la location par bail commercial. Plus particulièrement, un dirigeant a acquis la nue-propriété d'une maison contiguë à son habitation. Cela lui permet de recevoir dans une certaine convivialité et surtout discrétion ses fournisseurs et/ou clients principaux et, en général, les partenaires de la société. Elle permet également un développement harmonieux et conséquent de l'activité de la société. Ce bâtiment ainsi acquis n'est pas occupé à titre privé par le dirigeant, mais exclusivement à des fins professionnelles. Une interrogation demeure quant au montage juridique, qui pourrait constituer un abus de bien social, selon certains spécialistes, car la société a, en théorie, les moyens financiers d'acquérir la pleine propriété de ce bâtiment. Dans le même ordre d'idée, la qualification d'abus de biens social peut-elle être retenue en cas d'acquisition du bâtiment par une SCI dont l'associé principal est par ailleurs le principal actionnaire de la société locataire, société locataire ayant en théorie les moyens financiers d'acquérir ce bâtiment. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui apporter des éléments de réponse afin de dissiper les éventuels malentendus à ce sujet.

Texte de la réponse

La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'infraction d'abus de bien social doit permettre de sanctionner les dirigeants qui font un usage des biens de la société qu'ils savent contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés. Pour exercer son activité économique, une société doit avoir des locaux à sa disposition. Différents types de contrats permettent à une entreprise de bénéficier de tels locaux : contrat de vente, contrat de bail. Dans le cadre de la gestion de la société, les dirigeants sociaux sont libres de choisir les modalités contractuelles qui leur paraissent les plus adaptées à la situation de leur entreprise. Les montages juridiques décrits dans la question consistent soit en une acquisition démembrée d'un bien immobilier, soit en la mise en location d'un bien immobilier, propriété d'une société civile immobilière, elle-même détenue majoritairement par le principal actionnaire de la société locataire. Sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fonds, il ne semble pas que ces montages juridiques constitueraient en tant que tels des abus de biens sociaux. En effet, si l'opération semble pouvoir être réalisée dans l'intérêt du dirigeant de la société, elle ne sera pas pour autant forcément contraire à l'intérêt social. Elle dépendra, en réalité, des conditions économiques dans lesquelles seront réalisées les transactions. Il conviendra, par exemple, d'analyser le montant de l'acquisition du bien, à la fois par l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'origine des fonds, la durée de l'usufruit ainsi que les conditions dans lesquelles l'usufruit prendra fin. La capacité de la société à acquérir la pleine propriété du bien est inopérante pour déterminer si les faits en cause peuvent recevoir la qualification d'abus de biens sociaux.

A 7 - Acquisition de l'usufruit de droits sociaux à prix minoré : valeur à inscrire au bilan (CAA Nantes 15 février 2018, n° 16NT01325)

CAA Nantes 15 février 2018, 16NT01325, Luccotel, Inédit au recueil Lebon, 1re chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel Restaurant Luccotel a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 pour un montant de 317 179 euros.

Par un jugement n° 1502490 du 23 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 avril 2016, 20 mars 2017, 28 avril 2017, 28 septembre 2017, 26 octobre 2017, 15 décembre 2017, 15 janvier 2018 et 18 janvier 2018, la SARL Hôtel Restaurant Luccotel, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-le jugement méconnaît le principe du contradictoire, dans le cas où, la preuve de la notification le 19 décembre 2012 de la proposition de rectification aurait été apportée devant les premiers juges, dès lors que cette preuve ne lui a pas été communiquée ;

-les premiers juges ne pouvaient écarter la prescription sans la preuve de la mise à disposition du pli contenant la proposition de rectification notifiée le 19 décembre 2012 ;

-le service ne pouvait établir une nouvelle imposition au titre de l'année 2009 dès lors que le délai de reprise avait expiré au 31 décembre 2012 dès lors que la notification de la proposition de rectification le 2 janvier 2013 n'a pu l'interrompre en l'absence de preuve de notification antérieure ;

-la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été avisée de la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal, prévu par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, alors que l'administration a implicitement invoqué un tel abus de droit en se fondant sur la communauté d'intérêts existant entre elle-même et les cédants ;

-l'évaluation de l'avantage réputé par l'administration consenti à ses associés est infondée ; la valeur de la pleine propriété étant de 1 000 euros, l'usufruit qui n'en représente qu'une partie, ne pouvait être fixé à la somme de 632 993 euros, qui ne reflète pas une valeur pouvant être atteinte par le jeu normal de l'offre et de la demande ; la valeur devait être calculée en tenant compte de la valeur mathématique obtenue par actualisation de l'actif net comptable et de la valeur de productivité tirée de l'importance des bénéfices et de la valeur établie par capitalisation du dividende ainsi que l'a fait la commission de conciliation en matière de droits d'enregistrement, estimant la valeur de l'usufruit à 1 698 euros par part, et conformément à la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Nancy et du Conseil d'État ; l'usufruit portant non sur le bien immobilier lui-même mais sur les parts sociales, pour déterminer les revenus, il faut prendre en compte l'investissement, l'endettement et l'amortissement du bien ce qui a pour conséquence qu'elle ne pourra appréhender aucun flux de trésorerie au titre de son usufruit tant que la société civile immobilière (SCI) LBA n'aura pas remboursé son emprunt ; le revenu fiscal de la SCI LBA doit être déterminé selon les règles propres aux bénéfices industriels et commerciaux en vertu de l'article 238 bis K du code général des impôts, en intégrant donc la déduction d'un amortissement, d'autant qu'elle est une société soumise à l'impôt sur les sociétés comme le montre la déclaration n° 2072 souscrite indiquant un « revenu taxable de la SCI » de (-) 9 541 euros en 2009 et de (-) 9 321 euros pour 2010 ; le service a retenu cette règle dans un autre dossier après avis de la commission départementale des impôts et ne peut appliquer des méthodes différentes selon le contribuable, sauf à méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt ; la valeur mathématique de l'usufruit est proche de zéro dès lors que les parts sociales ne permettent d'obtenir ni revenus ni trésorerie futurs ; en capitalisant des revenus fonciers nets d'un impôt à 33,1/3 %, l'administration a mélangé la fiscalité personnelle constituée de revenus fonciers, qui ne tient pas compte de l'endettement de la société, et un taux d'impôt sur les sociétés, ce qui ne peut donc être admis, alors que l'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers serait à un taux de 45,5 %, contributions sociales comprises, conduisant à une valeur de 517 466 euros ; la valeur de l'usufruit doit être appréhendée en tenant compte d'une valeur mathématique affectée d'un coefficient 4 et d'une valeur de rendement affectée d'un coefficient 1 ainsi que l'a fait la cour d'appel de Colmar ;

-le paragraphe 190 du BOI-IR-BASE 10-10-30-20170406 indique, quand bien même il est postérieur, que « pour évaluer la valeur vénale d'un usufruit temporaire grevant un bien, il sera admis, à titre indicatif, de déterminer dans un premier temps la valeur vénale de la pleine propriété du bien correspondant puis, dans un second temps, d'appliquer à cette valeur les dispositions prévues au II de l'article 669 du code général des impôts », ce qui a pour conséquence que l'administration ne peut affirmer que le taux de 23 % est impropre à rendre compte de la réalité économique ;

-en matière de droits d'enregistrement, l'administration a mis en œuvre, à propos de la cession de l'usufruit temporaire des parts sociales de la SCI LBA, la méthode prévue par le II de l'article 669 du code général des impôts pour aboutir à une valeur d'usufruit de 233 600 euros qui pouvait être retenue à titre indicatif ;

-la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée dès lors que l'administration ne le démontre pas.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2016, 27 avril 2017, 20 octobre 2017, 6 novembre 2017, 15 janvier 2018 et 19 janvier 2018, le ministre chargé des finances publiques conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la valorisation de l'usufruit temporaire à un montant minimum de 233 600 euros.

Il fait valoir que :

-les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

-la valeur de l'usufruit des parts a été arrêtée en matière de droits d'enregistrement à la somme de 233 600 euros qui doit être retenue au minimum.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Delesalle,

-les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

-et les observations de Me A..., représentant la SARL Hôtel Restaurant Luccotel.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel Restaurant Luccotel, qui exerce une activité d'hôtel-restaurant à Loches (Indre-et-Loire), a pour associé unique, depuis le 23 novembre 2009, la SARL Conjugaison dont le capital est détenu à 100 % par M. et MmeB... ; qu'elle exerce son activité dans des locaux qu'elle a pris en location, en dernier lieu, auprès de la société civile immobilière (SCI) LBA, qui les a acquis le 12 novembre 2009 de la SCI Les Bournais au moyen d'un financement par emprunt ; que la SCI LBA, créée le 6 octobre 2009, a pour seuls associés, à parts égales, et cogérants M. et Mme B...et n'a pas opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés ; que le 28 décembre 2009, la SCI LBA a cédé à la SARL Hôtel Restaurant Luccotel l'usufruit temporaire, pour une durée de vingt ans, de la totalité de ses 100 parts sociales au prix de 4,6 euros la part, soit un prix total de 460 euros, que celle-ci a inscrit à l'actif de son bilan au cours de l'exercice 2010 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de la SARL Hôtel Restaurant Luccotel, l'administration a estimé que ce prix était très inférieur à la valeur vénale réelle de l'usufruit des titres cédés et a évalué cette valeur à la somme de 949 000 euros par capitalisation puis actualisation des flux de revenus à attendre du bien sur la période considérée de l'opération ; qu'elle en a déduit que la SCI LBA avait consenti une libéralité à la société cessionnaire et a rehaussé le montant de l'actif net de celle-ci de la somme de 948 540 euros sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts et de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code, en en tirant les conséquences sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2009 ; que, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique le 27 juin 2013, après avoir répondu aux observations du contribuable, le service a finalement évalué à 632 993 euros la valeur de

l'usufruit en prenant en compte le montant d'un impôt sur les sociétés théorique, soit une libéralité d'un montant de 632 533 euros ; qu'un supplément d'impôt sur les sociétés en résultant au titre de l'exercice clos en 2009 a été mis en recouvrement le 24 novembre 2014 pour un montant de 207 578 euros en droits et de 109 601 euros en pénalités, soit un montant total de 317 179 euros ; que la SARL Hôtel Restaurant Luccotel relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ce supplément d'impôt sur les sociétés ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'accusé de réception mentionnant la date de l'avis de mise instance, soit le 19 décembre 2012, de la proposition de rectification qui lui avait été adressée n'ayant pas été produit en première instance, la SARL Hôtel Restaurant Luccotel n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu, en tout état de cause, le caractère contradictoire de la procédure en ne le lui communiquant pas ; Sur la prescription du droit de reprise :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même code : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...). » ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable ; qu'il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 17 décembre 2009 relative à l'année 2009 a été adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au gérant de la SARL Hôtel Restaurant Luccotel ; qu'en l'absence de l'intéressé, un avis de mise en instance du pli au bureau de poste dont la société relevait a été déposé le 19 décembre 2012 ainsi qu'il ressort des mentions de l'avis de réception présenté pour la première fois en appel et ainsi que l'indiquait elle-même la SARL Hôtel Restaurant Luccotel en première instance ; que si M. et Mme B... ont retiré ce pli le 2 janvier 2013, dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation en vigueur du service des postes mais postérieurement à l'expiration, le 31 décembre 2012, du délai de reprise dont disposait l'administration au titre de l'année 2012, cette circonstance est sans incidence sur le caractère interruptif de prescription de la proposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. » ; que lorsque, pour justifier les réintégrations litigieuses, l'administration fait valoir non que le contrat litigieux aurait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que la qualification qu'il donnait aux prestations fournies ne correspondait pas à leur nature réelle et que les sommes versées en exécution de ce contrat étaient partiellement dépourvues de contreparties, elle ne se place pas sur le terrain de l'abus de droit ;

6. Considérant que si, pour apprécier l'existence d'une libéralité, l'administration s'est notamment fondée sur l'existence d'une communauté d'intérêts entre la SCI LBA, cédante, et la SARL Hôtel Restaurant Luccotel, cessionnaire, elle n'a pas pour autant fait valoir que le contrat de cession aurait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt mais elle s'est bornée à relever un élément de nature à justifier la qualification, en libéralité, de partie de la somme versée ; que la circonstance que le service ait par ailleurs appliqué une pénalité

de 40 % pour manquement délibéré est par elle-même sans incidence ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

7. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. / (...) ; / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; / (...).» ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit ;

8. Considérant que la valeur vénale des titres d'une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que l'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires ; qu'en l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, le service a eu recours à la méthode consistant à capitaliser puis actualiser les revenus à attendre des droits sociaux sur la période considérée de l'opération ; que s'agissant du revenu pris en compte, il a retenu le loyer annuel, estimé à 187 116 euros hors taxes, fixé d'après le bail antérieur conclu par la SARL Hôtel Restaurant Luccotel et donc doté selon lui d'une forte prévisibilité, correspondant ainsi au résultat brut dont aurait bénéficié la SCI en l'absence de cession, puis en a déduit des charges telles que les intérêts d'emprunt, les honoraires d'expertise comptable, les frais d'assurance liés à l'emprunt, la taxe foncière, soit un revenu net de 76 190 euros, sur lequel il a par ailleurs admis un abattement de 33,33 % correspondant à une imposition théorique à l'impôt sur les sociétés dès lors que la société cessionnaire est soumise à cet impôt ; que s'agissant du taux d'actualisation, il a retenu un taux de 5 % sur la période de vingt ans de cession, correspondant au bas de la fourchette communément admise selon lui, soit entre 5 % et 7 %, compte tenu d'un faible risque d'impayés au regard des résultats antérieurs de la SARL requérante et de la communauté d'intérêts existant entre le cédant et le cessionnaire ; qu'il a finalement évalué la libéralité à la somme de 632 533 euros, déduction faite de la valeur ainsi estimée du prix de cession s'élevant à 460 euros, qu'il a portée à l'actif, en immobilisation incorporelle, du bilan de la SARL requérante ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que pour apprécier la valeur vénale réelle d'un droit social, l'administration, qui doit rechercher un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue, n'est pas tenue de se fonder sur une unique méthode d'évaluation ; que la société requérante ne soutient pas sérieusement qu'il aurait existé une transaction équivalente permettant le recours à une méthode par comparaison et non d'appréciation directe, la création de la SCI LBA ne pouvant être regardée comme une transaction de nature à traduire une valeur issue du jeu de l'offre et de la demande ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la SARL Hôtel Restaurant Luccotel, le service, s'agissant d'une SCI relevant du régime d'imposition prévu par l'article 8 du code général des impôts et dont le résultat était, avant cession de l'usufruit de ses parts, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers entre les mains des personnes physiques détentrices de ces parts, a pu à bon droit estimer que les loyers issus de la location de l'immeuble constituaient un revenu brut pertinent pour apprécier la valeur de cet usufruit, lors du démembrement de ces parts, en vue de sa cession ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le revenu futur attendu devait être apprécié au regard d'un résultat comptable distribuable et d'une situation de trésorerie disponible déterminant une valeur de rendement applicable aux seules sociétés de capitaux rémunérant leurs actionnaires ou porteurs de parts par des distributions, dès lors que ce n'était pas le cas du cédant et ne pouvait entrer en ligne de compte, du point de vue du cessionnaire, SARL soumise à l'impôt sur les sociétés, pour déterminer la valeur de l'actif incorporel à porter en immobilisation ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, comme l'a estimé le service, la détermination du revenu net attendu, pour l'évaluation de la valeur de l'usufruit cédé et à immobiliser, devait toutefois se faire par application des règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 238 bis K du code général des impôts dès lors que la SARL était passible de l'impôt sur les sociétés et, en conséquence, en pratiquant un abattement représentant un impôt sur les sociétés théorique ; qu'à cet égard, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'un taux d'imposition à l'impôt sur le revenu supérieur à celui de 33,33 % retenu au titre d'un impôt sur les sociétés théorique ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que la SARL Hôtel Restaurant Luccotel ne peut utilement se prévaloir de ce que le service aurait appliqué une autre méthode pour l'appréciation de la valeur de l'usufruit temporaire d'une autre société, cette différence de méthode ne constituant pas en elle-même une rupture d'égalité devant l'impôt ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de ce que la valeur de l'usufruit devrait être appréhendée en tenant compte d'une valeur mathématique affectée d'un coefficient 4 et d'une valeur de rendement affectée d'un coefficient 1 ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que la SARL Hôtel Restaurant Luccotel se prévaut de ce que la valeur de l'usufruit temporaire a été arrêtée par l'administration à la somme de 223 600 euros au titre de la détermination des droits d'enregistrement par application à la valeur de la pleine propriété du barème prévu par le II de l'article 669 du code général des impôts ; que, toutefois, cette évaluation ne s'impose pas à l'administration pour la détermination de la valeur vénale de l'usufruit temporaire en vue de son immobilisation à l'actif ;

15. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n'apporte aucun élément, en tout état de cause, de nature à établir que celle-ci ne permettrait pas de respecter l'identité entre la valeur en pleine propriété et la somme de l'usufruit et de la nue-propriété ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de la proposition de rectification que le taux d'actualisation de 5 % retenu par le service correspond au bas de la fourchette comprise entre 5 et 7 % habituellement retenue ainsi qu'il n'est pas contesté, par agrégation, d'une part, d'un taux couvrant l'inflation et le coût du temps par référence au taux du marché des emprunts et, d'autre part, d'une prime de risque ; que la SARL Hôtel Restaurant Luccotel n'est pas fondée à demander que soit retenu un taux de 9,45 % dès lors que celui-ci correspond au taux de rendement de l'immeuble et ne peut servir à la détermination de la valeur de l'usufruit temporaire ; que, compte tenu de la communauté d'intérêts existant entre la SCI LBA et la société requérante, de ce que celle-ci exploite son activité depuis 1985 dans les mêmes locaux et de l'absence d'élément justificatif d'éventuelles difficultés rencontrées dans le secteur de la restauration, à Loches en particulier, l'administration justifie suffisamment du taux d'actualisation qu'elle a retenu ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

17. Considérant que la société ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 190 du BOI-IR-BASE 10-10-30-20170406 dès lors qu'il a été publié le 4 août 2015, soit après l'expiration du délai de déclaration de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2009 ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 17 du présent arrêt que la SARL Hôtel Restaurant Luccotel n'est pas fondée à soutenir que la méthode retenue par le service pour évaluer la valeur de l'usufruit temporaire est erronée ;

Sur les pénalités :

19. Considérant que pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré, le service s'est fondé sur l'écart très sensible entre la valeur d'immobilisation à l'actif telle qu'elle ressort de l'acte et la valeur vénale de cet actif, d'une part, et sur le fait que la société requérante ne pouvait ignorer que la sous-évaluation du droit incorporel correspondait à une libéralité accordée à son profit, d'autre part ; que l'administration établit ainsi le caractère délibéré du manquement ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hôtel Restaurant Luccotel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Hôtel Restaurant Luccotel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Hôtel Restaurant Luccotel et au ministre de l'action et des comptes publics.

A 8 - Apport temporaire d'usufruit - abus de droit (CA Paris 3 avril 2018, n° 16/06257)

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 3 avril 2018, n° 16/06257

FAITS ET PROCÉDURE

M. Daniel A. et Mme Liliane R. sont propriétaire d'un immeuble de rapport situé [... à Paris 16e] et seuls associés de la société civile agricole du Domaine de Brinon, elle-même propriétaire de terrains et d'un château situé à Brinon sur Beuvron, dans le département de la Nièvre (58)

Monsieur et Madame A. ont déposé les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2004 à 2010.

Par actes du 30 décembre 1981, 18 décembre 1991, 21 décembre 2001, ils ont apporté à la société civile agricole du domaine de Brinon l'usufruit temporaire de l'immeuble parisien pour des durées successives de 10 ans.

Par une proposition de rectification du 21 décembre 2010, l'administration a contesté l'opération d'apport d'usufruit temporaire en considérant qu'elle constituait un abus de droit.

L'administration estimait que l'opération d'apport temporaire d'usufruit de l'immeuble de rapport relevait d'une construction juridique élaborée dans le seul but d'éluder l'impôt, en permettant aux époux A., en leur qualité de nu propriétaires, de soustraire l'essentiel de la valeur de l'immeuble de l'assiette de leur ISF par le biais des dispositions de l'article 885 G du code général des impôts.

Le caractère abusif de la transmission temporaire d'usufruit a été recherché selon les modalités prévues à l'article L 64 du L.P.F.

Les évaluations de l'immeuble parisien et nivernais ont été réalisées selon la méthode comparative. La commission départementale de conciliation a admis la méthode par revenus. La commission départementale de la Nièvres a minoré les évaluations retenues par l'administration.

Par courrier du 15 novembre 2013, l'administration a informé les contribuables que, malgré l'avis des commissions, elle maintenait les impositions complémentaires.

Par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2014, M. et Mme A. ont fait assigner l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge de l'imposition.

Par un jugement rendu le 5 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de dégrèvement des époux A. et ordonné la restitution intégrale des sommes versées par les époux A.

L'Administration fiscale a interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2016

Par conclusions signifiées le 29 décembre 2017, l'administration demande à la cour de :

Dire et juger le directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 5 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 février 2016,

Confirmer que la procédure est justiciable de l'abus de droit ;

Ordonner le rétablissement des impositions déchargées sauf prise en compte des propositions de l'administration concernant les valeurs vénales à savoir retenir la valorisation de la commission de conciliation de la Nièvre pour le Château sis à Brinon sur Beuvron ;

Confirmer la valeur de l'immeuble parisien retenue par l'administration dans le cadre de la procédure de contrôle ;

Prendre acte que l'administration n'est pas opposée à corriger le montant des rappels de droits maintenus à l'issue de la procédure d'abus de droit en tenant compte du plafonnement de l'ISF si applicable, après transmission par les intimés des éléments permettant son calcul ;

Débouter les intimés de toutes leurs autres demandes ;

Les condamner aux entiers dépens de première instance

Par conclusions signifiées le 18 janvier 2018, Mme L. veuve Alix, Mme Florence A. et M Jean Marc A. demandent de :

À titre principal, déclarer l'appelant mal fondé en son appel ;

-L'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes ;

-Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

-Vu l'acte de notoriété établi par Me Xavier Grosjean, en date du 22 mars 2017 ;

-prononcer la mise hors de cause de madame Florence A. et monsieur Jean Marc A. ;

-à titre subsidiaire, déclarer la procédure comme prescrite et la déclarer nulle, confirmer l'annulation des AMR ;

-à titre subsidiaire, déclarer la procédure comme nulle en raison du manque de motivation de la proposition de rectification du à l'absence d'éléments de comparaison intrinsèquement similaires ;

-à titre subsidiaire, déclarer que l'opération d'apport temporaire d'usufruit n'est pas constitutive d'un abus de droit ;

-à défaut, écarter les éléments de valorisation retenus par l'administration fiscale et considérer que la procédure est nulle ;

-à tout le moins, retenir les valorisations des commissions départementales de conciliation ;

-à titre subsidiaire, ordonner que le montant du plafonnement de l'ISF soit déterminé et liquidé sur le montant des sommes redressées ;

-condamner l'état aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur l'intervention des héritiers

M. Daniel A. est décédé en décembre 2016. L'administration a fait délivrer une assignation en intervention forcée de madame Liliane A. (tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de monsieur Daniel A.), madame Florence A. et monsieur Jean Marc A. (enfants et héritiers de monsieur Daniel A.).

En application des dispositions du contrat de mariage, l'ensemble des droits et obligations résultant de la communauté universelle a été attribué en totalité au conjoint survivant, à savoir Madame Liliane A.

Par suite, Madame Liliane A. est seule tenue du passif d'ISF et des pénalités et amendes fiscales revendiquées. En conséquence, Mme Florence A. et M. Jean Marc A. seront mis hors de cause.

Sur l'abus de droit :

L'Administration fiscale estime que Monsieur et Madame A. ont agi dans un but exclusivement fiscal et commis un abus de droit.

En réplique, Mme A. soutient en substance que l'opération d'apport d'usufruit temporaire répondait à un objectif patrimonial effectif. M. A. avait mis en place l'apport temporaire d'usufruit dans l'espoir d'obtenir, à terme, un crédit lui permettant de financer les travaux de restauration de leur château. Parallèlement, il a recherché des financements auprès d'autres banques, en particulier le Crédit Foncier, avec lequel il a négocié les modalités d'une éventuelle ouverture de crédit, en prenant pour hypothèse le fait que la SCA du Domaine de Brinon disposait de ressources suffisantes au service de la dette grâce à l'apport en usufruit. Cette solution a permis à la SCA du Domaine de Brinon de bénéficier de ressources propres, d'un montant suffisant et sur une durée suffisante pour satisfaire au remboursement du prêt et au financement des travaux.

En outre, le surplus de loyers perçu au cours de cette période devait permettre de faire face à certains imprévus liés aux travaux en cours, en particulier à des erreurs d'estimation du coût des travaux, ce qui fut le cas. Cette opération se révèle une solution prudente, caractéristique de la gestion de son patrimoine en bon père de famille par le contribuable.

Le choix de la durée de dix ans avait été fait, initialement à une époque où une telle durée aurait présenté un quelconque intérêt sur le plan fiscal, ce qui permettait d'exclure, que, vingt ans plus tard, la réitération de l'opération pour cette même durée ait eu, cette fois, un objectif purement fiscal.

Mme A. soutient encore que la preuve des conditions nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure n'est pas apportée par l'administration. À titre subsidiaire, elle soutient que le délai de reprise ne peut excéder trois ans.

Ceci étant exposé,

Aux termes de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

L'article 885 G du code général des impôts dispose que :

Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie.

b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;

c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

L'administration fiscale reproche au tribunal d'avoir retenu l'objectif patrimomial allégué par les redevables sans prendre en compte les éléments détaillés dans la proposition de rectification, démontrant la mise en place de la construction juridique destinée à rendre les époux A. artificiellement nu propriétaires de l'immeuble locatif parisien alors qu'ils sont destinataires finaux des recettes locatives de ce bien et exercent les prérogatives d'un usufruitier, ce qui leur permettait une économie fiscale substantielle par le contournement de l'article 885 E du code général des impôts et des dispositions de l'article 885 G du code général des impôts.

L'existence de l'abus de droit est subordonnée à la démonstration par l'administration du caractère fictif de l'acte, ce qui permet d'éluder les charges fiscales tirées des textes précités.

Il est constant qu'au moment des faits M. et Mme A. étaient propriétaires d'un immeuble situé ..., composé de 52 appartements, pour partie donnés en location, à l'exception de trois appartements que les époux A. et leur fille occupaient à titre de résidence principale.

Le foyer fiscal est détenteur depuis 1967 de la totalité des parts de la société SCA, société civile agricole du domaine de Brinon, propriétaire d'un château et de terres dans la Nièvre, le château constituant leur résidence secondaire.

Par acte du 21 décembre 2001, ils ont apporté l'usufruit temporaire de l'immeuble parisien à la SCA du domaine de Brinon pour une durée de 10 ans.

L'actif de la SCA se compose de l'usufruit de l'immeuble locatif parisien et de la propriété nivernaise. Par l'opération de démembrement temporaire commencée en 1981, renouvelée depuis, dont celle de 2001 en litige, l'usufruitier, étant une personne morale non assujettie à l'ISF, la valeur de l'immeuble parisien détenu par les époux A. et indirectement au travers de la SCA se trouve imposé uniquement sur la valeur de l'usufruit temporaire.

Il résulte de ces éléments, que l'opération a permis une importante économie d'impôt dès lors que 80 % de la valeur de l'immeuble parisien n'est pas prise en compte dans l'actif net imposable à l'ISF du foyer fiscal. En effet, par le démembrement de propriété, les contribuables ont substitué à leur obligation de déclarer la valeur en pleine propriété, la seule valeur de l'usufruit de cet immeuble via la valorisation des parts de la SCA du domaine de Brinon qu'ils possèdent en totalité tout en continuant à percevoir les loyers à travers la SCA.

Les objectifs économiques allégués par les époux A. et que le tribunal a retenu, à savoir disposer de ressources propres pour financer par le recours à l'emprunt les travaux dans le château, sont démentis par l'analyse effectuée par l'administration fiscale figurant dans sa proposition de rectification.

Il ressort en effet des mentions de l'acte d'apport d'usufruit temporaire, que l'opération devait permettre de bénéficier de ressources suffisantes procurées par la perception des loyers de l'immeuble parisien et d'une ouverture de crédit de 500 000 F soit 77 224 euros pour financer les travaux de réhabilitation.

Or l'étude des déclarations de 2003 à 2009, sous forme de tableau déclinant les revenus et les travaux, montre que la perception des loyers de l'immeuble parisien vont bien au-delà des besoins de financement pour le château. Les recettes cumulées de l'immeuble démembré sont supérieures aux travaux entrepris. Ce que confirme le comité de l'abus de droit fiscal, qui indique, dans son avis, que les recettes nettes (..) étaient plus de trois fois supérieures au montant des travaux payés dans le château.

Au vu du montant des travaux et des ressources des redevables, il est indéniable que les travaux du château de Brinon pouvaient être financés sans avoir recours à l'apport d'usufruit.

Mme A. maintient en appel que l'opération d'apport d'usufruit à la SCA répondait à une logique de protection de patrimoine familial sur le long terme. Or, cet argument n'est pas davantage opérant dès lors que comme l'a souligné avec justesse le comité de l'abus de droit fiscal, d'une part l'usufruit temporaire sur une durée de dix ans

ne constitue pas un moyen efficace de protection du conjoint survivant, d'autre part la constitution de la SCA protégeait le conjoint survivant en lui attribuant toutes les parts en cas de décès.

Elle oppose le fait que l'organisation a été choisie en 1981 avant la création de l'impôt sur la fortune, mais cette assertion est sans objet dès lors que le litige porte sur l'apport réalisé en 2001 et qu'en tout état de cause les redevables ont reconduit cette opération en 1991 et en 2001, postérieurement à l'application de l'ISF.

Enfin, le choix de l'usufruit temporaire sur une durée de 10 ans, renouvelable n'était pas neutre dans la mesure où il était plus avantageux d'opter pour ce montage que pour celui d'une période de 20 ou 30 ans car c'est 40 % et 60 % de la valeur de l'immeuble qui aurait été alors prise en compte.

Le caractère fictif de l'opération se dégage ainsi à la lumière des éléments suivants :

-l'usufruit temporaire porte sur un bien immobilier, les nus propriétaires se sont réservés la jouissance de deux appartements à titre de résidence principale et d'un troisième pour leur fille sans que cette situation ne soit prévue dans l'acte d'apport temporaire d'usufruit ;

-la perception de loyers pour le reste de l'immeuble se fait au bénéfice d'une société civile relevant de l'article 8 du code général des impôts, dont la totalité des parts est détenue par les apporteurs ;

-les associés appréhendant la quasi totalité des revenus produits puisque cette société ne procède à aucun investissement pour son propre compte.

L'ensemble de ces faits ont permis à l'administration de conclure que l'opération de transfert de l'immeuble parisien renouvelée depuis 1981 et notamment sur la période de 2001 ne présentait qu'une préoccupation purement fiscale, à savoir la diminution de la base imposable en matière d'ISF.

La procédure est fondée sur la recherche de la motivation fiscale de ce choix d'organisation de la propriété par le contournement de l'article 885 E et de l'article 885 G du code général des impôts.

Le comité d'abus de droit a confirmé l'analyse de l'administration en relevant qu'en faisant échapper l'immeuble de rapport au principe de taxation de l'article 885 E pour le placer artificiellement dans le champ d'exception de l'article 885 G en conférant l'usufruit à une personne non visée par l'article 885 A, les époux A. ont poursuivi un but purement fiscal.

La démonstration par l'administration de l'abus de droit est suffisamment rapportée au sens de l'article 64 du livre des procédures fiscales.

Sur la date du fait générateur de l'abus de droit

Mme A. soutient que la procédure engagée par la proposition de rectification du 21 décembre 2010 est nulle car elle repose sur un fait prescrit, l'apport d'usufruit en date du 21 décembre 2001 relevant de la prescription abrégée.

La prescription de contrôle est celle qui se décompte à partir du fait générateur de l'impôt.

La prescription abrégée s'applique si l'acte révélateur établit l'exigibilité certaine des droits omis et si l'administration peut constater immédiatement au seul vu du document enregistré, l'existence du fait juridique imposable.

Si un doute subsiste quant à l'exigibilité des droits et s'il est nécessaire, pour en apporter la preuve, de procéder à des recherches quelconques, notamment par rapprochement de divers actes ou déclarations et examen de circonstances extrinsèques, le court délai de prescription ne s'applique pas.

En l'espèce, l'acte d'apport réalisé en 2001 est le point de départ des opérations de recherches entreprises par l'administration.

La procédure d'abus de droit est fondée sur la recherche de motivation fiscale du choix d'organisation de la propriété de l l'immeuble parisien et le contournement de l l'article 885 E précité ; l'administration a engagé son contrôle sur le fonctionnement de la SCA en 2010, l'acte de 2001 ne lui permettait pas de constater au seul vu du

document enregistré, l'existence du fait juridique imposable. Ses recherches lui ont montré que le démembrement temporaire de la propriété de l'immeuble réalisé en 2001 pour une durée de 10 ans permettait d'atténuer leur charge fiscale à compter de 2002.

Compte tenu du délai de reprise limitée à 6 ans, en vertu de l'article 186 du livre des procédures fiscales, l'administration a limité les rappels d'ISF de 2004 à 2010.

Les renseignements ont été exploités en 2010 dans les limites de la prescription applicable en matière de droit d'enregistrement. La procédure est donc régulière.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'évaluation de l'immeuble

L'administration a réintégré la valeur en pleine propriété de l'immeuble situé 25 rue de Civry dans le patrimoine imposable des époux A., tout en revoyant à la baisse la valeur des parts sociales de la SCA déterminée sur le seul actif constitué par le château de Brinon, soit :

Actif net imposable déclaré

+ valeur de la pleine propriété de l'immeuble de la rue de Civry

+ valeur des parts de la SCA du domaine de Brinon au titre de la seule propriété du château de Brinon

- valeur des parts de la SCA déclarées initialement

= Actif net ISF imposable rectifié

Elle a utilisé la méthode comparative pour faire une évaluation de l'immeuble parisien et du château nivernais.

La loi n'impose aucune méthode, mais la valeur par comparaison est privilégiée. La valeur à prendre en considération en matière de droits d'enregistrement est la valeur vénale réelle des biens qui est constituée par le prix qui pourrait être obtenu du bien par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état de l'immeuble.

L'immeuble, est décrit dans la proposition de rectification : il est situé [...] dans le 16e arrondissement de Paris, quartier recherché d'Auteuil, construit en 1929, composé d'un corps de bâtiment en façade sur rue, d'un rez-de-chaussée, de six étages courants et de deux étages sous combles, d'aspect extérieur soigné et équipé d'un ascenseur.

L'immeuble comprend 52 locaux dont 43 sont loués. La valorisation de cet immeuble entier a été réalisé sur la base d'une surface SDPHO calculée de 3 868 m2 détaillée dans l'annexe 1 de la proposition de rectification.

Les intimés évaluent la superficie à 3 741 m2. Ils estiment que les caves doivent être pondérées en utilisant un coefficient de 0,2 à 0,3 au lieu de 0,5 retenu par l'administration. Toutefois, ils ne justifient pas que l'état des caves légitimerait un si faible coefficient de pondération.

L'étude comparative à partir de comparaisons similaires est motivée. Les valeurs issues de la méthode comparative retenue par l'administration dans la proposition de rectification sont les suivantes : Année Valeurs issues de l'étude comparative

2004 : 10 327 000 euros

2005 : 9 963 600 euros

2006 : 10 822 000 euros

2007 : 10 973 000 euros

2008 : 12 087 000 euros

2009 : 11 619 000 euros

2010 : 12 037 000 euros

Les valeurs retenues par l'administration, de 2 670 euros/mé en 2004 à 3 112 euros/m2 en 2010 ne sont pas excessives. Mme A. critique les estimations qu'elle estime inappropriées. Elle soutient que la proximité du Parc ces Princes constitue une moins value.

Les critiques sont mal fondées dès lors que l'administration a choisi des immeubles entiers, de superficies cohérentes, si possible, situés dans l'ouest parisien, pour certains dans le 16e arrondissement, construits dans des années approchantes du début du siècle. L'antériorité des cessions prise en comparaison par rapport au fait générateur de l'impôt a été respectée.

Les termes de comparaison retenus pour dégager une dominante du marché pour ce type de bien aux dates du fait générateur de l'impôt, ont été sélectionnés pour se rapprocher autant que possible de la qualité intrinsèque de l'immeuble.

La commission de conciliation de Paris en séance du 17 septembre 2013, a, selon la méthode par capitalisation des loyers, proposée par les requérants, appliqué un taux de capitalisation de 5,5 % aux revenus dégagés par la location de l'immeuble.

L'administration n'a pas suivi cet avis et a maintenu la méthode comparative. Il est admis que pour les immeubles de rapport, la méthode par le revenu pour déterminer une valeur de marché est trop dépendante des conditions particulières de location, tels que loyers de convenance, immeuble loué partiellement. Or, en l'espèce, les époux A. et leur fille occupaient à titre d'habitation principale certains lots de l'immeuble. Il y a lieu de confirmer la valeur de l'immeuble parisien retenue par l'administration dans le cadre de la procédure de contrôle.

Sur l'évaluation du château situé à Brinon sur Beuvron à Nievre :

Les époux A. ont valorisé à l'actif de leur déclaration ISF les parts de la SCA domaine de Brinon après avoir attribué au château situé sur la commune de Brinon sur Beuvron des valeurs de 361 000 euros au 1er janvier 2004, 286 000 euros (2005), 426 000 euros (2006), 486 000 euros (2007), 528 000 euros (2008), 606 000 euros (2009) 836 000 euros (2010).

Lors de la procédure de contrôle, la valorisation réalisée par comparaison avec des biens d'exception (château, maison bourgeoise) situés pour la plupart dans le même département, la commission départementale de Nièvre a arrêté les valeurs à - 400 000 euros (2004), 412 000 euros (2005), 472 000 euros (2006), 535 000 euros (2007), 580 000 euros (2008), 625 000 euros (2009) et 672 000 euros (2010).

L'administration fiscale a accepté ces évaluations et a procédé ainsi aux rectifications suivantes : 9 452 000 euros en 2004, 9 075 000 euros pour 2005, 9 954 000 euros pour 2006, 10 108 000 euros pour 2007, 11 225 000 pour 2008, 10 724 000 euros pour 2009, 10 959 000 euros pour 2010.

La cour retiendra ces valeurs.

Sur le calcul de l'imposition,

Mme A. reproche à l'administration de ne pas avoir appliqué le plafonnement dans la proposition de rectification, mais l'absence de mise en œuvre de ce dispositif ne vicie pas pour autant l'ensemble de la procédure.

L'administration relève que dans la présente affaire, les époux A. n'ont jamais invoqué le plafonnement possible de leur cotisation ISF à la suite des rehaussements issus de la procédure engagée le 21 décembre 2010 sur l'ISF 2004 à 2010, ni revendiqué un montant de plafonnement applicable en considération de leur situation.

L'administration demande de prendre acte de ce qu'elle ne serait pas opposée à corriger le montant des cotisations supplémentaires ISF issues de la procédure pour tenir compte du plafonnement ISF, si les conditions sont remplies. Toutefois pour ce calcul, les revenus nets des années précédant le fait générateur de l' ISF doivent pouvoir être reconstitués. Il appartient à intimée de faire connaître les éléments de revenus permettant de vérifier si elle peut bénéficier du plafonnement. En cours de procédure, les redevables ne démontraient pas pouvoir en bénéficier.

Il est précisé que l'administration ne dispose pas de toutes les informations utiles au calcul sur l'ensemble de la période considérée. En effet, les époux A. détenaient un compte en Suisse non déclaré d'une valeur de l'ordre de 3 000 000 euros, qui a fait l'objet d'une régularisation en 2015, mais cette régularisation ne couvre pas toute la période du présent litige.

Sur les autres demandes

Mme Liliane R. veuve A. partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens

Il paraît équitable d'allouer à M. Le directeur des régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 février 2016,

Statuant à nouveau

MET hors de cause Mme Florence A. et M. Jean Marc A.

DIT que la procédure n'est pas prescrite

DIT la procédure régulière ;

ORDONNE le rétablissement des impositions déchargées sauf prise en compte des propositions de l'administration concernant les valeurs vénales à savoir la valorisation retenue par la commission de conciliation de la Nièvre pour le Château sis à Brinon sur Beuvron ;

CONFIRME la valeur de l'immeuble parisien retenue par l'administration dans le cadre de la procédure de contrôle ;

DONNE ACTE à l'administration n'est pas opposée à corriger le montant des rappels de droits maintenus à l'issue de la procédure d'abus de droit en tenant compte du plafonnement de l'ISF si applicable, après transmission par les intimés des éléments permettant son calcul ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Mme Liliane R. veuve A. à payer à M. Le directeur des régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme Liliane R. veuve A. aux entiers dépens d'appel

A 9 - Usufruit temporaire - abus de droit (CAA Nantes 31 mai 2018, n° 16NT04184)

CAA Nantes 31 mai 2018, n° 16NT04184, 1re chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C.... B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 pour le montant de 647 499 euros et la mise à la charge de l'État de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402759 du 26 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande de décharge et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un recours et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2016, 7 novembre 2017 et 23 mars 2018, le ministre chargé des finances demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme B..., en droit et pénalités, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 pour le montant de 643 499 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de rétablir, au titre de l'année 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une base supplémentaire de 251 556 euros.

Il soutient que :

-l'opération de cession de l'usufruit temporaire constitue un abus de droit au regard de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors, à titre principal, qu'elle constitue un montage juridique et économique artificiel organisé au bénéfice des associés de la SCI Kerjoany, agissant de concert dans le cadre d'une communauté familiale dans le but exclusif de d'obtenir l'avantage fiscal résultant de l'application littérale des dispositions du I de l'article 150 VC du code général des impôts auquel ils ne pouvaient normalement prétendre de la perception par la SCI dans le cadre du bail commercial de loyers producteurs de revenus fonciers imposables, en vertu de l'article 8 du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales aux noms de leurs foyers fiscaux ;

-l'opération constitue un abus de droit au regard de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors, à titre subsidiaire, qu'elle relève d'une situation de fictivité juridique du fait de son économie générale compte tenu notamment d'un prix de cession manifestement surévalué, de l'absence d'intérêt économique avéré pour les deux sociétés et de la substitution du droit temporaire d'usufruit au bail commercial alors en cours sans modification significative sur le droit de la SAS Le Gall Plafonds d'utiliser l'immeuble pour son exploitation ;

-subsidiairement, il doit être opéré une substitution de base légale dès lors que, d'une part, le prix d'acquisition de l'usufruit temporaire a été fixé à 1 300 000 euros alors qu'il doit être évalué à 796 887 euros et que la SAS Le Gall Plafonds a ainsi consenti un avantage occulte aux associés de la SCI à hauteur de 503 113 euros, imposable pour 251 556 euros chez M. et Mme B..., à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts et aux contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine sur le fondement des articles 1600-0 C et suivants du même code et, d'autre part, M. et Mme B...ne sont privés d'aucune garantie et notamment pas de celle tenant à la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2017 et 13 mars 2018, M. et Mme B..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Delesalle,

-et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

-et les observations de Me D..., représentant M. et MmeB...

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) Kerjoany est détenue pour la moitié de ses parts sociales par M. et Mme A...B..., co-gérants, et pour l'autre moitié par leur fils M. C...B..., par ailleurs représentant légal de la société par actions simplifiée (SAS) Le Gall Plafonds, venue aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Yves Le Gall. Le 29 juillet 2009, la SCI a cédé pour la somme de 1 300 000 euros à la SAS l'usufruit temporaire, pour une durée de quinze ans, du bâtiment industriel avec une partie de terrain dont elle est propriétaire à Brest et qui ont été loués à compter du 1er octobre 1990 à la SARL, puis à la SAS, en vertu d'un bail de neuf ans tacitement renouvelé et modifié par deux avenants. À la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Kerjoany, l'administration a estimé que cette cession devait être écartée comme constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que l'opération avait pour but exclusif de remplacer la perception de loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers par une plus-value de cession échappant à l'impôt entre les mains des associés de la SCI après application de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts. Cette rectification notifiée, le 15 octobre 2012, selon la procédure contradictoire, a eu pour effet d'imposer entre les mains des associés de la SCI Kerjoany le prix de cession de l'usufruit temporaire, en tant que loyers perçus d'avance et dans la catégorie des revenus fonciers, à hauteur de leur quote-part dans le capital de la SCI. Après rejet de leur réclamation préalable, M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 pour le montant total de 647 499 euros correspondant aux droits assortis de l'intérêt de retard et des pénalités de 80 % prévues par le b de l'article 1729 du code général des impôts en cas d'abus de droit. Le ministre chargé des finances relève appel du jugement du 26 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif a fait droit à leur demande de décharge et a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'existence d'un abus de droit :

2. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification (...)». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition incombe à l'administration.

3. Pour prononcer la décharge, les premiers juges ont estimé que l'administration, d'une part, n'invoquait pas le caractère fictif de l'opération réalisée par la SCI Kerjoany et la SAS Le Gall Plafonds et, d'autre part, n'apportait pas la preuve qu'en concluant la cession d'usufruit temporaire, la SCI avait voulu obtenir le bénéfice d'une application littérale de textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et avait exclusivement poursuivi le but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales qu'elle ou ses associés auraient, en l'absence de cet acte, normalement supportés.

4. En premier lieu, le ministre soutient que l'opération de cession de l'usufruit temporaire constitue un abus de droit au regard de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle constitue un montage juridique et économique artificiel organisé au bénéfice des associés de la SCI Kerjoany, agissant de concert dans le cadre d'une communauté familiale dans le but exclusif de leur permettre d'obtenir l'avantage fiscal résultant de l'application littérale des dispositions du I de l'article 150 VC du code général des impôts auquel ils ne pouvaient normalement prétendre de la perception par la SCI, dans le cadre du bail commercial, de loyers producteurs de revenus fonciers imposables, en vertu de l'article 8 du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales aux noms de leurs foyers fiscaux.

5. En vertu du I de l'article 150 VC du code général des impôts, la plus-value brute réalisée sur la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. Si, du fait de la détention de la pleine propriété, y compris l'usufruit, depuis une période de plus de quinze ans, M. et Mme B...ont bénéficié d'une exonération de plus-value sur la cession de l'usufruit temporaire, d'une part, cette cession a produit des effets économiques et juridiques distincts de la signature ou la poursuite d'un contrat de bail dès lors que la SCI a reçu immédiatement un prix de cession ferme et définitif, et non des loyers échelonnés sur une période de quinze ans, susceptibles d'être interrompus en cas de cessation d'activité, et qu'elle l'a immédiatement partagé entre ses associés, sans que le montant du prix de cession, surévalué selon l'administration, puisse être utilement invoqué aux fins de la démonstration de la poursuite d'un but exclusivement fiscal par la SCI. D'autre part, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que ce bénéfice était contraire aux objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a institué cet avantage par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

6. En second lieu, le ministre soutient que l'opération constitue un abus de droit au regard de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle relève d'une situation de fictivité juridique du fait de son économie générale compte tenu notamment d'un prix de cession manifestement surévalué, de l'absence d'intérêt économique avéré pour les deux sociétés et de la substitution du droit temporaire d'usufruit au bail commercial alors en cours sans modification significative sur le droit de la SAS d'utiliser l'immeuble pour son exploitation.

7. Toutefois, le ministre n'établit pas, ni même n'allègue, que l'opération n'a pas eu pour effet de transférer effectivement l'usufruit temporaire de la propriété du bâtiment avec l'ensemble des obligations en résultant dans le cadre de l'acte de cession qui prévoit, notamment la prise en charge par l'usufruitier des grosses réparations. Les seuls éléments dont il se prévaut, à les supposer même avérés, et notamment l'existence d'un prix surévalué, ne sont pas de nature à établir sa fictivité.

Sur l'existence d'un avantage occulte :

8. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse suivie devant le juge de l'impôt, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée.

9. Le ministre demande à la cour de substituer aux dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales celles du c de l'article 111 du code général des impôts à hauteur de 251 556 euros. Il soutient que le prix d'acquisition de l'usufruit temporaire a été fixé à 1 300 000 euros alors qu'il doit être évalué à 796 887 euros et que la SAS Le Gall Plafonds a ainsi consenti un avantage occulte aux associés de la SCI Kerjoany à hauteur de 503 113 euros, imposable pour moitié, soit 251 556 euros, chez M. et Mme B..., à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sur le fondement de ce c de l'article 111 sans que M. et Mme B...soient privés d'aucune garantie. Le ministre demande également d'imposer cette somme aux contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine sur le fondement des articles 1600-0 C et suivants du même code mais ne sollicite pas, par ailleurs, de substitution de base légale au titre des pénalités de 80 % infligées.

10. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...). ». En cas d'acquisition par des personnes distinctes de l'usufruit et de la nue-propriété du même bien immobilier, le caractère délibérément majoré du prix payé pour l'acquisition de l'usufruit temporaire par rapport à la valeur vénale de cet usufruit, sans que cet écart de prix comporte pour l'usufruitier de contrepartie, révèle l'existence, au profit du nu-propriétaire,

d'une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale de l'usufruit et, d'autre part, s'agissant des parties au démembrement du droit de propriété, de l'intention de l'usufruitier d'octroyer, et pour le nu-propriétaire, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de l'acquisition du bien. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

11. Par ailleurs, en l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale doit être faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue.

12. Il résulte de la proposition de rectification du 15 octobre 2012 adressée à la SCI Kerjoany et jointe à celle notifiée à M. et Mme B..., qu'au cours des opérations de contrôle sur place, cette société n'a pas répondu à la demande, formulée dans le courrier remis en main propre le 5 septembre 2012 à ce dernier, de justifier le calcul détaillé du montant de la cession temporaire d'usufruit. Il résulte du même document que la valeur de l'usufruit temporaire du bien immobilier concerné, fixée à 1 300 000 euros, correspond à 46 % d'une valeur en pleine propriété de 2 826 087 euros, à raison de 23 % par tranche de dix ans, par application du mode de calcul prévu au II de l'article 669 du code général des impôts applicable en matière de droits d'enregistrement, ce qui, selon le service, représente une valeur de pleine propriété 3,37 fois plus élevée que celle de biens comparables mentionnés en annexe. Pour retenir finalement une valeur de 796 887 euros pour l'usufruit temporaire, le ministre, qui ne se prévaut toutefois d'aucune transaction même équivalente, se fonde sur la méthode dite des « cash flow actualisés » consistant à capitaliser puis actualiser les flux de loyers raisonnablement attendus sur toute la période de l'usufruit. Pour l'application de cette méthode, il a retenu, d'une part, un revenu annuel net d'impôt de 93 100 euros compte tenu d'un montant de loyer brut attendu de 133 000 euros et d'un taux moyen d'imposition fixé à 30 % et, d'autre part, l'application d'un taux d'actualisation de 8 % intégrant un taux sans risque et une prime de risque, l'actualisation des flux de loyers étant réalisée sur une période de quinze ans, soit un coefficient multiplicateur de 8,559479.

13. Il résulte de l'instruction que le montant de 133 000 euros retenu par le ministre est celui dont se prévalent M. et Mme B... eux-mêmes au travers du rapport d'expert établi le 29 juin 2017 qu'ils ont produit. Contrairement à ce que font valoir M. et Mme B..., en se bornant à faire état de la doctrine administrative figurant au BOI-ENR-DMTOI-10-10-20-40 publié le 12 septembre 2012, laquelle concerne les droits d'enregistrement et n'est donc pas applicable en tout état de cause, le ministre était en droit de prendre en compte un revenu net d'impôt afin de déterminer le flux de trésorerie sans qu'ils critiquent sérieusement le taux de 30 % d'imposition retenu au vu des revenus « des associés dans la SCI ». Par ailleurs, M. et Mme B...ne critiquent pas le taux de 8 % d'actualisation retenu par le ministre et destiné à tenir compte des aléas inhérents à la perception future des loyers, lequel est celui arrêté par l'expert. En revanche, pour déterminer le revenu attendu sur quinze ans, il incombait au ministre de prendre en compte l'indexation du loyer sur l'indice du coût de la construction telle que prévue par l'avenant n° 2 au bail signé le 10 mars 1998 et que l'expert a évaluée, sans que cela soit contesté, à 1,5 % par an sur l'ensemble de la période, sans que ce taux se confonde avec celui de l'inflation contrairement à ce qui est soutenu. Compte tenu de ce taux, la valeur vénale de l'usufruit doit être évaluée à la somme de 867 799 euros. Dans ces conditions, il existait un écart significatif entre le prix convenu, soit 1 300 000 euros, et cette valeur vénale de l'usufruit. Par ailleurs, M. et Mme B...n'apportent aucun élément de nature à renverser la présomption d'intention libérale créée par les liens familiaux unissant M. et Mme A...B..., associés co-gérants de la SCI Kerjoany, et M. C...B..., gérant de la SAS Le Gall Plafonds et au surplus associé de la SCI. Il en résulte que la somme de 432 201 euros revêt le caractère d'un avantage occulte au bénéfice des associés de la SCI Kerjoany, imposable sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts à hauteur de la moitié, soit 216 100 euros, au foyer fiscal de M. et Mme B....

14. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la substitution de base légale sollicitée par le ministre serait de nature à priver M. et Mme B...d'une garantie de procédure. Il en va notamment ainsi, contrairement à ce qu'ils font valoir, de la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation dès lors qu'en vertu de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, celle-ci n'est compétente qu'en cas d'insuffisance des prix ou

évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune, et non pas en matière d'impôt sur le revenu.

15. Il résulte des points 8 à 14 du présent arrêt que le ministre est fondé à demander une substitution de base légale à hauteur, en base, de la somme de 216 000 euros, au titre de l'impôt sur le revenu. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les contributions sociales peuvent être imposées sur le fondement des articles 1600 et suivants du code général des impôts sans que M. et Mme B... soient davantage privés d'une garantie de procédure.

16. Il résulte de tout ce que précède que le ministre chargé des finances est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé M. et Mme B..., en droits et intérêt de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge pour l'année 2009 à hauteur des sommes correspondant à une base de 216 100 euros.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 216 100 euros est réintégrée dans la base imposable de M. et Mme B... au titre de l'année 2009 à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires correspondant au rétablissement mentionné à l'article 1er sont remises à la charge de M. et Mme B... en droits et intérêts de retard.

Article 3 : Le jugement du 26 octobre 2016 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre de l'action et des comptes publics et de celles de M. et Mme B... sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C.... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

A 10 - Cession d'usufruit - évaluation (cass. com. 26 septembre 2018, n° 16.26503)

Cass. com. 26 septembre 2018, n° 16.26503, publié au bulletin

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016), que par acte du 10 décembre 2010, la société civile immobilière Placimmo, ayant pour gérant M. Z..., a acquis auprès de la société civile immobilière Les Lys, dirigée par Mme Z..., l'usufruit d'un ensemble immobilier, lequel devait s'éteindre au décès du survivant de M. ou Mme Z... ; que le conservateur des hypothèques a refusé l'enregistrement de l'acte de cession, au motif que les droits de mutation devaient être évalués en considération du prix de cession et non sur la base d'un pourcentage de la valeur de l'immeuble cédé en pleine propriété conformément à l'article 669 I du code général des impôts ; que la société Placimmo, après s'être acquittée du supplément de droits exigés, en a demandé le remboursement puis, après rejet de sa réclamation, a saisi le tribunal de grande instance aux mêmes fins ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Placimmo alors, selon le moyen :

1°/ que pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, l'article 669 I du code général des impôts prévoit que la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après ; que ledit barème énumère les quotités à retenir pour la valeur de l'usufruit et la valeur de la nue-propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier ; que cette règle issue de la loi du 25 février 1901 et initialement destinée aux taxations des seules mutations à titre gratuit avait pour but de prendre en compte l'âge de l'usufruitier pour apprécier la valeur du démembrement de propriété dont allait bénéficier celui-ci ; que la notion d'âge de l'usufruitier ne peut concerner à l'évidence qu'une personne physique ; que la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, bien qu'élargissant ce principe d'évaluation légale à toutes les mutations, et modifiant les pourcentages à appliquer, a conservé le principe d'une évaluation en fonction de l'âge de l'usufruitier ; qu'ainsi le I de l'article 669 du code général des impôts est destiné exclusivement aux mutations d'usufruit dont les détenteurs sont des personnes physiques ; qu'en jugeant néanmoins que l'article 669 du code général des impôts, que ce soit dans son premier ou son second terme, ne distingue nullement entre personnes physiques et morales, la cour d'appel a fait une interprétation erronée de ce texte violant ainsi ses dispositions ;

2°/ qu'aux termes des dispositions impératives de l'article 619 du code civil, l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans ; que compte tenu du caractère d'ordre public de ce texte, il n'est pas possible d'y déroger par des dispositions conventionnelles ; que par voie de conséquence, l'usufruit cédé à une personne morale pour la durée de la survivance d'une personne physique ne peut être plus long que trente ans ; qu'un tel usufruit n'est donc pas un usufruit viager mais un usufruit à durée fixe dont le terme est incertain ; qu'en jugeant cependant que le fait que cet usufruit devait s'éteindre au delà de trente ans n'a pour la question de l'espèce aucune portée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 619 du code civil par refus d'application ;

3°/ que, pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, l'article 669-II du code général des impôts prévoit que l'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier ; qu'en application de l'article 619 du code civil, l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans ; qu'un tel usufruit qui concerne donc les personnes morales et qui a une durée maximum fixée à trente ans, ne peut être un usufruit viager et est donc un usufruit à durée fixe ; que le fait d'établir un tel usufruit sur la survivance d'un tiers, personne physique ne peut avoir pour conséquence de prolonger le délai de trente ans prévu par l'article 619 du code civil, ni de transformer l'usufruit à durée fixe en usufruit viager ; que pour calculer l'assiette des droits de mutation dus sur la vente d'un tel usufruit, il convient de faire application des dispositions de l'article 669 II précité ; qu'en jugeant néanmoins que la liquidation des droits d'enregistrement entre la société Placimmo et la société Les Lys relève de l'article 669 I et non du II de ce texte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 669 II par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 669 du code général des impôts, que ce soit en son premier ou son second paragraphe, ne distingue pas entre personnes physiques et morales pour l'évaluation de l'usufruit, l'arrêt retient que l'application du paragraphe I n'est pas réservée aux cessions de droits démembrés entre personnes physiques ; qu'il en déduit exactement que la liquidation des droits d'enregistrement afférents à la cession intervenue entre les sociétés Placimmo et Les Lys est soumise aux dispositions de l'article 669 I du code général des impôts, dès lors que l'usufruit, qui n'est cédé que pour la durée de la survivance de M. ou de Mme Z..., est de nature viagère, peu important que cet usufruit entre personnes morales ne puisse excéder trente ans aux termes de l'article 619 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société civile immobilière Placimmo la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en déclarant infondé le rejet par lettre du 31 janvier 2012 de la réclamation de la société Placimmo et condamné la Direction générale des finances publiques à restituer à la société Placimmo la somme de 88 057 euros versée le 2 février 2011, au titre des droits d'enregistrement relatifs à la cession du 10 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE,

Sur le texte applicable au calcul des droits de mutation

en application de l'article 669-I du code général des impôts « Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème [prévu par ce texte] » ; qu'en vertu du II de ce texte « L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier » ; qu'en l'espèce, la société Les Lys a cédé à la société Placimmo l'usufruit d'un ensemble immobilier et il est prévu par l'acte de cession que le droit d'usufruit s'éteindra au décès du survivant de M. ou Mme Z..., le premier étant gérant de la société Placimmo et la seconde gérante de la société Les Lys ; qu'il est exact que la cession s'est opérée entre personnes morales et que l'usufruit cédé ne l'étant que pour une durée de la survivance de M. ou Mme Z..., est de nature viagère, sans qu'importe que ce viager ne soit pas lié aux personnes morales, mais aux personnes physiques qui en sont associées ; que contrairement à ce que soutient l'Administration et ont retenu les premiers juges, l'article 669 du code général des impôts, que ce soit dans son premier ou son second terme, ne distingue nullement entre personnes physiques ou morales ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des travaux parlementaires ayant conduit à la réforme de ce texte et produits aux débats qu'il aurait été dans l'intention du législateur de réserver l'application du I aux cessions de droits démembrés entre personnes physiques ; que par ailleurs, il ne saurait être déduit de l'article 619 du code civil qui prévoit que l'usufruit entre personnes morales ne dure que trente ans, que l'usufruit cédé en l'espèce doive être considéré comme d'une durée de trente ans ; que le fait que cet usufruit doive s'éteindre au-delà de cette durée n'a pour la question de l'espèce aucune portée ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la société Placimmo soutient que la liquidation des droits d'enregistrement de la cession intervenue entre elle et la société les Lys relève de l'article 669 I et non du II de ce texte ;

Sur le montant des droits de mutation

que l'administration ne conteste pas que l'article 669 du code général des impôts qui constitue un texte spécial prime sur l'article 683 du même code qui a une portée générale, ce qui ressort d'ailleurs de la doctrine administrative ; que, compte tenu de ce qui a été retenu précédemment sur l'assiette du calcul des droits, elle n'est pas fondée à soutenir que celle-ci doive être déterminée par application du II de l'article 669 du code général des impôts, que c'est en conséquence à juste titre que la société Placimmo a calculé les droits dus par elle au titre de la mutation de l'usufruit par application du barème figurant à l'article 669 du code général des impôts comme s'élevant à la somme de 122 160 euros et qu'elle réclame la restitution de la différence entre cette somme et celle qu'elle a payée soit 88 057 euros (210 217 – 122 160) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, l'article 669 I du code général des impôts prévoit que la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après ; que ledit barème énumère les quotités à retenir pour la valeur de l'usufruit et la valeur de la nue-propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier ; que cette règle issue de la loi du 25 février 1901 et initialement destinée aux taxations des seules mutations à titre gratuit avait pour but de prendre en compte l'âge de l'usufruitier pour apprécier la valeur du démembrement de propriété dont allait bénéficier celui-ci ; que la notion d'âge de l'usufruitier ne peut concerner à l'évidence qu'une personne physique ; que la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, bien qu'élargissant ce principe d'évaluation légale à toutes les mutations, et modifiant les pourcentages à appliquer, a conservé le principe d'une évaluation en fonction de l'âge de l'usufruitier ; qu'ainsi le I de l'article 669 du code général des impôts est destiné exclusivement aux mutations d'usufruit dont les détenteurs sont des personnes physiques ;

qu'en jugeant néanmoins que l'article 669 du code général des impôts, que ce soit dans son premier ou son second terme, ne distingue nullement entre personnes physiques et morales, la cour d'appel de Paris a fait une interprétation erronée de ce texte violant ainsi ses dispositions ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, aux termes des dispositions impératives de l'article 619 du code civil, l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans ; que, compte tenu du caractère d'ordre public de ce texte, il n'est pas possible d'y déroger par des dispositions conventionnelles ; que, par voie de conséquence l'usufruit cédé à une personne morale pour la durée de la survivance d'une personne physique ne peut être plus long que trente ans ; qu'un tel usufruit n'est donc pas un usufruit viager, mais un usufruit à durée fixe dont le terme est incertain ; en jugeant cependant que le fait que cet usufruit doive s'éteindre au-delà de trente ans n'a pour la question de l'espèce aucune portée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 619 du code civil par refus d'application ;

ET ALORS ENFIN QUE, pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, l'article 669-II du code général des impôts prévoit que l'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier ; qu'en application de l'article 619 du code civil, l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans ; qu'un tel usufruit qui concerne donc les personnes morales et qui a une durée maximum fixée à trente ans, ne peut être un usufruit viager et est donc un usufruit à durée fixe ; que le fait d'établir un tel usufruit sur la survivance d'un tiers, personne physique ne peut avoir pour conséquence de prolonger le délai de trente ans prévu par l'article 619 du code civil, ni de transformer l'usufruit à durée fixe en usufruit viager ; que pour calculer l'assiette des droits de mutation dus sur la vente d'un tel usufruit, il convient de faire application des dispositions de l'article 669 II précité ; qu'en jugeant néanmoins que la liquidation des droits d'enregistrement entre la société Placimmo et la société Les Lys relève de l'article 669 I et non du II de ce texte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 669 II par refus d'application ;

A 11 - Acquisition par des personnes distinctes de l'usufruit temporaire et de la nue-propriété d'un immeuble : modalités de preuve d'une surévaluation de la valeur de l'usufruit (CE 24 octobre 2018, n° 412322)

CE 24 octobre 2018, n° 412322, Inédit au recueil Lebon, 8e et 3e chambres réunies

Vu 1°, sous le n° 412322, la procédure suivante :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1201627 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 15NC02357 du 11 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.

Vu 2°, sous le n° 412323, la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1201626 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 15NC02356 du 11 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

-le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

-les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.C....

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société civile Sacajisme, soumise à l'impôt sur les sociétés, et la société civile immobilière (SCI) Sacaj, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, ont acquis, par acte du 4 septembre 2008, respectivement l'usufruit, pour une durée de vingt-deux années, et la nue-propriété d'un immeuble sis 13 rue Tronchet à Paris pour un prix total de 730 000 euros. À l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Sacajisme, l'administration a estimé que le prix de 645 000 euros qu'elle avait acquitté pour acquérir l'usufruit excédait de 145 000 euros la valeur de celui-ci et que l'excédent de prix ainsi consenti constituait une libéralité accordée à la SCI Sacaj, nue-propriétaire. En conséquence, Mme B... et M. C..., associés à parts égales de la SCI Sacaj et associés par ailleurs à parts inégales de la société Sacajisme, ont été imposés, au titre de l'année 2008, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, à raison des revenus distribués correspondant à cette libéralité retenue par administration. Par des jugements du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur demande respectivement de Mme B...et de M. C..., prononcé la décharge des impositions litigieuses. Par des arrêts du 11 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les recours du ministre des finances et des comptes publics contre ces jugements. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ces arrêts.

3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ».

4. En cas d'acquisition par des personnes distinctes de l'usufruit temporaire et de la nue-propriété du même bien immobilier, le caractère délibérément majoré du prix payé pour l'acquisition de l'usufruit temporaire par rapport à la valeur vénale de cet usufruit, sans que cet écart de prix ne comporte pour l'usufruitier de contrepartie, révèle, en ce qu'elle conduit à une minoration à due concurrence du prix acquitté par le nu-propriétaire pour acquérir la nue-propriété par rapport à la valeur vénale de celle-ci, l'existence, au profit du nu-propriétaire, d'une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre les prix convenus et les valeurs vénales respectives de l'usufruit et de la nue-propriété, d'autre part, s'agissant des parties au démembrement du droit de propriété, de l'intention de l'usufruitier d'octroyer, et pour le nu-propriétaire, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de l'acquisition dudit bien.

5. En l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale doit être faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où l'acquisition est intervenue. Dans le cas de l'acquisition d'un bien en démembrement de propriété, constitue une telle méthode d'évaluation celle qui définit des prix de la nue-propriété et de l'usufruit tels qu'ils offrent le même taux de rendement interne de l'investissement pour l'usufruitier et le nu-propriétaire.

6. Pour déduire des faits qu'elle a souverainement appréciés que l'administration n'apportait pas la preuve d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale de l'usufruit de l'immeuble litigieux, la cour administrative d'appel a jugé, premièrement, que la méthode de valorisation de l'usufruit proposée par l'administration, fondée sur la somme actualisée des revenus futurs de l'immeuble, n'était pas davantage pertinente que celle employée par les parties à l'acte d'acquisition, dès lors que le taux de rentabilité fixe retenu par l'administration n'était pas à même de tenir compte de l'inflation des loyers, que, deuxièmement, était sans incidence sur la pertinence de la méthode retenue par les sociétés Sacajisme et Sacaj la circonstance que son application était susceptible de conduire à une évaluation de l'usufruit supérieure à 100 % du prix d'acquisition de l'immeuble, dès lors que la valeur vénale de sa pleine propriété serait différente à la date d'extinction de l'usufruit, et, troisièmement, que la circonstance que l'intérêt financier de la SCI Sacaj à recevoir le bien en pleine propriété au terme de l'usufruit serait sans commune mesure avec le coût supporté par elle pour l'acquisition de la nue-propriété ne démontrait pas la surévaluation de l'usufruit.

7. La cour administrative d'appel a ainsi écarté la méthode d'évaluation de l'administration au motif qu'elle n'aurait pas tenu compte de l'augmentation annuelle des loyers du fait de l'inflation, alors que cette méthode déterminait de manière cohérente la valeur vénale de l'usufruit par différence entre la valeur de pleine propriété à la date de l'opération et la valeur actualisée à cette même date de la pleine propriété obtenue à l'extinction de l'usufruit en appliquant un taux d'actualisation égal au taux de rendement de l'investissement immobilier, indépendamment de l'inflation. Elle a regardé comme plus pertinente la méthode d'évaluation employée par les sociétés Sacajisme et Sacaj qui déterminait la valeur vénale de l'usufruit à partir de la somme actualisée des loyers futurs pour la durée de l'usufruit temporaire, exprimés en valeur nominale et donc en prenant en compte l'inflation, tout en appliquant un taux d'actualisation ne prenant pas en compte l'inflation. Or une telle méthode repose sur des termes de calcul non homogènes et conduit par suite à une rentabilité interne de l'investissement déséquilibrée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire et à un partage inexact, à la date de la cession, de la valeur en pleine propriété de l'immeuble entre celle de l'usufruit et celle de la nue-propriété, cette méthode erronée ayant pour conséquence que la somme de la valeur ainsi déterminée de l'usufruit et de la valeur vénale de la nue-propriété soit supérieure au prix d'acquisition de la pleine propriété. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé, par le moyen d'erreur de droit qu'il invoque, qui, contrairement à ce que M. C...soutient en défense, n'est pas irrecevable, à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy du 11 mai 2017 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics, à Mme D... B... et à M. A... C....

A 12 - Levée d'option d'un contrat de crédit-bail (CAA Marseille 11 décembre 2018, n° 17MA02433)

CAA Marseille 11 décembre 2018, n° 17MA02433, 4e chambre, formation à 3

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503696 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2017, le 27 novembre 2017 et le 20 décembre 2017, M. A..., représenté par Me C.... , demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-en l'absence de réponse dans un délai de soixante jours à compter de la réception de ses observations à la proposition de rectification en date du 24 juillet 2012, l'administration doit être regardée comme ayant accepté ses observations, en application de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;

-il n'a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

-la SCI USII n'était pas tenue de constater une plus-value imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à l'issue de la levée de l'option d'achat des immeubles qu'elle prenait en crédit-bail, dès lors qu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés détenait l'usufruit de son capital ;

-à titre subsidiaire, la plus-value n'était imposable qu'entre les mains de l'usufruitier ;

-à titre subsidiaire, cette plus-value n'a pas de contrepartie financière équivalente ;

-à titre subsidiaire, l'imposition de la plus-value demeure possible en application de la situation de la société post-restructuration ; -

-à titre subsidiaire, la plus-value afférente à la cession ultérieure d'une partie des biens acquis dans le cadre de la levée d'option a été déclarée et imposée ; -

-c'est à tort que le tribunal administratif a regardé l'article 28 des statuts de la SCI USII comme une clause réputée non écrite sur le fondement de l'article 1844-1 du code civil ;

-l'administration ne pouvait remettre en cause la répartition statutaire du profit exceptionnel constitué par la plus-value résultant de la levée de l'option d'achat des immeubles que la SCI USII prenait en crédit-bail sur le fondement de la théorie de l'abus de droit ;

-c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la majoration pour manœuvres frauduleuses était applicable ;

-la majoration pour abus de droit doit être ramenée à 40 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il demande également, par la voie de l'appel incident, que la Cour juge que la majoration pour abus de droit initialement appliquée est régulière.

Il soutient que :

-les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;

-l'application de la majoration pour abus de droit au taux de 80 % est justifiée dès lors que la société et ses associés ont été à l'initiative des actes constitutifs du montage abusif et qu'ils en ont été les principaux bénéficiaires.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a procédé d'office à la substitution de la majoration pour manœuvres frauduleuses à la majoration pour abus de droit et de l'irrecevabilité des conclusions du ministre de l'action et des comptes publics, présentées par la voie de l'appel incident, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de constater la régularité de l'application de pénalités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code civil ;

-le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4e chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Mastrantuono,

-les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

-et les observations de Me D..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Union Service Immobilier Industriel (USII), dont M. A... était associé, a conclu en 1997 un contrat de crédit-bail avec la société Slibailmurs, devenue Finamur, pour l'acquisition et le financement d'un terrain situé à la Farlède, sur lequel a été édifié un ensemble immobilier à usage de casse automobile, que la société civile a donné en sous-location à la SARL Société de Distribution Mécanique et Métallique (SDMM). À la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile, l'administration a estimé que la levée d'option, le 13 octobre 2010, de ce contrat de crédit-bail, avait entraîné un changement de nature de l'activité exercée, la société mettant désormais l'immeuble en location au lieu de le donner en sous-location. L'administration a, en conséquence, réintégré dans le résultat de la société civile la plus-value résultant de ce changement d'activité. Elle a tiré les conséquences de cette rectification à l'égard de M. A... à l'issue d'un contrôle sur pièces, en imposant entre ses mains la plus-value à hauteur de sa quote-part dans le capital de la société, après avoir écarté comme ne lui étant pas opposable la répartition des bénéfices exceptionnels résultant des statuts de la SCI USII entre les nus-propriétaires des parts du capital de la société, dont M. A... faisait partie, et l'usufruitier. M. A... fait appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été ainsi assujetti au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes.

Sur l'appel principal de M. A... :

2. L'article L. 64 du livre des procédures fiscales dispose que : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou

de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (...) ».

3. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. / (...) 6. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article (...) ». L'article 93 quater du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. / (...) III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. / IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution (...) ».

4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 5 août 2010, les parts composant le capital de la SCI USII étaient détenues en pleine propriété à hauteur de 51 % par Mme A..., la mère du requérant, qui détenait également l'usufruit du surplus, alors que ses deux fils en détenaient la nue-propriété. À l'issue d'opérations de donations, d'apports et de cession intervenues entre le 5 août et le 27 septembre 2010, la SARL SDMM, dont le capital était également détenu par Mme A... et ses deux fils, est devenue titulaire de l'usufruit temporaire des parts de la SCI USII, la nue-propriété des parts étant répartie entre Mme A... et ses deux fils. Le 27 septembre 2010, l'article 28 des statuts de la SCI USII a été modifié afin de prévoir que les bénéfices exceptionnels résultant notamment de la cession d'éléments d'actifs immobilisés seraient répartis entre usufruitiers et nus-propriétaires à hauteur de 40 % aux usufruitiers et 60 % aux nus-propriétaires.

5. L'administration a estimé que ces opérations étaient constitutives d'un abus de droit en se fondant sur la proximité temporelle entre, d'une part, le démembrement de la propriété d'une partie des parts de capital de la SCI USII, la transmission de l'usufruit temporaire de ces parts à la SARL SDMM, la modification des statuts de la SCI et, d'autre part, la levée d'option du crédit-bail, la sous-valorisation de l'usufruit temporaire des parts de la SCI, les incohérences juridiques résultant de la modification statutaire de la répartition de ses profits exceptionnels et le but fiscal des opérations, tant en ce qui concerne Mme A... et ses fils que la SARL SDMM. Elle a en conséquence considéré qu'à l'issue de la levée d'option, le 13 octobre 2010, du contrat de crédit-bail conclu en 1997 par la SCI USII, la plus-value susceptible d'avoir été acquise à cette date en raison de la cessation de l'activité initiale de la SCI et du changement de son régime fiscal, faute de demande de report d'imposition, était imposable en totalité entre les mains de Mme A... et de ses deux fils. Toutefois, le requérant soutient que l'augmentation de capital de la SARL SDMM décidée en vue d'attribuer à Mme A... et à son fils des parts en rémunération de l'apport de l'usufruit temporaire des parts de la SCI a conduit à un renforcement des fonds propres de la SARL nécessaire à la continuité de son exploitation et que le produit de la cession ultérieure des parcelles a été réinvesti dans l'activité de cette société, permettant d'assurer sa survie, sans être sérieusement contredit en ce qui concerne les difficultés économiques de la SARL SDMM. Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que les opérations en cause n'ont pu être inspirées par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales des associés de la SCI USII.

6. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été ainsi assujetti au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes. Sur l'appel incident du ministre :

7. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de constater la régularité de l'application de pénalités. Par suite, les conclusions du ministre de l'action et des comptes public tendant à ce que la Cour juge que la majoration pour abus de droit initialement appliquée est régulière sont irrecevables. Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017 est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 4 : L'État versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

A 13 - Avis rendu par le comité de l'abus de droit fiscal (séance au 14 février 2019)

DGFiP, Avis rendu par le comité de l'abus de droit fiscal, séance au 14 février 2019, affaire 2018/23, 2018/29, 2018/39, 2018/40

Affaire n° 2018-23 concernant la société A

La société A, constituée en 1998, a pour activité la fabrication, la vente et le négoce de supports publicitaires, l'impression sérigraphique et numérique ainsi que le marquage sur tout support publicitaire. M. X, associé et gérant, en détient depuis 2008 l'intégralité de son capital. Il détient également, depuis le partage de la communauté qu'il constituait avec son épouse, l'intégralité du capital de la société civile immobilière (SCI) B, société soumise à l'impôt sur les sociétés, propriétaire, dès sa constitution en 2001, d'un ensemble immobilier composé, d'une part, d'un local à usage d'atelier et de bureaux avec parking attenant pris à bail le 1er novembre 2008 par la société A et, d'autre part, d'une maison à usage d'habitation donnée en location depuis le 1er avril 2002 à un tiers.

Le 23 décembre 2013, la SCI B a procédé au démembrement de cet ensemble immobilier et en a cédé l'usufruit temporaire pour une durée de 17 ans à la société à responsabilité limitée (SARL) C, société créée six mois auparavant et détenue à hauteur de 99,9 % par la société A et de 0,1 % par M. X. La cession de cet usufruit temporaire a été réalisée au prix de 587 400 euros, payée immédiatement et financée par la société C au moyen d'un emprunt bancaire.

La SCI B a ensuite procédé à une distribution de dividendes à son associé unique, M. X, en deux temps :

-le 26 décembre 2013, distribution d'un dividende de 97 000 euros ;

-le 27 mars 2014, distribution d'un dividende de 142 600 euros, payé en nature par l'attribution de la nue-propriété des biens immobiliers précédemment démembrés.

Le 30 juin 2014, M. X a fait apport de 199 titres sur 200 (99,5 %) de la SCI B à la société A pour une valeur de 357 000 euros. En rémunération de cet apport, il s'est vu attribuer 357 parts sociales de la société A, nouvellement émises d'une valeur nominale unitaire de 32 euros (soit une augmentation de capital de 11 424 euros) et une prime d'émission de 345 576 euros. La plus-value d'apport chez M. X a bénéficié du régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts.

Le 1er juillet 2014, les associés de la SCI B ont décidé de la distribution par cette dernière d'un dividende global de 225 000 euros, dont 223 875 euros (99,5 %) au profit de la société A et 1 125 euros (0,5 %) au profit de M. X.

Le dividende de 223 875 euros perçu par la société A a été soumis au régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, avec taxation d'une seule quote-part de frais et charges de 5 %

Après ces opérations, le bilan de la société B, dont les titres ont été conservés par la société A, est principalement composé d'actifs financiers (trésorerie, valeurs mobilières de placement) pour un montant d'environ 75 000 euros.

Par la suite, la société A a attribué à M. X deux primes exceptionnelles, en sus de sa rémunération courante au titre de sa gérance fixée le 1er avril 2014 à 3 200 euros par mois outre la prise en charge des cotisations fiscales et sociales relatives à cette rémunération : une première prime de 150 000 euros le 30 septembre 2014 et une seconde prime de 125 350 euros décidée le 1er avril 2015 et payée en 6 versements entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016.

L'administration a, à l'issue de son contrôle de la société A, considéré que la mise en place de cette série d'opérations rapprochées dans le temps, consistant dans la cession de l'outil d'exploitation de la SCI B puis l'acquisition de ses parts par la société A suivie d'une distribution de dividendes le lendemain, n'avait été réalisée que dans le but exclusivement fiscal de dégager des liquidités en franchise d'impôt grâce à l'application du régime des sociétés mères, à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur.

Par une proposition de rectification du 29 août 2017, elle a, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, écarté l'application du régime des sociétés mères dont a bénéficié la société A et imposé le dividende versé par la SCI B à son profit.

Le Comité a entendu ensemble le contribuable, son conseil et le représentant de l'administration.

Le Comité relève que les différentes opérations concernant les sociétés A et B s'inscrivent dans le cadre de la restructuration du groupe de sociétés appartenant à M. X et qu'elles sont internes à ce groupe. Il constate qu'elles ont été effectuées notamment pour des raisons patrimoniales et estime qu'ainsi le but exclusivement fiscal n'est pas établi.

Le Comité en déduit que l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Nota : l'administration s'est rangée à l'avis émis par le comité.

Affaire n° 2018-29 concernant M. X

Par acte du 24 mars 2014, M. X a apporté à la société par actions simplifiée (SAS) A 81 250 titres de la société B et 81 250 titres de la société D.

En contrepartie de ces apports valorisés globalement à 11 073 000 euros, M. X a reçu de la société SAS A 11 073 000 actions, d'une valeur nominale d'un euro.

La plus-value résultant de cet apport a été placée en report d'imposition selon les dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.

Le 30 janvier 2015, M. X a apporté à la société C, dont il détient 99 % du capital, 10 422 720 actions de la société SAS A, représentant 94 % de son capital. En rémunération de cet apport, il a reçu de la société C 956 212 parts, d'une valeur nominale de 10 euros par part, émises par cette société dans le cadre d'une augmentation de son capital porté de 1 000 euros à 9 563 120 euros, ainsi qu'une soulte de 860 000 euros représentant 9 % de la valeur nominale des titres reçus. Cette somme a été inscrite au compte courant d'associé de M. X dans la société C.

La plus-value d'apport a été placée en report d'imposition, conformément aux dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts pour l'intégralité de son montant dès lors que la soulte ne dépassait pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a considéré que cette soulte était dépourvue de justification économique et dissimulait en réalité, sous couvert d'une opération d'échange de titres, la perception d'un dividende en franchise d'impôt. Elle a donc mis en œuvre, par une proposition de rectification en date du 9 décembre 2016, la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et a écarté la qualification de soulte et l'application à celle-ci du régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Elle a taxé, au titre de l'année 2015, la somme de 860 000 euros à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du même code ainsi 2 qu'à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales et a assorti les droits dus de la majoration pour abus de droit au taux de 80 %.

Le Comité a entendu ensemble le contribuable et son conseil ainsi que le représentant de l'administration.

Le Comité relève que le dispositif du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts poursuit la même finalité que le dispositif du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du même code. Ces dispositifs ont pour objectif de faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser le développement de celles-ci, en conférant un caractère intercalaire aux opérations d'échange de titres.

Le Comité estime que, si le législateur a admis, avant la modification législative introduite par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, que l'opération d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur bénéficie intégralement, y compris pour la soulte, du report d'imposition, dès lors que le montant de la soulte appréhendée par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l'octroi d'une telle soulte doit s'inscrire dans le respect du but qu'il a entendu poursuivre.

Le Comité considère que ce but n'est pas respecté si l'octroi de la soulte ne s'inscrit pas dans le cadre de l'opération de restructuration d'entreprise mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l'apporteur des titres d'appréhender en franchise immédiate d'impôt des liquidités détenues par la société dont les titres sont apportés et faisant ainsi l'objet d'un désinvestissement faute qu'il soit justifié que la société bénéficiaire de l'apport avait, afin de permettre le dénouement de l'opération, un intérêt économique au versement de cette soulte, alors que, lorsque cette soulte est ainsi financée, elle prive cette société de la possibilité de disposer de ressources nécessairement prises en compte lors de la détermination de la valeur des titres apportés.

Le Comité relève que M. X doit être regardé comme ayant bénéficié de la mise à disposition de la soulte litigieuse par inscription de son montant au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans la société C dont il détenait 99 % du capital, alors même qu'aucun prélèvement n'a été opéré.

Il note que l'argument selon lequel la soulte visait à indemniser l'apporteur de la perte de valeur liée à une décote de holding est en tout état de cause inopérant dès lors qu'une telle indemnisation ne présentait pas d'intérêt économique pour la société C pas plus qu'elle ne conditionnait la réalisation de l'opération d'échange de titres.

Il estime que, compte tenu de l'ensemble des éléments ainsi portés à sa connaissance, et en l'absence de toute justification probante de l'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport de prévoir le versement d'une soulte afin de rendre possible la réalisation de l'opération de restructuration effectuée entre des sociétés contrôlées par M. X, la mise à disposition de cette soulte sur le compte courant d'associé ne s'inscrit pas dans le respect du but poursuivi par le législateur au titre de la restructuration et du développement du groupe de M. X mais caractérise une appréhension de liquidités en franchise d'impôt, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance alléguée par le contribuable qu'aucun remboursement de cette soulte ne serait en réalité intervenu.

Le Comité émet en conséquence l'avis que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales pour restituer son véritable caractère de distribution à la mise à disposition de la soulte réalisée, à l'occasion d'un apport placé sous le régime de report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, au bénéfice d'une application littérale de ces dispositions allant à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but de disposer de cette somme en franchise d'imposition.

Enfin, le Comité estime que M. X doit être regardé comme ayant eu l'initiative principale des actes constitutifs de l'abus de droit et, en outre, comme en ayant été le principal bénéficiaire au sens du b) de l'article 1729 du code général des impôts. Il émet donc l'avis que l'administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions.

Nota : l'administration a pris note de l'avis émis par le comité.

Affaire n° 2018-39 concernant M. X

Le 30 septembre 2013, M. X a apporté à la société à responsabilité limitée (SARL) A, dont il est l'associé unique, 60 000 titres de la société B évalués à la somme de 12 960 000 euros. Il détient à parts égales avec ses deux sœurs le capital de cette société.

En rémunération de cet apport, il a reçu 11 782 parts, d'une valeur nominale de 1 000 euros par part, de la SARL A, valorisées à la somme de 11 782 000 euros, émises par cette société dans le cadre d'une augmentation de son capital, ainsi qu'une soulte de 1 178 000 euros représentant 9,998 % de la valeur nominale des titres reçus.

Dès le 11 juillet 2013, un compte courant d'associé au nom de M. X avait été ouvert dans la société A sous la dénomination « compte courant M. X bloqué » et la somme de 1 178 000 euros a été portée au crédit de ce compte sous le libellé « apport titres B soulte ».

La plus-value d'apport a été placée en report d'imposition, conformément aux dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts pour l'intégralité de son montant dès lors que la soulte ne dépassait pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

À l'issue de son contrôle, l'administration a considéré que cette soulte était dépourvue de justification économique et avait eu pour seul objectif d'éviter l'imposition immédiate d'une partie de la plus-value constatée lors de l'apport des titres de la société B à la SARL A. Elle a donc mis en œuvre, par une proposition de rectification en date du 20 décembre 2016, la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et a écarté la qualification de soulte et l'application à celle-ci du régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Elle a réintégré dans les revenus imposables dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières, au titre de l'année 2013, en application des dispositions de l'article 150-0 A du même code, une somme de 414 015 euros, correspondant à l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value placée en report d'imposition, correspondant à la soulte. Cette somme a été taxée à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales et l'administration a assorti les droits dus de la majoration pour abus de droit au taux de 80 %.

Le Comité a entendu ensemble le conseil du contribuable et le représentant de l'administration.

Le Comité relève que le dispositif du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts poursuit la même finalité que le dispositif du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du même code. Ces dispositifs ont pour objectif de faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser le développement de celles-ci, en conférant un caractère intercalaire aux opérations d'échange de titres.

Le Comité estime que, si le législateur a admis, avant la modification législative introduite par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, que l'opération d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur bénéficie intégralement, y compris pour la soulte, du report d'imposition, dès lors que le montant de la soulte appréhendée par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l'octroi d'une telle soulte doit s'inscrire dans le respect du but qu'il a entendu poursuivre.

Le Comité considère que ce but n'est pas respecté si l'octroi de la soulte ne s'inscrit pas dans le cadre de l'opération de restructuration d'entreprise mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l'apporteur des titres d'appréhender en franchise immédiate d'impôt des liquidités à raison de l'opération d'apport des titres, faute qu'il soit justifié que la société bénéficiaire de l'apport avait, afin de permettre le dénouement de l'opération, un intérêt économique au versement de cette soulte, alors que, lorsque cette soulte est ainsi versée, elle prive cette société de la possibilité de disposer de ressources nécessairement prises en compte lors de la détermination de la valeur des titres apportés.

Le Comité relève que M. X doit être regardé comme ayant bénéficié de la mise à disposition de la soulte litigieuse par inscription de son montant au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans la société A dont il était l'associé unique.

Il estime que, compte tenu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, et en l'absence de toute justification probante de l'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport de 4 prévoir le versement d'une soulte afin de rendre possible la réalisation de l'opération de restructuration entreprise, la mise à disposition de cette soulte sur le compte courant d'associé ne s'inscrit pas dans le respect du but poursuivi par le législateur au titre de la restructuration et du développement du groupe de M. X mais caractérise la volonté du contribuable d'appréhender immédiatement en franchise d'impôt une partie de la plus-value constatée lors de l'apport, sans qu'ait d'incidence à cet égard ni la circonstance alléguée par le contribuable qu'aucun remboursement de cette soulte ne serait en réalité intervenu, ni le fait qu'elle ait été inscrite à un compte courant d'associé bloqué.

Le Comité émet en conséquence l'avis que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales pour restituer son véritable caractère à la mise à disposition de la soulte réalisée, à l'occasion d'un apport placé sous le régime de report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, au bénéfice d'une application littérale de ces dispositions allant à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but de disposer de cette somme en franchise d'imposition.

Enfin, le Comité estime que M. X doit être regardé comme ayant eu l'initiative principale des actes constitutifs de l'abus de droit et, en outre, comme en ayant été le principal bénéficiaire au sens du b) de l'article 1729 du code général des impôts. Il émet donc l'avis que l'administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions.

Nota : l'administration a pris note de l'avis émis par le comité.

Affaire n° 2018-40 concernant Mme X

Le 22 mai 2014, Mme X a fait apport à la société à responsabilité limitée (SARL) A, dont elle est l'associée unique, de 60 000 titres de la société B évalués à la somme de 12 960 000 euros. Elle détient à parts égales avec son frère et sa sœur le capital de cette société.

En rémunération de cet apport, elle a reçu 11 782 parts, d'une valeur nominale de 1 000 euros par part, de la SARL A, valorisées à la somme de 11 782 000 euros, émises par cette société dans le cadre d'une augmentation de son capital, ainsi qu'une soulte de 1 178 000 euros, représentant 9,998 % de la valeur nominale des titres reçus, inscrite au compte courant d'associé ouvert à son nom dans la société A.

La plus-value d'apport a été placée en report d'imposition, conformément aux dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts pour l'intégralité de son montant dès lors que la soulte ne dépassait pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a considéré que cette soulte était dépourvue de justification économique et avait eu pour seul objectif d'éviter l'imposition immédiate d'une partie de la plus-value constatée lors de l'apport des titres de la société B à la SARL A. Elle a donc mis en œuvre, par une proposition de rectification en date du 9 février 2017, la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et a écarté la qualification de soulte et l'application à celle-ci du régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Elle a réintégré dans les revenus imposables dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières, au titre de l'année 2014, en application des dispositions de l'article 150-0 A du même code, une somme de 414 015 euros, correspondant à l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value placée en report d'imposition, correspondant à la soulte. Cette somme a été taxée à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales et l'administration a assorti les droits dus de la majoration pour abus de droit au taux de 80 %.

Le Comité a entendu ensemble le conseil de la contribuable et le représentant de l'administration.

Le Comité relève que le dispositif du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts poursuit la même finalité que le dispositif du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du même code. Ces dispositifs ont pour objectif de faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser le développement de celles-ci, en conférant un caractère intercalaire aux opérations d'échange de titres.

Le Comité estime que, si le législateur a admis, avant la modification législative introduite par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, que l'opération d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur bénéficie intégralement, y compris pour la soulte, du report d'imposition, dès lors que le montant de la soulte appréhendée par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l'octroi d'une telle soulte doit s'inscrire dans le respect du but qu'il a entendu poursuivre.

Le Comité considère que ce but n'est pas respecté si l'octroi de la soulte ne s'inscrit pas dans le cadre de l'opération de restructuration d'entreprise mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l'apporteur des titres d'appréhender en franchise immédiate d'impôt des liquidités à raison de l'opération d'apport des titres, faute qu'il soit justifié que la société bénéficiaire de l'apport avait, afin de permettre le dénouement de l'opération, un intérêt économique au versement de cette soulte, alors que, lorsque cette soulte est ainsi versée, elle prive cette société de la possibilité de disposer de ressources nécessairement prises en compte lors de la détermination de la valeur des titres apportés.

Le Comité relève que Mme X doit être regardée comme ayant bénéficié de la mise à disposition de la soulte litigieuse par inscription de son montant au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans la société A dont elle était l'associée unique.

Il estime que, compte tenu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, et en l'absence de toute justification probante de l'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport de prévoir le versement d'une soulte afin de rendre possible la réalisation de l'opération de restructuration entreprise, la mise à disposition de cette soulte sur le compte courant d'associé ne s'inscrit pas dans le respect du but poursuivi par le législateur au titre de la restructuration et du développement du groupe de Mme X mais caractérise la volonté de la contribuable d'appréhender immédiatement en franchise d'impôt une partie de la plus-value constatée lors de l'apport, sans qu'ait d'incidence à cet égard ni la circonstance alléguée par la contribuable qu'aucun remboursement de cette soulte ne serait en réalité intervenu, ni le fait qu'elle ait été inscrite à un compte courant d'associé ultérieurement bloqué.

Le Comité émet en conséquence l'avis que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales pour restituer son véritable caractère à la mise à disposition de la soulte réalisée, à l'occasion d'un apport placé sous le régime de report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, au bénéfice d'une application littérale de ces dispositions allant à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but de disposer de cette somme en franchise d'imposition.

Enfin, le Comité estime que Mme X doit être regardée comme ayant eu l'initiative principale des actes constitutifs de l'abus de droit et, en outre, comme en ayant été la principale bénéficiaire au sens du b) de l'article 1729 du code général des impôts. Il émet donc l'avis que l'administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions.

Nota : l'administration a pris note de l'avis émis par le comité.

A 14 - Valeur de l'usufruit temporaire (CA Orléans, 21 mars 2019, n° 18/005361)

Cour d'appel Orléans, 21 mars 2019, n° 18/005361, Chambre commerciale, économique et financière

Exposé du litige :

Le 6 octobre 2009, Monsieur W... V... et son épouse, Madame H... O..., ont constitué la SCI LBA qui a acquis, le 12 novembre 2009, un immeuble sis à Loches dans lequel la SAS HÔTEL-RESTAURANT LUCCOTEL, dont Monsieur V... était président, exploitait un hôtel-restaurant.

Le 28 décembre 2009, Monsieur et Madame V... ont cédé pour une durée de 20 ans à la société LUCCOTEL l'usufruit des 100 parts sociales qu'ils détenaient dans la SCI.

La valeur en pleine propriété de ces parts sociales a été fixée à 1 000 euros, de sorte que, par application des dispositions de l'article 669 II du code général des impôts, la valeur soumise à droits d'enregistrement a été arrêtée à 460 euros.

Le 17 décembre 2012, l'administration fiscale a établi un courrier dans lequel elle faisait connaître à la SAS que la valeur en pleine propriété des parts sociales devait être fixée à 7 619 euros par part, et en conséquence la valeur de l'usufruit temporaire à 3 810 euros par part, de sorte qu'était réclamé un complément de droits de 19 000 euros assorti de pénalités.

À la suite d'observations de la société, la valeur des parts sociales a été arrêtée à 5 079 euros et la mise en recouvrement du complément de droits a été opérée pour un montant réduit à 11 630 euros majorés de 1 628 euros de pénalités, soit un total de 13 258 euros.

Contestant ce redressement, la société LUCCOTEL a, le 9 décembre 2015, saisi le tribunal de grande instance de Tours en sollicitant la décharge de l'imposition. Elle a d'une part fait état de la prescription intervenue, d'autre part contesté la valorisation des parts sociales réalisée par l'administration fiscale.

Par jugement en date du 12 décembre 2017, le tribunal a fait droit à la demande de décharge en retenant que l'administration des finances publiques était prescrite dans l'exercice de son droit de reprise.

L'administration des finances publiques a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 mai 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter Monsieur et Madame V... de toutes leurs prétentions, de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros et de condamner les intimés aux dépens dont distraction au profit de Maître GARNIER.

Elle fait valoir qu'elle disposait, pour exercer son droit de reprise, d'un délai qui expirait le 31 décembre 2012 ; qu'elle a adressé à la société LUCCOTEL le 17 décembre 2012 une proposition de rectification ; que ce courrier a été présenté le 19 décembre 2012, ce qui suffit pour interrompre le délai de prescription, peu important que la lettre n'ait effectivement été distribuée à l'intimée que le 2 janvier 2013.

Elle expose la valorisation des parts sociales à laquelle elle a procédé en faisant valoir qu'en application des articles 666 et 726 du code général des impôts, la base de perception des droits d'enregistrement est constituée par le prix exprimé dans l'acte, augmenté de toutes les charges en capital et de toutes les indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que se soit ; que la Cour de cassation retient que la valeur vénale des parts doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande et n'impose pas à l'administration le choix d'une méthode particulière de valorisation ; qu'elle exige uniquement que la ou les méthodes retenues soient justifiées au regard des caractéristiques et des spécificités des titres à évaluer ; que la jurisprudence procède habituellement à une évaluation combinant plusieurs méthodes ; qu'elle a procédé à un calcul combinant la valeur mathématique et la valeur de productivité ; que cette méthode, qui est celle usuellement appliquée pour la valorisation des parts de SCI, n'est pas contestée par l'intimée qui est également d'accord avec la valeur mathématique mais se trompe quant à la valeur de productivité.

Elle fait valoir que cette dernière est en effet obtenue par capitalisation du résultat net d'impôt de l'entreprise, qu'il soit distribué ou mis en réserve, suivant l'hypothèse d'une rente infinie du bénéfice dégagé selon la formule : VP (valeur de productivité) = revenu/taux de capitalisation ; qu'il existe une communauté d'intérêts entre les cédants et la cessionnaire qui explique la différence entre la valeur vénale qu'elle a retenue et le prix de cession, ce qui établit l'existence d'une libéralité consentie au profit de LUCCOTEL ; que, pour évaluer cette libéralité, elle a retenu, dans son calcul, le revenu dont aurait bénéficié le cédant en l'absence de cession temporaire d'usufruit,

soit le revenu de la SCI LBA déterminé selon les règles des revenus fonciers, estimé a minima à 76 190 euros, montant auquel elle a appliqué une décote de 33 1/3 % représentative d'un impôt sur les sociétés théorique au taux plein, soit un montant retenu comme base de calcul de 50 793 euros ; qu'elle a appliqué un taux de capitalisation de 5 % en fonction d'un taux couvrant l'inflation d'une part et d'autre part d'une prime de risque modique et elle rappelle que le taux de capitalisation généralement admis varie entre 5 et 7 % ; qu'elle a combiné les deux méthodes mathématique et de productivité par moitié en prenant en compte le fait qu'il s'agit d'une société patrimoniale et en considération de la communauté d'intérêts existant entre le cédant et le cessionnaire.

Elle rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 669 II du code général des impôts que, pour la liquidation des droits de mutation, « l'usufruit constitué pour une durée fixe est estimée à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l''usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. » Et elle en déduit une valeur des parts de la SCI de 7 619 euros ramenée à 5 079 euros pour tenir compte de l'application d'une décote de 33 1/3 % représentant l'impôt sur les sociétés théorique, soit une valeur unitaire de l'usufruit, d'une durée de 20 ans, des parts de la SCI LBA, par application de l'article 669 II du CGI, évaluée à 2 336 euros (46 % x 5 079).

Répondant à l'argumentation de l'intimée, elle fait valoir que les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques ne font pas obstacle à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi. Et elle affirme que la procédure produite par la société intimée pour démontrer une rupture d'égalité concerne une situation différente, le fait que la problématique juridique puisse être identique ne signifiant pas que les éléments matériels et factuels qui ont fondé les rappels d'impôt soient strictement identiques.

La société LUCCOTEL conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour d'y ajouter la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'à supporter les dépens et notamment ceux mentionnés à l'article R. 207-1 du Livre des procédures fiscales.

Elle soutient que l'administration fiscale est prescrite en son action ; que, dans le cas de notification par voie postale d'une proposition de rectification, la prescription est en effet interrompue à la date de la réception du pli postal et qu'elle n'a signé l'avis de réception que le 2 janvier 2013, soit postérieurement à l'écoulement du délai de trois années imposé à l'appelante pour exercer son droit de reprise après la cession intervenue à son profit.

À titre subsidiaire, elle fait part de son accord sur la méthode de valorisation des parts par combinaison de la valeur mathématique et de la valeur de productivité. Elle ne conteste pas la valeur mathématique nulle retenue par l'administration mais lui reproche, en ce qui concerne la valeur de productivité, d'avoir capitalisé des revenus fonciers alors que, les titres étant détenus par une société commerciale, il convenait de capitaliser, soit les flux nets de trésorerie, soit les résultats déterminés par la méthode applicable à la société, avec la déduction d'un amortissement des biens. Elle soutient que le calcul de l'appelante est erroné tant sur le bénéfice retenu, puisque sa déclaration fiscale faisait ressortir un déficit de 9 321 euros pour 2010, que sur le taux de capitalisation, la méthode consistant à retenir un résultat prévisionnel sans tenir compte des règles comptables et fiscales qui s'imposent à l'acquéreur ne pouvant être approuvée. Et, pour démontrer l'erreur commise, elle procède elle-même à un calcul du résultat net déterminé en partant du postulat que les règles régissant le régime des BIC trouvent à s'appliquer puisqu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés. Elle obtient un résultat comptable négatif correspondant selon elle en tout point à sa situation de trésorerie sur les années à venir puisqu'elle doit supporter un emprunt de 1 880 000 euros l'amenant à payer des annuités de 83 400 euros par an pendant 20 ans. Et elle en déduit que le résultat à capitaliser était égal à zéro, d'où une valeur de productivité nulle. Elle fait valoir que l'autre méthode de calcul serait fondée sur les flux de trésorerie qu'elle pourrait percevoir du fait de l'usufruit ; que le raisonnement porterait alors, non pas sur un bénéfice mais sur un cash flow correspondant à la trésorerie disponible, et que la capitalisation d'un flux négatif justifie en conséquence pleinement la valeur de 460 euros retenue lors de la cession.

Elle souligne que le taux de capitalisation retenu par l'appelante est de 5 % alors que la commission de conciliation avait défini un taux de 6,88 %, et que la cession avait été opérée au regard d'un taux de 7 % en adéquation avec celui retenu par cette commission. Et elle fait valoir que le prix d'acquisition de 1 996 000 euros et le loyer de 187

066 euros (hors taxe foncière) sont parfaitement connus et que le taux de rentabilité réel est donc de 9,37 %, très éloigné du taux retenu par l'administration puisqu'il représente presque le double.

Elle soutient enfin que le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques doit conduire l'administration fiscale à appliquer des méthodes identiques dans des situations similaires, donc à déterminer les résultats selon la méthode des BIC/IS dans chaque dossier. Et elle reproche à l'appelante d'avoir appliqué un autre calcul qu'à elle-même à une autre société dans une situation similaire.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Attendu que l'article L. 17 du livre des procédures fiscales autorise l'administration à rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle, au jour de la transmission, des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations ;

Que l'article L. 180 du même livre dispose que « pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885 W du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

Attendu que les parties s'accordent pour indiquer que, la cession litigieuse étant intervenue le 28 décembre 2009, le délai de prescription expirait le 31 décembre 2012 ;

Que l'appelante fait valoir qu'elle a rédigé le 17 décembre 2012 un courrier faisant connaître à LUCCOTEL qu'elle entendait exercer son droit de reprise et que, si l'intimée n'a effectivement reçu cette lettre que le 2 janvier 2013, elle a cependant été avisée dès le 19 décembre 2012 qu'elle lui était adressée et qu'il lui appartenait de faire diligence pour aller la retirer au bureau de Poste puisqu'il lui avait été indiqué qu'elle y avait été déposée ;

Attendu que selon l'article 668 du code de procédure civile : « Sous réserve de l'article 647-1, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre » ;

Que l'article 669 du même code énonce que : « La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».

Qu'il résulte dès lors de ces dispositions que la date de réception par le destinataire est celle à laquelle il a signé l'avis de réception ;

Qu'il est cependant dérogé à cette règle lorsqu'il est démontré que le destinataire a su qu'un pli était mis à sa disposition mais n'a pas été le retirer ou lorsqu'il a expressément demandé que son courrier soit conservé alors qu'il savait qu'il ne pourrait pas en prendre connaissance ;

Que, dans ces cas, strictement contrôlés par le juge comme étant dérogatoires au droit commun, la date de réception est celle à partir de laquelle le pli recommandé est tenu à la disposition du destinataire ;

Que dans son arrêt n° 53052 du 23 juin 1986, cité par l'appelante, le Conseil d'État a ainsi retenu « qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste » ;

Que l'arrêt de la Cour de cassation produit par l'appelante pour démontrer le bien fondé de son argumentation (cass. Com. 20 mars 2007 n° 06-15.535) ne dit rien d'autre en sanctionnant un contribuable qui avait décidé de ne pas faire suivre son courrier pendant son absence et de demander au bureau de Poste de le lui conserver jusqu'à son retour, l'administration justifiant de la carence de ce contribuable en produisant une attestation de la Poste ;

Attendu que l'appelante produit l'avis de réception de son envoi recommandé qui porte les mentions suivantes : Présenté/ avisé le 19/12 Distribué le 2/01/13, la signature du dirigeant de LUCCOTEL étant portée sous cette dernière mention ;

Attendu qu'il est établi par ce document que l'intimée a été avisée le 19 décembre 2012 de ce qu'elle avait reçu une lettre recommandée et devait aller la retirer au bureau de Poste ;

Que LUCCOTEL n'a jamais expressément contesté, que ce soit devant les premiers juges ou devant la cour, avoir reçu un avis l'informant qu'un pli recommandé contenant le courrier du 17 décembre 2012 était à sa disposition au bureau de Poste, se contentant de se référer à la date à laquelle elle a signé l'avis de réception ;

Qu'elle n'indique pas avoir été dans l'impossibilité d'aller retirer ce courrier à la Poste ni avoir tenté en vain de se le faire remettre avant le 2 janvier 2013 ;

Qu'il ne peut donc qu'être retenu qu'elle est seule responsable de la non remise de ce courrier entre le 19 décembre 2012 et le 2 janvier 2013 ;

Que le délai de prescription ayant été interrompu le 19 décembre 2012, aucune prescription ne peut être opposée à l'appelante ;

Que la décision déférée sera en conséquence infirmée ;

Attendu que les parties s'accordent pour indiquer que la valeur vénale des parts doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ;

Qu'elles s'accordent également pour retenir que les parts sociales litigieuses peuvent en l'espèce être valorisées en appliquant une combinaison entre la valeur mathématique, qu'elles sont également d'accord pour voir fixer à 0 euro, et la valeur de productivité sur laquelle elles sont en désaccord ;

Attendu que cette valeur de productivité se définit par la capitalisation du résultat net d'impôt de l'entreprise suivant l'hypothèse d'une rente infinie dudit bénéfice selon la formule : VP = revenu/ taux de capitalisation ;

Attendu, s'agissant de la détermination du revenu, que l'intimée reproche à l'administration de s'être fondée sur des éléments comptables « théoriques » ;

Que LUCCOTEL ne saurait cependant reprocher à l'administration fiscale d'avoir fixé un revenu net annuel « théorique » de la SCI alors que Monsieur et Madame V... ont revendu l'usufruit de leurs parts sociales quelques semaines après leur acquisition intervenue en décembre 2009 soit peu avant le début de l'année 2010 ;

Que les lieux étaient donnés à bail avant l'acquisition de l'immeuble par la SCI et qu'il n'est pas soutenu que le montant du loyer aurait pu varier significativement entre décembre 2009 et l'année 2010 et qu'il sera d'ailleurs relevé que la cession d'usufruit avait pour but d'assurer la pérennité de l'occupation des locaux ;

Que le montant du produit annuel de la location doit donc être retenu comme étant de 187 116 euros annuels ;

Attendu que le montant des dépenses est quant à lui connu puisqu'elles sont constituées des honoraires d'expertise comptable, de frais d'assurance afférents à l'emprunt, de la taxe foncière et des intérêts de l'emprunt ;

Que LUCCOTEL prétend cependant qu'il convient de prendre en considération les règles comptables et fiscales qui s'imposent à l'acquéreur ;

Qu'elle déduit dès lors des revenus de la SCI un amortissement annuel de 94 832 euros selon les règles BIC-IS et aboutit à un revenu annuel net nul ;

Mais attendu que cette méthode repose sur la nécessité d'un résultat comptable distribuable et d'une situation de trésorerie disponible ce qui conduit LUCCOTEL à prendre en considération, non la valeur de productivité d'une SCI mais une valeur de rendement-distribution non prise en compte pour une telle société ;

Qu'elle ne saurait dès lors être approuvée dans cette démonstration qui consiste à appliquer à des revenus perçus par une SCI des règles comptables appliquées à une SAS ;

Attendu que l'intimée fait également valoir qu'une autre méthode applicable serait celle d'actualisation des cash flow ;

Qu'elle déduit alors des revenus de la SCI la totalité du capital emprunté ;

Mais attendu que l'endettement en capital de la SCI ne doit pas être pris en considération pour déterminer la valeur de productivité, laquelle est fixée par capitalisation du résultat net ;

Qu'en effet, le montant en capital des emprunts souscrits ou du compte courant ne constitue pas une charge annuelle influant sur les revenus annuels de la SCI ;

Que cette dernière méthode ne peut être mise en œuvre qu'à l'égard d'entreprises sociétaires pratiquant des distributions régulières et non à l'égard d'une SCI, de nature patrimoniale, ayant pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier privé ;

Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que, pour démontrer que la valeur de productivité des parts sociales est négative, LUCCOTEL procède à la détermination du résultat de la SCI selon les règles BIC-IS mais ne prend pas en considération le revenu foncier cumulé ni le résultat net cumulé qui présentent des valeurs positives supérieures au prix de cession de l'usufruit ;

Qu'il résulte en effet des calculs opérés selon les indications de l'intimée que, sur la période de 20 ans considérée :

-le revenu foncier s'élève à 3 185 505 euros ;

-le résultat net cumulé s'élève à 997 759 euros après imputation du déficit comptable constaté les trois premières années et déduction de l'impôt sur les sociétés ;

-la trésorerie nette cumulée est de 1 175 281 euros selon les règles des revenus fonciers et de 827 354 euros selon les règles BIC-IS ;

Attendu en conséquence que LUCCOTEL n'oppose pas d'argument pertinent aux calculs opérés par l'administration des finances qui conduisent à retenir un revenu net de 50 793 euros, donc une valeur des parts de 5 079 euros ;

Attendu, s'agissant du taux de capitalisation, que l'administration a retenu un taux de 5 % tenant compte d'un coefficient de risque de 0,6 % ;

Que le coefficient de risque correspond aux risques internes et externes de la société, en l'espèce le risque de non paiement des loyers, le taux de base retenu comme étant sans risque étant le taux de rendement des obligations publiques garanties par l'État ;

Qu'ainsi que l'a retenu la commission départementale de conciliation, il convient cependant de tenir compte du fait que la SCI LBA est adossée à un commerce à risque exercé dans une ville où l'activité est stagnante ;

Qu'il convient donc de retenir un coefficient de risque de 0,95 % qui conduit à appliquer un taux de capitalisation de 6,88 % ;

Que la valeur de productivité est donc :

R (50 793) / taux de capitalisation (6,88 %) = 7 382,70 euros

Que la moyenne entre la valeur mathématique (0) et la valeur de productivité (7 382,70) conduit à retenir une valeur unitaire des parts s'élevant à 3 691,35 euros ;

Que les parties sont d'accord pour retenir que l'usufruit s'élève, en application de l'article 669 II du code général des impôts à 46 % de la valeur de la part en pleine propriété ;

Que la valeur de l'usufruit par part sera donc fixée à 1 698 euros et qu'il sera en conséquence jugé que l'administration fiscale est fondée à opérer un redressement tenant compte d'une valeur vénale de l'usufruit des parts sociales fixée à 1 698 euros ;

Attendu que l'intimée, succombant principalement en ses prétentions, supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu cependant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT A NOUVEAU

DÉBOUTE la société LUCCOTEL de sa demande tendant à voir juger prescrit le droit de reprise de l'administration des finances publiques,

DIT que l'administration des finances publiques est fondée à exercer un droit de reprise tenant compte d'une valeur vénale unitaire de l'usufruit des parts sociales de la SCI LBA fixée à 1 698 euros,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur W... V... et son épouse, Madame H... O... à supporter les dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à Maître GARNIER, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A 15 - Droit de mutation- vente d'un immeuble à prix minoré (cass. com. 7 mai 2019, n° 17-15621)

Cass. com. 7 mai 2019, n° 17-15621

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2017), que, par un acte authentique du 7 janvier 2003, la société Harmonie a cédé une parcelle de terrain à M. V..., qui était président du conseil d'administration de cette société ; que l'administration fiscale a constaté que, au moment de cette acquisition, un immeuble à usage d'habitation, construit par une société civile immobilière administrée par la société Harmonie, était implanté sur le terrain vendu ; que, considérant que la vente du terrain nu constituait une donation indirecte de la valeur de l'immeuble construit et prenant en compte l'évaluation de celle-ci faite par la commission départementale de conciliation, l'administration fiscale a rehaussé la valeur du bien et notifié à M. V... une proposition de rectification au titre des droits de mutation à titre gratuit et de la publicité foncière ; qu'après règlement de ces droits et rejet de sa réclamation, M. V... a assigné le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire en restitution du surplus d'imposition versé ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la vente d'un bien immobilier à un prix minoré par rapport à sa valeur vénale réelle contractée par une société commerciale au profit de son dirigeant est constitutive, à hauteur de la minoration de prix constatée par le service, d'un avantage occulte au sens de l'article 111 c) du code général des impôts, taxable en tant que revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par application de l'article 158 du même code ; que

cette qualification légale de revenu distribué, avec le régime d'imposition qui lui est associé, est exclusive de l'application de l'article 677 du code général des impôts, qui ne soumet à des droits de mutation les transmissions entre vifs de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles que « sous réserve de dispositions particulières » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés que M. V... avait acquis de la société anonyme Harmonie, dont il était le président du conseil d'administration, une parcelle de terrain décrite dans l'acte de vente comme une parcelle à bâtir moyennant la somme de 2 744 euros, alors que cette parcelle était déjà construite au jour de la vente et qu'ainsi, la société venderesse s'était irrévocablement dépouillée au profit de son dirigeant de la différence de valeur entre la valeur vénale du bien cédé et le prix de cession ; qu'en jugeant néanmoins l'administration fondée à assujettir M. V... à des rappels de droits d'enregistrement prévus aux articles 677, 750 ter et 777 du code général des impôts et de la taxe de publicité foncière, au motif inopérant que la vente à prix minorée ainsi intervenue entre la société Harmonie et son dirigeant s'analysait comme une libéralité, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'avantage ainsi retiré par ce dernier n'aurait pu être imposé qu'au titre d'un revenu distribué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que les articles 677 et 750 ter du code général des impôts, qui soumettent les transmissions d'immeubles à titre gratuit intervenues entre vifs à des droits de mutation dont les taux, fixés par l'article 777 du même code, dépendent du lien de parenté entre le donateur et le donataire, ne sont applicables qu'aux libéralités consenties par des personnes physiques ; qu'en jugeant l'administration fondée à assujettir M. V... à des rappels de droits de mutation prévus aux articles 677, 750 ter et 777 du code général des impôts, au titre de la libéralité que lui avait accordée la société Harmonie en lui cédant un bien immobilier moyennant un prix minoré, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. V... que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la donation litigieuse constituait en réalité un avantage occulte ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que l'article 902 du code civil, selon lequel toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, n'exclut pas les personnes morales et retenu, par motifs propres et adoptés, que l'article 777 du code général des impôts, qui vise notamment les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique pour les soumettre aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs et qui prévoit un taux pour les personnes non-parentes, est également applicable par nature aux personnes morales, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la donation dont avait bénéficié M. V... de la part de la société Harmonie était soumise aux dispositions de ce dernier texte ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf, signé par Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Orsini, conseiller, qui en a délibéré, en remplacement de M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. V...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. V... de l'ensemble de ses demandes et d'avoir mis à sa charge les dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« la société Harmonie, société anonyme, avait acquis diverses parcelles de terre à Saint-Brévin-les-Pins et obtenu, le 11 avril 1996, un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation de vingt logements ; qu'elle a obtenu, le 21 décembre 2001, un second permis de construire un immeuble comportant un parking souterrain et trois logements ;

qu'elle a ainsi agi comme un professionnel de l'immobilier, qui n'ignore ni les dispositions de l'article 546 du code civil ni la différence de valeur entre un terrain nu et un immeuble d'habitation ;

qu'elle a, en janvier 2003, vendu à M. V..., par ailleurs son dirigeant, au prix de 2 744,08 euros comme terrain à bâtir, les parcelles [...] , [...] et [...], qui faisaient l'objet du permis de construire du 21 décembre 2001 ;

que l'administration fiscale a estimé d'abord la valeur vénale réelle de l'ensemble immobilier, comprenant le bâtiment construit sur ces parcelles, à 278 000 euros ;

que la commission départementale de conciliation a fixé cette valeur au moment de la cession à 200 000 euros, au regard d'une qualité modérée de la construction qui y était édifiée ;

que M. V... a revendu le 13 novembre 2009 à la SCI Yophil l'ensemble immobilier au prix de 285 000 euros, en déclarant que celui-ci était achevé depuis plus de cinq ans, soit avant le 13 novembre 2004, de sorte que la mutation n'entrait ainsi pas dans le champ de la TVA, tout en ayant déclaré néanmoins, au titre de l'assujettissement à la taxe foncière, l'achèvement des travaux au 1er avril 2006 ;

qu'il ressort de l'ensemble de ces considérations qu'à l'évidence, le bâtiment était construit lorsque M. V... a acquis le terrain, et que ce dernier a en conséquence également acquis la propriété du bâtiment, en application des dispositions de l'article 546 du code civil ;

qu'il n'appartient pas à la cour, qui n'est pas saisie de cette question, de porter une appréciation sur la régularité, au plan comptable, de l'affectation ou non d'un bien à l'actif social, non plus que sur la régularité, au regard du droit des sociétés, de la décision prise par la société Harmonie, représentée à l'acte de vente par M. V..., de céder au même et à ce prix son bien ;

que cette décision, comme toute décision d'une personne morale, n'a à l'évidence été prise que par les organes physiques de la société qui en sont les mandataires sociaux, ainsi que l'a relevé le tribunal, en l'occurrence son représentant légal lors de la signature de l'acte, lequel répondra le cas échéant d'une faute de gestion si elle lui est reprochée, dans le cadre du droit applicable ;

qu'il ne lui appartient pas davantage d'examiner le litige entre l'administration fiscale et M. V... sous l'angle de l'article 121-2, alinéa 1er, du code pénal cité par ce dernier, disposition étrangère au litige ;

qu'il y a lieu seulement :

-de rappeler que, selon l'article 902 du code civil, toutes personnes, sauf celles que la loi en déclare incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, ce qui n'exclut nullement les personnes morales ;

-de relever que l'article 777 du code général des impôts, qui vise d'ailleurs notamment les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique pour les soumettre aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs, n'est pas moins applicable par nature aux personnes morales ;

-et de constater qu'en cédant à M. V..., par un acte qui produit ses effets à l'égard de ce dernier ainsi que des tiers, un terrain supportant un bâtiment d'habitation pour le prix du terrain nu, la société Harmonie s'est elle-même irrévocablement dépouillée au profit de celui-ci de la différence de valeur entre la valeur vénale du bien cédé et le prix de cession, l'intention libérale exprimée à travers l'acte de son dirigeant étant caractérisée par l'absence de toute contrepartie, ce qui répond à la définition de la donation prévue aux articles 893 et 894 du code civil » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE :

« M. V... convient aujourd'hui que la société Harmonie n'était pas seulement propriétaire du sol mais également de tout ce qui s'y unissait accessoirement soit naturellement soit artificiellement (article 546 du code civil) ;

qu'il a initialement soutenu que la venderesse n'était propriétaire que du sol car elle n'avait pas financé la construction ;

qu'en vertu des articles 546, 552 et 555 du code civil, la société Harmonie était propriétaire par accession de toutes les constructions réalisées sur le terrain, y compris par des tiers avec des matériaux appartenant à ces derniers ;

qu'il convient de rappeler que l'objet social de la SA Harmonie était l'achat et la vente de biens immobiliers ;

que cette société, de par son activité, ne pouvait ignorer qu'en l'absence de convention particulière, elle était propriétaire par accession des bâtiments ;

qu'elle agissait par l'intermédiaire de M. R... V..., son représentant légal, qui était un professionnel de l'immobilier et gérant de plusieurs sociétés ayant une activité dans le domaine de l'immobilier et de la construction ;

que les parties conviennent aujourd'hui que l'immeuble avait une valeur de 200 000 euros au jour de la vente et non de 2 744,08 euros ;

que l'éventuel inachèvement de la construction ne rendait pas nulle la plus-value apportée par les bâtiments ;

qu'en tout état de cause, il est acquis aux débats que l'immeuble était achevé, nonobstant l'absence de déclaration administrative en ce sens ;

que la SA Harmonie et M. V... le savaient parfaitement : l'immeuble était construit par la SCI Boréale, administrée par la SA Harmonie, elle-même administrée par M. V... ;

que l'acte de vente du 7 janvier 2003 a entraîné la cession irrévocable du terrain et des bâtiments ;

qu'en l'absence de mention des bâtiments dans l'acte et en présence d'un prix ne correspondant qu'à la valeur du terrain nu, la vente est susceptible d'avoir entraîné une donation indirecte au profit de M. V... ;

que pour caractériser cette donation, l'intention libérale de la SA Harmonie doit être établie ;

qu'en l'espèce, cette intention résulte, d'une part, de la connaissance qu'avait la société Harmonie de la valeur de l'immeuble vendu et, d'autre part, de l'identité même de l'acquéreur ;

que M. V... ne prétend pas que la SA Harmonie aurait vendu l'immeuble aux mêmes conditions à un tiers ;

que lui seul, en qualité de représentant de la société Harmonie pouvait acquérir l'immeuble à ce prix, sans contrepartie pour les bâtiments ;

qu'il doit être relevé à cet égard que dès le 2 mars 2007, l'administration des impôts demandait à M. V... de préciser si en dehors de l'acte de cession du 7 janvier 2003 des conventions particulières se rapportant à l'ensemble immobilier avaient été établies entre lui et la société Harmonie ou toute autre personne ; l'administration n'a pas reçu réponse sur ce point y compris dans le cadre de la présente instance : M. V... ne prétend pas qu'il a payé à la SCI Boréale du prix des travaux, éventuellement par une cession des fruits de l'immeuble ;

que l'intention libérale de la société Harmonie est ainsi établie ; qu'indépendamment des actions qui pouvaient être diligentée contre la société Harmonie, c'est à juste titre que l'administration a effectué la rectification des droits de mutation dûs par le bénéficiaire de la donation en application des articles 677, 750 ter, 777 et 1712 du code général des impôts » ;

1) ALORS QUE la vente d'un bien immobilier à un prix minoré par rapport à sa valeur vénale réelle contractée par une société commerciale au profit de son dirigeant est constitutive, à hauteur de la minoration de prix constatée par le service, d'un avantage occulte au sens de l'article 111 c) du code général des impôts, taxable en tant que

revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par application de l'article 158 du même code ;

que cette qualification légale de revenu distribué, avec le régime d'imposition qui lui est associé, est exclusive de l'application de l'article 677 du code général des impôts, qui ne soumet à des droits de mutation les transmissions entre vifs de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles que « sous réserve de dispositions particulières » ;

qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés que M. V... avait acquis de la société anonyme Harmonie, dont il était le Président du conseil d'administration, une parcelle de terrain décrite dans l'acte de vente comme une parcelle à bâtir moyennant la somme de 2 744 euros, alors que cette parcelle était déjà construite au jour de la vente et qu'ainsi, la société venderesse s'était irrévocablement dépouillée au profit de son dirigeant de la différence de valeur entre la valeur vénale du bien cédé et le prix de cession ;

qu'en jugeant néanmoins l'administration fondée à assujettir M. V... à des rappels de droits d'enregistrement prévus aux articles 677, 750 ter et 777 du code général des impôts et de la taxe de publicité foncière, au motif inopérant que la vente à prix minorée ainsi intervenue entre la société Harmonie et son dirigeant s'analysait comme une libéralité, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'avantage ainsi retiré par ce dernier n'aurait pu être imposé qu'au titre d'un revenu distribué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2) ALORS, de surcroît, QUE les articles 677 et 750 ter du code général des impôts, qui soumettent les transmissions d'immeubles à titre gratuit intervenues entre vifs à des droits de mutation dont les taux, fixés par l'article 777 du même code, dépendent du lien de parenté entre le donateur et le donataire, ne sont applicables qu'aux libéralités consenties par des personnes physiques ; qu'en jugeant l'administration fondée à assujettir M. V... à des rappels de droits de mutation prévus aux articles 677, 750 ter et 777 du code général des impôts, au titre de la libéralité que lui avait accordée la société Harmonie en lui cédant un bien immobilier moyennant un prix minoré, la Cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QU'IL résulte des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevée ; b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus c) ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention ;

qu'en application de cet article, l'administration fiscale a l'obligation de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit lorsqu'elle invoque une intention de déguisement du contribuable ;

qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait requalifié en une donation indirecte la vente intervenue entre la société Harmonie et M. V..., son dirigeant, d'une parcelle de terrain en réalité construite, mais décrite dans l'acte de vente comme à bâtir, puis avait notifié à M. V... une pénalité de 40 % pour manquement délibéré aux motifs qu'il ne pouvait ignorer les inexactitudes avec leurs conséquences contenues dans l'acte d'acquisition sur le descriptif du bien et que l'infraction a été commise sciemment en vue de se soustraire à une partie de l'impôt dû ;

qu'en considérant que l'acte litigieux était une donation indirecte, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'administration avait regardé cet acte comme renfermant une donation déguisée, ce dont il résultait que l'administration fiscale aurait dû mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit, la cour d'appel a violé l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

A 16 - Valorisation de l'usufruit par référence à la valeur de la nue-propriété (CAA Nancy 14 mai 2019, n° 18NC00107)

CAA Nancy 14 mai 2019, n° 18NC00107, 2e chambre - formation à 3

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LP Diffusion a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de rétablir les déficits consécutifs aux dotations aux amortissements au titre des exercices clos en 2008 et 2009, et de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500063 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 janvier 2018 et 21 mars 2019, la SARL LP Diffusion, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à rétablir les déficits consécutifs aux dotations aux amortissements au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et à prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes.

2°) de rétablir les déficits consécutifs aux dotations aux amortissements au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire et des pénalités correspondantes au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de répondre à un moyen et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

-la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ; l'administration ne pouvait se fonder sur un document qui n'est pas une publication officielle de l'ordre des experts-comptables mais un document de formation interne ;

-l'administration ne lui a pas adressé le document sur la base duquel les redressements sont fondés en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

-la méthode du « cash-flow » utilisée pour évaluer la valeur des nues-propriétés était pertinente ;

-la méthode substituée par l'administration n'est pas couramment utilisée et n'est pas adaptée ;

-l'administration n'a pas démontré l'intention libérale de la société LP Diffusion et ainsi l'existence d'un acte anormal de gestion ;

-elle peut se prévaloir de la réponse Grosskost du 28 juin 2005 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL LP Diffusion ne sont pas fondés.

Vu :

-les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Lambing, - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

-les observations de M. E...et de Mme A..., représentant la SARL LP Diffusion, qui ont été invités par le président de chambre à prendre la parole à l'audience, l'avocat de la société requérante étant absent,

-et les observations de MM. C.... etD..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics.

Par des notes en délibéré, enregistrées le 12 et 29 avril 2019, la société LP Diffusion présente des éléments complémentaires à l'audience.

Par une note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics présente des éléments complémentaires à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) LP Diffusion a acquis, les 10 avril et 26 juin 2008 et 6 juin 2009, l'usufruit de biens immobiliers, la nue-propriété ayant été acquise par les sociétés civiles immobilières (SCI) Foncière Phino et PJ. À la suite de la vérification de comptabilité de la SARL LP Diffusion, l'administration a réévalué la valeur de la nue propriété des trois immeubles litigieux et a qualifié la surévaluation du prix de l'usufruit d'acte anormal de gestion. Par propositions de rectification des 15 décembre 2011 et 13 juin 2012 établies selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration a remis en cause le montant des déficits au titre des exercices clos en 2008 et 2009 consécutifs aux amortissements pratiqués et a assigné à la SARL LP Diffusion une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes. La SARL LP Diffusion relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au rétablissement des déficits litigieux et à la décharge de l'imposition supplémentaire susmentionnée et des pénalités correspondantes. Sur le bien fondé de l'impôt :

2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

3. En cas d'acquisition par des personnes distinctes de l'usufruit temporaire et de la nue-propriété du même bien immobilier, lorsque l'administration établit le caractère délibérément majoré du prix payé pour l'acquisition de l'usufruit temporaire par rapport à la valeur vénale de cet usufruit, sans que cet écart de prix ne comporte pour l'usufruitier de contrepartie, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de cette opération.

4. Il résulte de l'instruction que la SARL LP Diffusion a déduit de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés des dotations aux amortissements correspondant à l'acquisition de l'usufruit des trois immeubles en litige. Pour démontrer la surestimation du prix versé pour l'acquisition de l'usufruit de ces trois immeubles, l'administration fiscale indique avoir utilisé, en vue de déterminer la valeur de la nue-propriété de cet immeuble, la méthode dite de la valeur de la pleine propriété. Afin de calculer dans un premier temps la valeur de la nue-propriété, le service a eu recours à une formule mathématique dans laquelle figure, au numérateur, la valeur de la pleine propriété à la date de l'acquisition actualisée par un taux annuel de 3 %, et au dénominateur un calcul de rentabilité de l'investissement sur la durée de démembrement à partir d'un taux de rentabilité propre à chaque immeuble, à savoir 8,5 % pour l'immeuble situé à Brunstatt et respectivement 12 % et 18 % pour les deux immeubles situés à Mulhouse. La valeur de la nue-propriété de l'immeuble à Brunstatt a dès lors été fixée à 103 712 euros au lieu de 13 591 euros, celle de l'immeuble de Mulhouse acquis en 2008 à 21 606 euros au lieu de 500 euros, et celle de l'immeuble de Mulhouse acquis en 2009 à 16 310 euros au lieu de 3 720 euros. Puis, en soustrayant de la valeur

en pleine propriété la valeur de la nue-propriété ainsi obtenue, l'administration a déterminé la valeur de l'usufruit acquis par la SARL LP Diffusion, qui a été en conséquence évaluée à 126 288 euros pour l'immeuble de Brunstatt, à 28 394 euros pour celui de Mulhouse acquis en 2008, et à 58 690 euros pour celui acquis à Mulhouse en 2009. L'administration en a tiré les conséquences au titre de la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés en rectifiant le montant des dotations aux amortissements au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010. Eu égard au déficit constaté en 2008 et 2009, une cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés a été notifiée uniquement au titre de l'exercice clos en 2010.

5. La société requérante conteste le calcul de l'administration fondé sur l'application à la valeur de la pleine propriété d'un taux de revalorisation annuel de 3 %, correspondant au taux d'actualisation des loyers utilisés par la SARL LP Diffusion dans le cadre des baux de location des immeubles. Cette méthode conduit, selon la société requérante, à une surévaluation de la valeur de la nue-propriété et est dépourvue de cohérence en l'absence de relation entre la revalorisation des loyers et la valeur des immeubles. La société requérante se prévaut en outre de la pertinence de la méthode du cash-flow actualisé qu'elle a appliquée.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'administration a déterminé la valeur vénale de la nue-propriété à la date de la cession à partir d'une formule de calcul comprenant au numérateur la valeur de la pleine propriété à la date de l'acquisition actualisée par le taux de revalorisation annuelle des loyers de 3 %, tel que résultant des baux des immeubles en litige, pour la durée du démembrement de propriété. Si la valeur de la nue-propriété à la date de la cession doit prendre en considération la valeur de la pleine propriété au terme du démembrement, l'administration, à qui incombe ici la charge de la preuve, ne démontre pas la cohérence de sa méthode fondée sur une actualisation de la valeur de la pleine propriété à partir d'un taux de croissance constant des revenus futurs de l'usufruitier pour la durée de son usufruit temporaire. En outre, la société requérante a déterminé un taux de rendement, compris entre 8, 5 et 18 % selon les immeubles, qui a été appliqué, dans le cadre de la méthode du cash-flow actualisé, aux flux futurs attendus par l'usufruitier. Ce taux de rendement, qui n'est pas remis en cause par l'administration, prend en considération, selon la société requérante, le risque financier lié notamment à l'aléa de la location d'un immeuble commercial dans le secteur géographique où se situent les biens en cause. L'administration a, pour sa part, appliqué ce taux de rendement au dénominateur de la formule de calcul utilisée pour déterminer la valeur de la nue-propriété. Dans ces conditions, cette méthode repose sur des termes de calcul non homogènes, comme le fait valoir la société requérante, dès lors que l'administration a actualisé la valeur de la pleine propriété, à la date du terme du démembrement, à partir du taux de revalorisation des loyers qui est un taux constant ne tenant pas compte de l'évolution du prix de l'immobilier dans ce secteur géographique, tout en conservant au dénominateur un taux de rendement des flux futurs de l'usufruitier, qui intègre une évaluation de l'évolution des loyers pendant la durée de l'usufruit au regard du risque financier de l'investissement immobilier. La méthode de l'administration conduit par suite à une rentabilité interne de l'investissement déséquilibrée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire et à un partage inexact, à la date de la cession, de la valeur en pleine propriété de l'immeuble entre celle de l'usufruit et celle de la nue-propriété, cette méthode erronée ayant pour conséquence que la somme de la valeur ainsi déterminée de l'usufruit et de la valeur vénale de la nue-propriété soit supérieure au prix d'acquisition de la pleine propriété. La seule circonstance que l'intérêt financier des sociétés civiles immobilières résiderait dans le coût très faible d'acquisition de la pleine propriété à l'issue de la période d'usufruit ne permet pas de regarder la valeur de l'usufruit à la date de la cession comme ayant été surévaluée. La méthode alternative proposée par l'administration dans sa note en délibéré fondée sur la méthode du cash-flow ne permet pas non plus d'obtenir des chiffres aussi voisins que possible de ceux qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où les acquisitions sont intervenues, dès lors que, comme le soutient la société requérante, pour déterminer le revenu attendu sur la durée des démembrements, il incombait au ministre de prendre en compte l'indexation des loyers de 3 % telle que prévue par les baux relatifs aux immeubles en cause et non contestée par l'administration. En n'actualisant pas les bénéfices futurs de l'usufruitier, l'administration a minoré les flux de trésorerie attendus, surestimant ainsi la valeur de la nue-propriété. En outre, l'administration ne fournit aucune explication quant à l'application d'un taux de rendement actualisé chaque année par ce même taux qui a pour conséquence de réduire le bénéfice attendu par l'usufruitier au cours du démembrement et par conséquent de sous-évaluer la valeur de l'usufruit au terme des conventions de démembrement.

7. Il s'ensuit que l'administration, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, ne démontre pas que la valeur vénale de l'usufruit temporaire des trois immeubles en cause a été surévaluée ni que les opérations de démembrement de propriété ont constitué un acte étranger à une gestion commerciale normale pour la SARL LP Diffusion.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL LP Diffusion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au bénéfice de la SARL LP Diffusion au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 novembre 2017 est annulé.

Article 2 : Les déficits consécutifs aux dotations aux amortissements au titre des exercices clos en 2008 et 2009 sont rétablis et la SARL LP Diffusion est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : Il sera mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de la SARL LP Diffusion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LP Diffusion et au ministre de l'action et des comptes publics.

A 17- Usufruit temporaire des parts d'une SCI - abus de droit (CAA Douai 1er juillet 2019, n° 17DA01029)

CAA Douai 1er juillet 2019, n° 17DA01029, 4e chambre - formation à 3

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Thierry C.... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par deux requêtes distinctes, de prononcer, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014 et des pénalités afférentes.

Par un jugement unique n° 1400788, 1503688 du 23 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2017 et le 23 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 23 mars 2017 et de remettre à la charge de la SARL Thierry C.... les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014 et des pénalités afférentes ;

2°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de la SARL Thierry C.... les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014 et des pénalités afférentes à concurrence de la réintégration du montant des intérêts d'emprunt aux bénéfices des exercices litigieux et de réformer le jugement en ce sens ;

3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 500 euros que l'État a été condamné à verser à la SARL Thierry C.... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts ;

-le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller ;

-et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Thierry C.... , créée le 1er novembre 2008, a pour activité la culture de pommes de terres. M. A...C...et son épouse sont les associés uniques de cette société, M. C.... en étant le gérant. Cette société a été créée dans le cadre de la reprise du fonds rural et des bâtiments ruraux exploités jusqu'à leur départ en retraite par M. et Mme B.... Ces derniers, qui possédaient la SCEA B...et la SCI B...Canonne, ont cédé l'intégralité de la nue-propriété de parts de ces deux sociétés à M. et Mme C.... et l'intégralité de l'usufruit de ces parts à la SARL Thierry C.... , à l'exception d'une part de chaque société que M. et Mme C.... ont conservé en pleine propriété. Les usufruits des parts de la SCEA B...et de la SCI B...Canonne, respectivement renommées SCEA C.... et SCI C.... , ont été cédé à la SARL Thierry C.... pour une durée de vingt-et-un an. À la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Thierry C.... portant sur les exercices clos en 2009 et 2010 et d'un contrôle sur pièces portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, l'administration a informé la SARL Thierry C.... qu'elle considérait que le montage lui conférant l'usufruit temporaire des parts de la SCI C.... et de la SCEA C.... avait été réalisé dans un but exclusivement fiscal ce qui a abouti, sur la base de la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, a constater l'existence d'un abus de droit qui a entraîné la reprise des amortissements opérés sur l'usufruit temporaire et à remettre en cause la déduction fiscale des intérêts de l'emprunt que la SARL Thierry C.... avait souscrit pour financer l'acquisition de cet usufruit temporaire. L'administration fiscale avait également fondé son rehaussement à titre subsidiaire sur l'acte anormal de gestion. La SARL Thierry C.... , après avoir vainement présenté des réclamations, a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par deux requêtes distinctes, de prononcer, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014 et des pénalités afférentes. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal a fait droit à sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'existence d'un abus de droit :

2. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification ».

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif

ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

4. Pour déterminer la dévolution de la charge de la preuve, le défaut de saisine du comité de l'abus de droit par l'administration fiscale doit être assimilé au refus de l'administration de se conformer à l'avis de ce comité. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, la charge de la preuve du bien-fondé des rehaussements incombe à l'administration fiscale.

5. D'une part, il est constant que l'acquisition pour une durée de vingt-et-un an de l'usufruit temporaire des parts de la SCI C.... et de la SCEA C.... par la SARL Thierry C.... a été réalisée par actes notariés du 14 janvier 2009 dont la réalité et les effets ne sont pas contestés. Il résulte de l'instruction que les SARL Thierry C.... , la SCI C.... et la SCEA C.... sont le support d'activités économiques réelles et que la SCEA C.... et la SCI C.... ont au cours des années en litige versés à la SARL Thierry C.... des revenus au titre de l'usufruit temporaire qu'elle avait acquis. Par suite, il n'est pas établi que l'opération de démembrement de la propriété des parts de la SCEA C.... et de la SCI C.... et l'acquisition de l'usufruit temporaire de ces parts par la SARL Thierry C.... constituerait un montage purement artificiel et fictif.

6. D'autre part, l'administration fiscale soutient que la SARL Thierry C.... a recherché l'application littérale des dispositions de l'article 619 du code civil, selon lesquelles l'usufruit temporaire concédé à une personne morale ne peut excéder trente ans, à l'encontre de l'intention de leurs auteurs. Toutefois, de telles dispositions, en elles-mêmes, n'ont aucun objet ni aucune portée fiscale et ne sauraient en conséquence être utilement invoquées par l'administration pour démontrer l'existence d'une fraude à la loi fiscale qui suppose l'utilisation de dispositifs fiscaux à l'encontre de l'intention de leur auteur. Par suite, l'administration fiscale, qui n'invoque aucune disposition fiscale dont la SARL Thierry C.... aurait recherché une application littérale à l'encontre des intentions de ses auteurs, en ayant recours au mécanisme de l'usufruit temporaire prévu par les dispositions de l'article 619 du code civil, n'établit pas l'existence d'un abus de droit. Ce seul motif suffit à lui seul pour écarter l'existence d'un abus de droit dans l'opération en litige.

7. En tout état de cause, si la SARL Thierry C.... a pu, grâce à l'opération d'acquisition temporaire d'usufruit des parts de la SCI C.... et de la SCEAC..., procéder à l'amortissement de la valeur totale de l'usufruit et déduire en tant que charge les intérêts de l'emprunt souscrit pour procéder à cette acquisition, il résulte toutefois de l'instruction que ces déductions fiscales ont une contrepartie dans la perception de revenus versés par la SCI C.... et la SCEAC.... Si la SARL Thierry C.... avait acquis directement les parts de ces sociétés en pleine propriété, elle aurait pu également déduire les intérêts d'emprunt liés à cette acquisition. Par ailleurs, si l'administration fiscale soutient que la taxation à l'impôt sur les sociétés des revenus versés par la SCI C.... et la SCEA C.... est plus avantageuse qu'une taxation à l'impôt sur le revenu et que l'opération entraîne une absence de taxation des revenus à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au nom de M. A...C..., il résulte de l'instruction que même si elle avait acquis les parts en pleine propriété, les revenus afférents à ces parts que la SARL Thierry C.... aurait perçus auraient été imposés à l'impôt sur les sociétés. En outre, la SARL Thierry C.... fait valoir, sans être contestée sur ce point par le ministre de l'action et des comptes publics, que si elle avait acquis les parts de la SCEA C.... en pleine propriété, la SCEA C.... n'aurait alors pu se voir apporter par M. et Mme C.... les terres agricoles pour lesquelles ils sont preneur d'un bail rural en raison des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural qui prévoit cette mise à disposition à la condition que le capital de la SCEA soit majoritairement détenu par des personnes physiques. Ainsi, la SARL Thierry C.... avait un intérêt autre que fiscal à n'acheter que l'usufruit des parts de la SCEAC.... En conséquence, le choix de la SARL C.... de n'acquérir que l'usufruit temporaire des titres de la SCI C.... et de la SCEA C...répond indépendamment de l'économie fiscale qu'elle lui procure en lui permettant de déduire l'amortissement de l'usufruit, à une préoccupation de nature économique afin de permettre à la SCEA C.... de pouvoir bénéficier de l'apport des terres des époux C.... dont ils sont locataires. Par suite, nonobstant l'avantage fiscal qui en découle, l'administration fiscale ne démontre pas que l'opération en cause procède, pour la SARL C.... , de la recherche d'un but exclusivement fiscal.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge des impositions en litige en l'absence d'abus de droit. En ce qui concerne l'existence d'un acte anormal de gestion :

9. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

10. L'administration fiscale soutient que la SARL Thierry C.... a financé par emprunt l'acquisition de l'usufruit des parts de la SCI C.... et de la SCEA C.... alors même que dans vingt-et-un ans elle perdra les fruits liés à ces parts, sans indemnité ni contrepartie. À l'issue de ce délai de vingt-et-un ans, calculé sur la durée de l'activité agricole de M.C..., ce dernier sera propriétaire des parts de la SCI C.... et de la SCEA C.... dont l'acquisition aura été financée à 65 % par la SARL Thierry qui en aura supporté les frais financiers et ne percevra aucune contrepartie. Il résulte cependant de l'instruction que l'usufruit acquis par la SARL Thierry C.... ne pouvant être que temporaire, elle pouvait légalement l'amortir, l'administration fiscale ne contestant d'ailleurs pas dans son principe cet amortissement ni sa durée. En outre, il n'est pas établi par l'administration fiscale que l'abandon au terme du délai de vingt-et-un ans, de l'usufruit au nu-propriétaire constituerait une intention libérale de la SARL Thierry C.... au profit de son gérant dès lors que ce dernier a renoncé aux fruits des parts dont il est propriétaire pendant vingt-et-un ans au profit de la SARL Thierry C.... Par ailleurs, si l'administration fiscale fait valoir que l'amortissement pratiqué aurait été calculé de manière à compenser exactement les produits issus de l'usufruit, elle ne l'établit pas. Les produits issus de l'usufruit n'ont pas vocation à être fixes ainsi que le montrent les résultats affectés à la SARL Thierry C.... à proportion de ses parts au cours des années en litige. L'administration fiscale n'établit pas non plus que le montant de l'usufruit temporaire des parts en cause pendant vingt-et-un ans devrait représenter moins de 65 % du prix d'acquisition de ces parts. Enfin, les frais financiers en litige ne sont pas dénués de contrepartie pour la SARL Thierry C.... , dès lors qu'ils ont pour objet l'acquisition d'éléments productifs de revenus pendant une période de vingt-et-un ans. En conséquence, l'administration fiscale n'établit pas que la déduction des intérêts d'emprunt par la SARL Thierry C.... constitue pour cette dernière un acte anormal de gestion. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de substitution de base légale présentée par le ministre.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Thierry C.... a été assujettie au titre des années 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014 à concurrence de la réintégration des intérêts de l'emprunt souscrit pour acquérir les parts de la SCI C.... et de la SCEA C.... aux bénéfices des années en cause. Sur les frais liés à l'instance :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

13. Le ministre de l'action et des comptes publics n'étant pas la partie gagnante devant la cour, il n'y a pas lieu d'annuler la mise à la charge de l'État par le tribunal de la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Thierry C... sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros demandée par la SARL Thierry C.... sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais liés à la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre est rejetée.

Article 2 : L'État versera à la SARL Thierry C.... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Thierry C.... et au ministre de l'action et des comptes publics.

A 18 – En cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier n'a droit qu'aux dividendes distribués (CE 30 septembre 2019, n° 419855)

CE 30 septembre 2019, n° 419855

Vu la procédure suivante :

La société Hôtel Restaurant Luccotel a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009. Par un jugement n° 1502490 du 23 février 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NT01325 du 15 février 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hôtel Restaurant Luccotel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code civil ;

-le code général des impôts, l'annexe III à ce code et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

-le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

-les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la Société Hôtel Restaurant Luccotel ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par acte sous seing privé du 28 décembre 2009, la SCI LBA a cédé à la société Hôtel Restaurant Luccotel, détenue indirectement par les associés de la SCI, l'usufruit de la totalité de ses parts sociales pour une durée de vingt ans et un montant total de 460 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'évaluation de la valeur de cet usufruit qu'elle a estimée, en application de la méthode d'actualisation des flux de revenus attendus, à la somme de 949 000 euros, par la suite ramenée à 632 993 euros. En conséquence, l'administration a procédé au rehaussement de l'actif net de la société Hôtel Restaurant Luccotel à hauteur de la différence entre la valeur réelle de l'usufruit et celle inscrite à l'actif de cette société. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 février 2018 de la cour administrative de Nantes qui a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans avait rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités résultant de cette rectification.

2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. / (...) ; / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; / (...). "

3. D'une part, la valeur vénale des titres d'une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.

4. D'autre part, en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués.

5. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'administration a déterminé la valeur attendue de l'usufruit provisoire des parts de la SCI LBA sur la base de la capitalisation, avec taux d'actualisation de 5%, des résultats nets d'activité de la société avec un abattement de 33,33% correspondant à une imposition théorique à l'impôt sur les sociétés. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que l'évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d'investissements futurs, lorsqu'elles sont justifiées par la société. Par suite, en jugeant que la méthode d'évaluation de la valeur de l'usufruit acquis par la société Hôtel Restaurant Luccotel, retenue par l'administration et fondée sur les résultats imposables prévisionnels de la société, était régulière alors qu'il convenait de déterminer cette valeur sur la base des distributions prévisionnelles, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Hôtel Restaurant Luccotel est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 15 février 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société Hôtel Restaurant Luccotel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Hôtel Restaurant Luccotel et au ministre de l'action et des comptes publics.

A 19 – L’usufruitier n’est pas un associé (Cass. civ. 16 février 2022, n° 20-15164)

Cass. civ. 16 février 2022, n° 20-15164

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ [M] [J], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, au droit duquel viennent :

2°/ Mme [P] [F], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 2],

tous deux pris tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'ayants droit de [M] [J],

ont formé le pourvoi n° W 20-15.164 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à la société Veuliah, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

1. Mme [P] [J] et M. [W] [J] entendent reprendre l'instance à laquelle [M] [J], décédé le 7 septembre 2020, était partie.

2. En vertu de l'article 617 du code civil, l'usufruit s'éteignant par la mort de l'usufruitier, il ne peut y avoir transmission à cause de mort de ce droit ni d'une action qui en est l'accessoire.

3. Il s'ensuit qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le décès de [M] [J] a éteint l'instance, en ce qu'elle avait été introduite par lui avant son décès, accessoirement à l'extinction de l'action, de sorte que cette instance ne peut pas être reprise par Mme [P] [J] et M. [W] [J] en leur qualité d'ayants droit du défunt.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 2020), [M] [J] et son épouse, Mme [P] [J], ont eu trois enfants, Mme [X] [J] et MM. [D] et [W] [J].

5. Mmes [P] et [X] [J] et M. [D] [J] ont constitué la société civile immobilière Veuliah (la SCI), dont Mme [X] [J] est gérante.

6. En 2010, Mme [P] [J] a cédé l'ensemble de ses parts à Mme [X] [J] et M. [D] [J].

7. Par acte du 15 janvier 2018, l'usufruit d'une partie des parts sociales a été cédé à [M] [J] et Mme [P] [J].

8. En mai 2018, à l'occasion d'une augmentation du capital social, M. [W] [J] a acquis des parts sociales dont l'usufruit a été attribué à [M] [J] et Mme [P] [J].

9. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2019, [M] [J] et Mme [P] [J] ont demandé à la gérante de provoquer la délibération des associés concernant la révocation de Mme [X] [J] de ses fonctions de gérante et la nomination de co-gérants.

10. Exposant que Mme [X] [J] avait gardé le silence, [M] [J], Mme [P] [J] et M. [W] [J] ont assigné, sur le fondement de l'article 14 des statuts de la SCI et de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, Mme [X] [J], M. [D] [J] et la SCI aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés à l'effet de statuer sur la révocation de Mme [X] [J] de ses fonctions de gérante et la nomination de co-gérants.

11. [M] [J] est décédé le 7 septembre 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur ce moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui sont irrecevables.

Sur le moyen, pris en sa première branche, après avis de la chambre commerciale, pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile

Enoncé du moyen

13. Mme [P] [J] et M. [W] [J] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de [M] [J] et de Mme [P] [J] tendant à la désignation d'un mandataire, alors « que l'usufruitier de parts sociales a la qualité d'associé ; et qu'en posant en principe que, dans le silence de la loi, l'usufruitier de parts sociales n'est pas un associé, que dès lors il n'a pas le pouvoir demander au gérant de provoquer la délibération des associés et qu'a fortiori il est irrecevable à saisir le juge du tribunal de grande instance d'une demande tendant à la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, la cour d'appel a violé l'article 1844 du code civil, ensemble l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. »

Réponse de la Cour

14. Aux termes de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

15. Selon l'article 39, alinéas 1er et 3, du décret du 3 juillet 1978, dans sa version applicable, un associé non gérant d'une société civile peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa demande, solliciter du président du tribunal, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

16. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, mais qu'il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

17. [M] [J] et Mme [P] [J] n'ayant pas la qualité d'associés et n'ayant pas soutenu que la question à soumettre à l'assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l'usufruit, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que leur demande de désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] [J] et M. [W] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] [J] et M. [W] [J] et les condamne à payer à Mme [X] [J], M. [D] [J] et la société civile immobilière Veuliah la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [F] épouse [J] et M. [W] [J]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré la demande principale de désignation d'un mandataire de M. [M] [J], Mme [P] [J] et M. [W] [J] irrecevable,

Aux motifs propres que « Les dispositions de l'article 1873 du Code civil autorisent le démembrement des droits attachés à des parts sociales en nue-propriété et usufruit.

Aux termes des statuts de la SCI, le droit de vote est transféré à l'usufruitier : en effet l'article 8 des statuts intitulé "parts sociales" dispose :

titre - la propriété des parts sociales résulte seulement des statuts, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, qui seraient régulièrement consenties, constatées publiées.

Tout associé peut, après toute modification statutaire, demander la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. A ce document est annexée la liste mise à jour des associés, des gérants et, le cas échéant, des autres organes sociaux. Les parts sociales ne sont pas négociables.

Droits attachés aux parts - chaque part donne droit dans la répartition des bénéficies ou des pertes, du boni ou du mali de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Elle donne également droit de participer aux assemblées générales des associés et d'y voter.

Usufruit - Si une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions prises lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le nu-propriétaire en sa qualité d'associé étant convoqué aux assemblées générales, avec voix consultative.

Ainsi, le nu-propriétaire a la qualité d'associé et en l'espèce aucune disposition ni des statuts ni de la loi ne confère à l'usufruitier la qualité d'associé.

Et aux termes des statuts de la SCI et en l'espèce l'article 14 intitulé "décisions collectives", seul l'associé a la faculté de demander à la gérante de provoquer la délibération des associés ; cet article dispose en effet : (...)

Convocation : sauf lorsque tous les associés sont gérants, les assemblées sont convoquées par la gérance ou sur la demande de plusieurs associés représentant la moitié au moins de toutes les parts sociales" (...)

En l'espèce [M] et [P] [J] (titulaires selon leurs écritures de l'usufruit de plus de 80 % des parts sociales) ont demandé à la gérance de la SCI de provoquer ladite délibération alors qu'ils ont la seule qualité d'usufruitiers titulaires d'un droit de vote et non la qualité d'associés.

C'est donc par une motivation précise et pertinente que la cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevables leurs prétentions de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés de la société à l'effet, au principal, de statuer sur la révocation de Mme [X] [J] de ses fonctions de gérant, la nomination de cogérants, la modification corrélative des statuts et les pouvoirs en vue des formalités.

Le premier juge a pertinemment retenu qu'aux termes de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, l'associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée, et que l'article 14 des statuts de la SCI intitulé "convocation" précise que "sauf lorsque tous les associés sont gérants, les assemblées sont convoquées par la gérance ou sur la demande de plusieurs associés représentant au moins la moitié de toutes les parts sociales".

S'agissant de [W] [J], s'il a la qualité d'associé, sous réserve de l'issue du contentieux également pendant devant le Tribunal de grande instance de Libourne à ce sujet, il est constant que l'assignation délivrée en son nom n'a pas été précédée d'une réclamation faite par lui à la gérante dans les termes de l'article 14 des statuts aux fins de provoquer une délibération.

En effet, la mise en demeure par lettre recommandée datée du 14 janvier 2019 adressée à la gérante [X] [J] (pièce numéro 24 des intimés) est signée des seuls [P] [J] et [M] [J] et la signification de cette lettre par acte d'huissier du 17 janvier 2019 mentionne toujours qu'il s'agit d'une lettre adressée en recommandé AR émanant de Monsieur et Madame [M] [J] demandant de provoquer la délibération des associés de la société Veuliah, aux fins précitées.

C'est donc pour des motifs précis et pertinents que la Cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevables les prétentions des époux [M] et [P] [J] ainsi que de [W] [J]. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs réputés adoptés de l'ordonnance entreprise que « I. Sur la demande principale

Les demandeurs s'appuient sur les dispositions de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 qui prévoit que "un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée et sur l'article 14 "convocation" des statuts qui précise que "sauf lorsque tous les associés sont gérants, les assemblées sont convoquées par la gérance ou sur la demande de plusieurs associés représentant au moins la moitié de toutes les parts sociales".

Sur ces fondements et affirmant qu'ils détiennent ensemble plus de 80 % des droits de vote, ils ont demandé au gérant par lettre recommandée avec accusés de réception du 14 janvier 2019 de provoquer la délibération des associés de la société VEULIAH sur l'ordre du jour relatif notamment à la révocation de Madame [X] [J] de ses fonctions de gérant et la nomination de co-gérants.

Ils indiquent que Madame [X] [J] ayant gardé le silence, ils entendent se prévaloir des dispositions de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 qui prévoit dans cette hypothèse que "si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés".

Les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la demande de [M] et [P] [J] en ce qu'ils n'ont pas la qualité d'associé, rappelant qu'aux termes de l'acte de cession de parts du 15 janvier 2018, dont la nullité est par ailleurs poursuivie par eux devant le Tribunal de grande instance de Libourne, les époux [J] ont acquis l'usufruit des parts de Madame [X] [J] et de Monsieur [D] [J].

Suite à l'augmentation de capital du 18 mai 2018, dont ils demandent également l'annulation aux termes de la même procédure au fond, les époux [J] se sont attribué l'usufruit d'une partie des parts souscrites par Monsieur [W] [J].

Ils soutiennent qu'en qualité d'usufruitiers, [M] et [P] [J] n'ont pas la qualité d'associés et ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 et ne peuvent demander à la gérante de la société VEULIAH de convoquer une assemblée et, à défaut, solliciter de la juridiction la nomination d'un mandataire pour convoquer cette assemblée.

Les défendeurs soulèvent également l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [W] [J] lequel n'a pas mis en demeure Madame [X] [J], ès-qualité, de convoquer l'assemblée de la société Veuliah et ne peut donc demander à la juridiction la nomination d'un mandataire chargé de convoquer cette assemblée au vu des dispositions de l'article 39 précité.

Sur la recevabilité de la demande de [M] et [P] [J] :

[M] et [P] [J], par acte de cession de pars du 15 janvier 2018, ont acquis l'usufruit de 100 des 120 parts de la SCI VEULIAH pour un prix de 96 000 euros.

Ils ont donc la qualité d'usufruitier des parts sociales.

Même si les statuts de la SCI VEULIAH offrent de manière particulièrement généreuse à l'usufruitier le droit de vote exclusif aux assemblées avec consultation pour avis du nu-propriétaire aux assemblées générales, ils ne peuvent en tirer pour conséquence qu'ils ont pour autant la qualité d'associé laquelle est attachée à la seule propriété et/ou nue-propriété des parts sociales, étant rappelé que la qualité d'associé n'est pas liée à l'étendue des droits de vote.

Dans le silence de la loi et l'absence d'une position claire du droit positif sur l'extension de la qualité d'associé à l'usufruitier, il convient de considérer que [M] [J] et [P] [J] ne peuvent se prévaloir de cette qualité.

Il s'en déduit au regard des statuts qu'ils n'avaient pas le pouvoir de solliciter du gérant la convocation d'une assemblée et, en l'absence de réponse du gérant, ne sont pas recevables à en faire la demande devant le président du tribunal de grande instance.

Sur la recevabilité de la demande de [W] [J]

[W] [J] a acquis des parts sociales dans le cadre d'une augmentation de capital au cours de l'année 2008, au moment où [M] [J] et [P] [J] avaient acquis la gérance de la société dans des conditions qui ont conduit à l'annulation, en référé, des décisions prises relatives à la révocation de madame [X] [J] et à leur nomination en qualité de gérants.

Une procédure au fond est actuellement en, cours en demande notamment de la nullité des décisions relatives à l'augmentation de capital.

Dans l'attente de la décision relative à cette procédure au fond, il convient de constater que Monsieur [W] [J] qui dispose de 20 parts sociales en pleine propriété et de 40 parts sociales en nue-propriété a la qualité d'associé de la SCI VEULIAH.

C'est à juste titre que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de sa demande en justice en désignation d'un mandataire en application de l'article 39 du décret du 4 juillet 1978 et de l'article 14 des statuts de la SCI VEULIAH, laquelle doit au préalable être précédée d'une demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au gérant de la société.

Or, force est de constater que le courrier AR adressé le 14 janvier 2019 à Madame [X] [J] pour solliciter la délibération des associés, n'émane que des deux usufruitiers [P] et [M] [J].

Il s'en déduit que [W] [J] n'est pas recevable en sa demande.

En conséquence, la demande présentée par les consorts [J] sera déclarée irrecevable » ;

1 °) Alors que l'usufruitier de parts sociales a la qualité d'associé ; et qu'en posant en principe que, dans le silence de la loi, l'usufruitier de parts sociales n'est pas un associé, que dès lors il n'a pas le pouvoir demander au gérant de provoquer la délibération des associés et qu'a fortiori il est irrecevable à saisir le juge du Tribunal de grande instance d'une demande tendant à la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, la Cour d'appel a violé l'article 1844 du Code civil, ensemble l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

2°) Alors que, aussi et en tout état de cause, le terme « associé(s) » tel que mis en oeuvre par les statuts de la S.C.I. VEULIAH désigne clairement et sans la moindre ambiguïté, et de façon générale, outre les nus-propriétaires de parts sociales, tous les titulaires du droit de voter aux assemblées générales, dont les usufruitiers ; qu'en retenant néanmoins que les statuts de la S.C.I. VEULIAH, même s'ils « offrent de manière particulièrement généreuse à l'usufruitier le droit de vote exclusif aux assemblées avec consultation pour avis du nu-propriétaire aux assemblées générales », n'attribuent pas pour autant la qualité d'associé à l'usufruitier et ne lui confèrent pas « le pouvoir de solliciter du gérant la convocation d'une assemblée et, en l'absence de réponse du gérant, (qualité pour demander) au président du tribunal de grande instance » la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés de la société, la Cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises desdits statuts, violant ainsi l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 nouveau du même Code ;

3°) Alors que, encore et en tout état de cause, à une formalité déterminée, exigée par la loi ou la convention, peut toujours être valablement substituée une formalité plus contraignante pour celui qui l'accomplit et plus protectrice pour celui à qui elle est destinée ; qu'une assignation en justice peut donc toujours être substituée à une lettre recommandée ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de M. [W] [J] tendant à la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, faute par cet associé d'avoir, préalablement à l'assignation en justice délivrée notamment à la gérante et à la société VEULIAH, formulé sa demande par lettre recommandée adressée à la gérante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978

4°) Alors que, en tout état de cause et enfin, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la Cour d'appel a constaté que [M] et [P] [J] avaient adressé le 14 janvier 2019 un courrier recommandé avec accusé de réception à Mme [X] [J] pour solliciter la délibération des associés ; qu'elle a également constaté que M. [W] [J] s'était joint à M. [M] [J] et Mme [P] [J] pour assigner Mme [X] [J], M. [D] [J] et la société VEULIAH prise en la personne de son représentant légal devant le Président du Tribunal de grande instance de Libourne statuant en la

forme des référés ; que, néanmoins, la Cour a déclaré irrecevables les demandes de [M], [P] [J] et [W] [J], faute par les premiers d'avoir, selon elle, la qualité d'associés les autorisant à former une telle réclamation auprès de la gérante et faute par le dernier, auquel elle a reconnu la qualité d'associé, d'avoir fait précéder l'assignation délivrée en son nom d'une réclamation faite par lui à la gérante dans les termes de l'article 14 des statuts aux fins de provoquer une délibération ; qu'en statuant ainsi alors qu'en se joignant à la procédure, M. [W] [J] avait, en tout état de cause, fait disparaître la cause de l'irrecevabilité fondée sur le prétendu défaut de qualité de [M] et [P] [J], la Cour a violé l'article 126 du Code de procédure civile.

A 20 – Changement inexpliqué dans la politique de dividendes (CE 20 mai 2022, n° 449385)

CE 20 mai 2022, n° 449385

Vu la procédure suivante :

D'une part, la société civile (SC) Ambroise D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1602235 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé une décharge partielle et rejeté le surplus de sa demande.

D'autre part, M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1602234 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé une décharge partielle et rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt nos 19NC00530, 19NC00543 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés respectivement par la SC Ambroise D... et par M. et Mme D... contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 3 mai 2021 et le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SC Ambroise D... et M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code civil ;

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

-le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

-les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société civile Ambroise D... et de M. et Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile (SC) Ambroise D..., qui a pour activité l'exploitation et la gestion de biens viticoles dans la Marne, a été créée le 1er mai 2006 entre M. A... D... et Mme E... D... à parts égales. Le 31 juillet 2009, Mme D... a cédé à la SC Ambroise D... l'usufruit temporaire des parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société civile d'exploitation viticole (SCEV) Champagne René Bouché pour une période de 10 ou 17 ans selon les parts. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SC Ambroise D..., l'administration a réévalué la valeur des cessions d'usufruit temporaire réalisées en 2009 et a réintégré la différence dans l'actif net de la société. Elle a également requalifié le montant de la cession des parts sociales de Mme D... en plus-values professionnelles. En conséquence de ces rectifications, l'administration a notifié, d'une part, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2009 à la SC Ambroise D... et, d'autre part, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 à M. et Mme D.... Par deux jugements du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit aux demandes de décharge de la SC Ambroise D... et de M. et Mme D.... Ces contribuables se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs appels formés contre ces jugements en tant qu'ils ont rejeté le surplus de leurs demandes.

2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. / (...) ; / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; / (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit.

3. D'une part, la valeur vénale des titres d'une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.

4. D'autre part, en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués. Il en résulte que l'évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles, qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d'investissements futurs, lorsqu'elles sont justifiées par la société.

Sur la méthode d'évaluation mise en œuvre par le vérificateur :

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le vérificateur a déterminé la valeur attendue de l'usufruit des parts de la SCEV Champagne René Bouché en effectuant la moyenne arithmétique des valeurs obtenues à l'aide, d'une part, de la méthode de la valeur actualisée des flux de revenus futurs, en capitalisant le montant du dividende moyen distribué les trois années précédant la cession en litige, à partir d'un taux de rendement et d'un taux de croissance des dividendes sur la durée de l'usufruit, et d'autre part de la méthode de la valeur en pleine propriété des titres, l'usufruit étant déterminé à partir du taux de rendement des titres sur la durée de l'usufruit.

La cour a relevé que la valeur de l'usufruit des titres en litige ainsi obtenue était supérieure de 69 % à la valeur déclarée par les contribuables s'agissant des titres démembrés durant une période de dix ans et de 114 % pour ceux portant sur une durée de dix-sept ans.

6. En premier lieu, en l'absence d'argumentation des contribuables tirée de ce que le montant des distributions prévisionnelles tel que déterminé par le vérificateur serait surévalué en tant qu'il ne prendrait pas en compte certains éléments susceptibles de l'affecter qu'ils étaient seuls en mesure de justifier, notamment le solde de la trésorerie disponible, et alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, depuis sa création, la totalité des bénéfices de la SCEV était distribuée et appréhendée par les associés, par perception de numéraire ou inscription au crédit des comptes courants d'associés, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu son office et les règles de dévolution de la charge de la preuve en s'abstenant de rechercher si la méthode mise en œuvre par l'administration tenait compte de tels éléments ne peut être qu'écarté.

7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la cour a commis une erreur de droit en refusant de soustraire des résultats distribués la rémunération versée à Mme D..., associée exploitante de la SCEV Champagne René Bouché, pour la détermination du dividende de référence utilisé pour calculer la valeur actualisée des flux de revenus futurs de l'usufruitier et la valeur de rendement de la pleine propriété des titres. Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que le dividende de référence a été calculé à partir des résultats distribués les trois années précédentes, lesquels correspondaient aux résultats comptables de la SCEV compte tenu de la pratique de distribution intégrale de ces derniers. Or, il ressort des pièces comptables figurant au dossier soumis aux juges du fond que les rémunérations versées par la SCEV à Mme D..., à hauteur de 2 500 euros mensuels, ont été, au cours des exercices précédant la cession, déduites des résultats comptables. Par suite, il n'y avait pas lieu de déduire du dividende de référence la rémunération versée à Mme D... déjà prise en compte. Il y a lieu de substituer ce motif, qui résulte de faits constants, à celui, inopérant, retenu par la cour, tiré de ce que la rémunération des associés d'une société de personnes ne constitue pas une charge déductible pour la détermination du bénéfice imposable.

8. En troisième lieu, en relevant que les éléments produits par les contribuables ne permettaient pas de remettre en cause le taux de croissance constant des dividendes de 2 % retenu par le vérificateur, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier. En outre, les requérants ne sauraient utilement contester le motif, surabondant, par lequel la cour a relevé que les données de l'entreprise relatives aux chiffres d'affaires des années précédant celle des cessions en litige, produites par la société requérante, tendaient à confirmer dans leur ensemble le taux de croissance évalué par l'administration. Par suite, les moyens d'erreur de droit et de dénaturation soulevés à l'encontre de ce motif ne peuvent être qu'écartés.

9. Il résulte de ce qui précède qu'en validant la méthode mise en œuvre par le vérificateur pour établir la minoration de la valeur de l'usufruit déclarée par les contribuables, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard de la règle exposée au point 4 ni dénaturé les faits.

Sur la méthode alternative d'évaluation de l'usufruit proposée par les contribuables :

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SC Ambroise D... proposait, dans le dernier état de ses écritures d'appel, une méthode alternative d'évaluation de l'usufruit des titres de la SCEV Champagne René Bouché fondée sur le solde actualisé de la trésorerie disponible correspondant à la différence entre l'excédent brut d'exploitation et le besoin en fonds de roulement, les annuités d'autofinancement des investissements et la rémunération des associés, sans justifier des motifs pour lesquels elle entendait modifier pour l'avenir sa pratique antérieure constante de distribution de la totalité de ses bénéfices comptables. La cour a jugé que cette méthode se bornait à déterminer l'endettement financier de la SCEV et sa trésorerie disponible et ne permettait pas, par suite, de déterminer le montant des distributions prévisionnelles attendu par l'usufruitier. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, et alors au demeurant que le ministre fait valoir que la méthode alternative proposée aboutissait, sur les quatre années antérieures, à retenir un montant de trésorerie disponible nettement inférieur au montant effectivement distribué au titre de ces mêmes années, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits.

11. En second lieu, les requérants, qui ne proposaient pas d'autre méthode alternative que celle décrite au point 10, ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de statuer sur la méthode d'évaluation initiale de la valeur de l'usufruit à laquelle ils avaient procédé, remise en cause par le vérificateur.

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

13. Pour valider l'application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, la cour a relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, qu'il ressortait des propositions de rectification adressées aux contribuables que le prix de cession de l'usufruit temporaire des parts accordé par M. et Mme D... à la SC Ambroise D... était d'un montant inférieur à celui des résultats annuels de trois exercices pour le démembrement de dix ans et de quatre exercices pour celui de dix-sept ans, et qu'ils avaient nécessairement connaissance de la progression des ventes de bouteilles de champagne et des résultats en hausse de la SCEV Champagne René Bouché. En déduisant de ces constatations que Mme D... ne pouvait ignorer qu'elle consentait à la SC Ambroise D... l'usufruit temporaire des parts à un prix nettement inférieur à leur valeur vénale réelle, et que la société ne pouvait ignorer qu'elle bénéficiait ainsi d'une libéralité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SC Ambroise D... et de M. et Mme D... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile Ambroise D..., à M. et Mme A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

A21 – Cession de l'usufruit de droits sociaux soumise au droit fixe (Cass. com. 30 novembre 2022, n° 20-18884)

Cass. com. 30 novembre 2022, n° 20-18884

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

La société [F] participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-18.884 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [F] participations, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain,

conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, M. Alt, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, MM. Boutié, Gillis, Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2020) et les productions, par acte des 7, 15 et 22 mars 2012, enregistré le 26 avril 2012 au service des impôts des entreprises, Mmes [H] [F] [R], [O] [F] et [G] [F] et MM. [T] [F], [D] [F], [W] [F] et [S] [F] (les consorts [F]), associés dans la société civile immobilière NSG, ont cédé l'usufruit temporaire des parts qu'ils détenaient dans cette société à la société [F] participations, qui a acquitté le droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts.

2. Le 23 janvier 2015, soutenant que cet acte devait être soumis au droit d'enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l'article 726, I, 2°, du code général des impôts, applicable aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, l'administration fiscale a notifié à la société [F] participations une proposition de rectification des droits d'enregistrement pour l'année 2012.

3. Après le rejet partiel de sa réclamation contentieuse, la société [F] participations a assigné l'administration fiscale en décharge des droits supplémentaires mis en recouvrement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société [F] participations fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la décharge totale des droits supplémentaires d'enregistrement auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2012, alors « que seules les cessions de participations dans les personnes morales à prépondérance immobilière sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 5 % ; que la cession temporaire de l'usufruit de droits sociaux, dès lors qu'elle ne confère pas au titulaire une part du capital, mais seulement le droit temporaire de jouir et de percevoir les fruits de tels droits, n'est pas incluse dans le champ d'application de la taxe ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de cession d'usufruit temporaire de parts sociales des 7, 15 et 20 mars 2012 que la société civile immobilière NSG, au capital de 49 300 000 euros, a été créée entre les consorts [F], lesquels ont cédé pour une durée de vingt ans l'usufruit de leurs parts à la société [F] participations ; que cette dernière n'est devenue propriétaire, avec la jouissance qui y est attachée, que de l'usufruit temporaire des parts sociales, les consorts [F] demeurant propriétaires des parts et assumant le risque capitalistique qui s'y attache ; qu'en jugeant qu'une telle cession devait être regardée comme une cession de participations, la cour d'appel a violé l'article 726 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 726 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et l'article 578 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement proportionnel.

6. Aux termes du second, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Il en résulte que l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l'usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.

7. Pour retenir que la cession de l'usufruit des parts sociales de la société civile immobilière NSG, conclue entre les consorts [F] et la société [F] participations, entrait dans le champ d'application de l'article 726 du code général des impôts et rejeter la demande de décharge des droits d'enregistrement supplémentaires réclamés, l'arrêt énonce

que le terme « cession », au sens de cet article, n'est pas uniquement limité à l'acte définitif de la cession de l'intégralité d'une ou plusieurs parts sociales, mais s'entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou de son démembrement, telle la cession de l'usufruit ou de la nue-propriété, le texte ne distinguant pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci, même si d'autres dispositions du code général des impôts procèdent à une telle différenciation. Il retient encore que la cession litigieuse a entraîné le transfert d'éléments de participation dès lors qu'en se dépossédant de l'usufruit des titres, les associés de la société civile immobilière NSG, qui ont perdu leur droit au bénéfice des dividendes, ont également perdu leur droit de vote afférent aux parts sociales cédées.

8. En statuant ainsi, alors que la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n'est pas soumise au droit d'enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui précède que l'acte des 7, 15 et 22 mars 2012, enregistré le 26 avril 2012 au service des impôts des entreprises, portant cession, par les consorts [F] à la société [F] participations, de l'usufruit des parts sociales de la société civile immobilière NSG, n'est pas soumis au droit d'enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l'article 726, I, 2°, du code général des impôts.

12. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, d'annuler la décision du 16 mars 2015 ayant rejeté partiellement la réclamation de la société [F] participations et de prononcer la décharge des droits d'enregistrement supplémentaires mis en recouvrement contre cette société.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement ;

Annule la décision du 16 mars 2015 rejetant partiellement la réclamation de la société [F] participations ;

Prononce la décharge des droits d'enregistrement supplémentaires mis en recouvrement ;

Condamne le directeur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales et le condamne à payer à la société [F] participations la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [F] participations.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [F] Participations de ses demandes tendant à la décharge totale des droits supplémentaires d'enregistrement auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la société appelante le terme « cession » n'est pas uniquement limité à l'acte définitif de la cession de l'intégralité d'une ou plusieurs parts sociales mais s'entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou son démembrement telle la cession d'usufruit ou de la nue-propriété ; que les premiers juges ont justement relevé que l'article 726, I, 2° du code général des impôts ne distingue pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement, peu important que d'autres dispositions du code général des impôts procèdent à cette différenciation ; que les dispositions de l'article 726, I, 2° du code général des impôts étant claires donc exclusives d'interprétation, la société appelante est mal fondée à soutenir qu'il conviendrait de procéder à une interprétation stricte de la loi fiscale ; que la société appelante est également mal fondée à soutenir que, au sens de l'article précité, la cession en litige ne porterait sur aucune participation dès lors que la société cédante conserverait la nue-propriété des titres ; qu'en effet, en se dépossédant de l'usufruit des titres, les associés de SCI NSG ont perdu leur droit de dividendes ainsi que leur droit de vote afférents aux parts sociales cédées ; que des éléments de participation ont été ainsi transférés et qu'il s'en déduit que la « cession d'usufruit temporaire de parts sociales » conclue les 7, 15 et 20 mars 2012 entre les consorts [F] et la société [F] participations de parts sociales de la SCI NSG entre dans le champ d'application de l'article 726, I, 2° du code général des impôts ;

ALORS QUE seules les cessions de participations dans les personnes morales à prépondérance immobilière sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 5% ; que la cession temporaire de l'usufruit de droits sociaux, dès lors qu'elle ne confère pas au titulaire une part du capital, mais seulement le droit temporaire de jouir et de percevoir les fruits de tels droits, n'est pas incluse dans le champ d'application de la taxe ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de cession d'usufruit temporaire de parts sociales des 7,15 et 20 mars 2012 que la SCI NSG, au capital de 49 300 000 euros, a été créée entre les consorts [F], lesquels ont cédé pour une durée de 20 ans l'usufruit de leurs parts à la société [F] Participation ; que cette dernière n'est devenue propriétaire avec la jouissance qui y est attachée que de l'usufruit temporaire des parts sociales, les consorts [F] demeurant propriétaires des parts et assumant le risque capitalistique qui s'y attache ; qu'en jugeant qu'une telle cession devait être regardée comme une cession de participation, la cour d'appel a violé l'article 726 du code général des impôts.

A 22 - Cession de l'usufruit de droits sociaux soumise au droit fixe (Cass. com. 4 janvier 2023, n° 20-10112)

Cass. com. 4 janvier 2023, n° 20-10112

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Centrale automobile Strasbourg (CAS), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-10.112 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié en ses bureaux, pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel, [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Centrale automobile Strasbourg, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 novembre 2019), le 15 septembre 2010, les membres de la famille [N], associés de la société civile immobilière GJH [Localité 3] (la société GJH), ont conclu avec la société Centrale automobile Strasbourg (la société CAS) une convention destinée à permettre le financement de la construction, sur un terrain appartenant à la société GJH, d'un immeuble devant être donné en location à la société CAS. Il était convenu qu'une certaine somme soit « confiée » par la société CAS aux associés de la société GJH, à charge pour ces derniers de souscrire à une augmentation de capital de la société GJH par augmentation de la valeur nominale unitaire des parts et de constituer, au profit de la société CAS, un usufruit temporaire sur lesdites parts.

2. Le 5 décembre 2013, soutenant que les actes passés en exécution de la convention du 15 septembre 2010 réalisaient une cession d'usufruit de parts sociales taxable au titre du droit d'enregistrement prévu à l'article 726, I, 2°, du code général des impôts, l'administration fiscale a notifié à la société CAS une proposition de rectification portant rappel de droits.

3. Après le rejet de sa réclamation, la société CAS a assigné l'administration fiscale en décharge des droits d'enregistrement mis en recouvrement.

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 726 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, et l'article 578 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement proportionnel.

6. Aux termes du second, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Il en résulte que l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l'usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.

7. Pour rejeter la demande de la société CAS en décharge des droits d'enregistrement, l'arrêt retient que l'opération litigieuse, vue sous l'angle des rapports entre les associés de la société GJH et la société CAS, réalise une cession de la valeur de l'usufruit des parts sociales de la société GJH, entrant dans le champ d'application de l'article 726, I, 2°, du code général des impôts.

8. En statuant ainsi, alors que la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n'est pas soumise au droit d'enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui précède que la constitution au profit de la société CAS de l'usufruit sur les parts sociales de la société GJH, réalisée en exécution de la convention du 15 septembre 2010, n'est pas soumise au droit d'enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l'article 726, I, 2°, du code général des impôts.

12. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du 22 janvier 2015 rejetant la réclamation de la société CAS et de confirmer le jugement uniquement en tant qu'il prononce la décharge des droits d'enregistrement mis en recouvrement le 24 septembre 2014 contre cette société et qu'il condamne la direction générale des finances

publiques prise en la personne du directeur régional de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin à payer à la société CAS la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la décision du 22 janvier 2015 rejetant la réclamation de la société Centrale automobile Strasbourg ;

Confirme le jugement uniquement en tant qu'il prononce la décharge des droits d'enregistrement mis en recouvrement le 24 septembre 2014 contre la société Centrale automobile Strasbourg et qu'il condamne la direction générale des finances publiques prise en la personne du directeur régional de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin à payer à la société Centrale automobile Strasbourg la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Centrale automobile Strasbourg.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la contestation de la société anonyme Centrale Automobile Strasbourg à l'encontre de la rectification opérée par l'administration fiscale et de l'avis de mise en recouvrement du 24 septembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En l'espèce, l'administration n'a pas invoqué le caractère fictif de l'un quelconque des actes conclus en application de la convention du 15 septembre 2010. Elle n'a pas non plus dénoncé un montage constitutif d'une fraude à la loi, au sens du texte légal précité, c'est-à-dire l'utilisation de procédés légaux détournés de leur finalité dans le but exclusif de bénéficier d'un avantage fiscal. En effet, l'administration n'a pas prétendu que les actes passés, que ce soit le versement de la somme de 3 550 000 euros par la société CAS aux associés de la SCI, la souscription par ceux-ci à une augmentation de capital de la SCI à hauteur de 3 625 000 euros et la constitution d'un usufruit des parts sociales au profit de la société CAS, ne correspondaient pas à l'objectif économique recherché par les parties, à savoir le financement de la construction d'un immeuble sur le terrain appartenant à la SCI, au moyen de capitaux apportés en plus grande partie par la société CAS, sans attribution à celle-ci de nouvelles parts sociales de la SCI, afin que la répartition du capital social demeure inchangée entre les membres de la famille [N]. L'administration a seulement considéré que ces actes faisaient apparaître l'existence d'une cession de l'usufruit des parts sociales entre les associés de la SCI et la société CAS. Ce faisant, elle a rétabli la véritable qualification de l'opération, qui était au demeurant celle adoptée par les parties elles-mêmes dans l'acte notarié de reconnaissance de dette du 25 octobre 2010, la rectification ultérieure de cet acte pour les seuls besoins de la cause étant sans emport, outre qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la distinction

entre "constitution" et "cession" d'usufruit, comme il sera vu ci-après. La requalification d'un acte ne constituant pas la dénonciation d'un abus de droit lorsque l'acte requalifié n'a pas été détourné de sa finalité voulue par législateur et conclu dans un but exclusivement fiscal, l'administration n'était pas tenue, en l'espèce, de respecter la procédure prévue en cas d'abus de droit. La procédure est donc régulière et le jugement déféré doit être infirmé. Sur le fond. Aux termes de l'article 726, I, 2° du code général des impôts, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 5 % pour les cessions de participations dans les personnes morales à prépondérance immobilière. La constitution d'usufruit se distingue de la cession d'usufruit en ce qu'elle intervient concomitamment au démembrement de propriété, alors que la cession suppose que le démembrement existait antérieurement. Dans le premier cas, l'usufruit, qui était englobé dans la pleine propriété, est détaché de la nue propriété pour être cédé au bénéficiaire de la constitution d'usufruit. La constitution d'usufruit réalise donc bien une cession, en ce que la valeur de l'usufruit est transférée du patrimoine du constituant à celui de l'usufruitier. Elle entre donc dans les prévisions du texte fiscal précité applicable aux cessions de droits sociaux. Dès lors, il est sans incidence qu'en l'espèce, l'opération litigieuse ait consisté en une constitution d'usufruit et non en une cession d'un usufruit préexistant. Pour être taxable en vertu de l'article 726, I, du code général des impôts, la cession de droits sociaux doit correspondre au transfert effectif de la valeur des droits sociaux d'un patrimoine vers l'autre, moyennant le paiement d'un prix qui est l'assiette de la taxation. En l'espèce, il est incontestable que la valeur de l'usufruit des parts de la SCI GJH [Localité 3] a quitté le patrimoine des membres de la famille [N] pour rejoindre celui de la société CAS. Comme le fait observer l'administration, cette valeur (3 550 000 euros) a été comptabilisée par la société CAS dans ses actifs, dans un compte "titres immobilisés". Pour nier l'existence d'une cession, la société CAS fait valoir que la somme de 3 550 000 euros versée par elle n'est pas demeurée dans le patrimoine des associés de la SCI, qu'elle leur avait seulement été "confiée" pour souscrire à une augmentation de capital de la SCI et que, dès lors, il ne s'agissait pas d'un prix. L'opération consisterait ainsi en un apport à la SCI réalisé par la société CAS, par l'intermédiaire des associés, rémunéré par l'attribution de droits en usufruit sur les parts sociales. Cette analyse est erronée en ce qu'elle considère que les associés n'ont joué qu'un rôle de simple intermédiaire dans une opération qui concernait la SCI et la société CAS. Or, cette opération n'était pas neutre à leur égard. En effet, d'une part les associés se sont dépouillés de l'usufruit de leurs parts sociales, d'autre part la valeur nominale de leurs parts est passée, après réalisation de l'augmentation de capital de la SCI, de 100 euros à 36 350 euros. En outre, l'usufruit étant temporaire et limité à quinze ans, les associés ont vocation à récupérer à terme la pleine propriété des parts sociales, de sorte qu'ils sont les bénéficiaires ultimes du versement, par la société CAS, de la somme de 3 550 000 euros, laquelle constitue donc bien un prix, contrepartie de l'usufruit constitué en faveur de la société CAS. Vue sous l'angle des rapports entre les associés de la SCI et la société CAS, l'opération litigieuse réalise donc une cession de la valeur de l'usufruit des parts sociales de la SCI. Dès, lors, la rectification opérée par l'administration est fondée et il convient de débouter la société CAS de ses prétentions » (arrêt attaqué, pp. 4-6) ;

ALORS QUE 1°) le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit clair et précis qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la convention conclue entre les associés de la SCI GJH [Localité 3] et la société Centrale Automobile Strasbourg le 15 septembre 2010 précise que la société CAS « confierait les fonds susvisés aux Membres de la famille [N] à charge pour ces derniers de souscrire à une augmentation de capital de la Société d'un montant global de 3.625.000 euros. En contrepartie, les Membres de la famille [N] constitueraient un usufruit temporaire sur les parts de la Société au profit de la CAS » (acte p. 2, antépénultième et pénultième alinéa) ; qu'il en résulte que cette convention avait pour objet d'organiser la réalisation d'un apport de fonds en vue d'une augmentation de capital au sein de la SCI GJH [Localité 3] en contrepartie d'un usufruit temporaire sur les parts sociales au profit de la société CAS ; qu'en retenant pourtant que cette convention réalisait une cession d'usufruit des parts sociales, la cour d'appel a dénaturé ladite convention, en violation du principe susvisé ;

ALORS, subsidiairement, QUE 2°), la cession d'usufruit des parts sociales suppose le transfert d'un usufruit préalablement constitué en contrepartie d'un prix fixé entre les parties ; que ne constitue donc pas une cession d'usufruit la constitution d'usufruit réalisée en rémunération d'un apport de fonds dans le cadre d'une augmentation de capital d'une société ; qu'en affirmant que la constitution d'usufruit réaliserait une cession au seul prétexte que la valeur de l'usufruit aurait été transférée du patrimoine du constituant à celui de l'usufruitier, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 10, al. 10), si la contrepartie de la constitution d'usufruit

était un apport de fonds dans le cadre d'une augmentation de capital et non le versement d'un prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil et de l'article 726, I, 2° du code général des impôts ;

ALORS, subsidiairement, QUE 3°), l'administration fiscale se fonde implicitement mais nécessairement sur le terrain de l'abus de droit lorsqu'elle entend soumettre à des droits d'enregistrement la cession de l'usufruit de parts sociales d'une société qu'elle estime avoir été dissimulée sous couvert de constitution d'usufruit ; qu'en jugeant que l'administration fiscale s'était bornée à rétablir la véritable qualification de l'opération, en considérant que les actes conclus en application de la convention du 15 septembre 2010 faisaient apparaître l'existence d'une cession de l'usufruit des parts sociales entre les associés de la SCI GJH [Localité 3] et la société Centrale Automobile Strasbourg (cf. arrêt attaqué, p. 5, §. 1er), en sorte qu'elle n'était pas tenue de respecter la procédure prévue en cas d'abus de droit (cf. arrêt attaqué, p. 5, §. 2), la cour d'appel a violé l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.